前言——民法简介

一、法系

法系是依据法律制度的历史传统——主要是指法律的精神、原则、观念和意识，法律的结构形态以及法律技术特征的差异和不同，而对自古至今全部法律所做的一种分类。

凡在法律的历史传统（主要是指法律的精神、原则、观念和意识）、法律的结构形态以及法律的技术方面具有相同或相似特征的法律，无论其实际存在的时间为何、无论其存在的地域为何，也不论其经济基础和反映的统治阶级的意志是什么，都属于同一法系。

1.大陆法系又被称为罗马法系、民法法系、法典法系、罗马—日耳曼法系，是指所有以古罗马法为基础，以法国民法典为蓝本所建立和发展起来的各个国家的法律构成的法系。其分布主要是以法国和德国为代表的欧洲大陆国家，以及曾经是法国、西班牙、荷兰、葡萄牙的殖民地的亚洲、非洲、拉丁美洲的许多国家和地区。

2.英美法系又被称为英国法系、普通法系、判例法系，是以中世纪英国的“普通法”以及后来出现的“衡平法”（均表现为“判例”形式）为基础和蓝本所建立和发展起来的各个国家的法律构成的法系。其分布主要是以英国（苏格兰除外）、美国（路易斯安那州除外）为代表，包括了英联帮成员国以及亚洲、非洲、拉丁美洲曾经是英国的殖民地的国家和地区。

从法律历史传统、法律的结构形态以及法律的技术方面，我国属于大陆法系。

二、民法的编纂体例

（一）民法的编纂体例有两种：第一为罗马式，又称为法学阶梯式；第二为德意志式，又称为潘德克顿式。

1、罗马式乃仿效罗马法学家盖尤斯的法学教科书《法学阶梯》的体例，分为三编，第一编人法，第二编物法，第三编诉讼法。法国民法典即采此体例，惟将诉讼法排除在外，第一编人，第二编财产及对所有权的各种限制，第三编取得财产的各种方法。

2、德意志式又称潘德克顿式，乃是德国法学者于著述中的所用体例，为德国民法典所沿用。共分五编，第一编总则，第二编债权，第三编物权，第四编亲属，第五编继承。

（二）我国民法典已颁布（2020 年。总则—物权—合同—人格权—婚姻家庭—继承—侵权责任。），在编制体例上属于变种的潘德克顿式。

• 民法的学习与适用

学习民法的过程，是由“一般到特殊”，即先学习总则，后学习分则。但关于法律的适用，则反其道而行，即由“特殊到一般”，由“后”到“前”，须无特别规定时，才可适用一般原则。

三、民法各编

- 民法总则
- 债法
- 物权法
- 亲属法
- 继承法

（一）民法总则的规定能够适用于全部的民商法领域，其主要内容包括民法的概念与含义、民法的沿革、民法的调整对象、民法的性质、民法的本位、民法的渊源、民法的效力、民法的基本原则、民事法律关系、民事法律关系主体、民事法律关系客体、民事法律关系变动（民事法律行为、代理、诉讼时效、除斥期间和期限。）

（二）债法指调整债权债务关系的法律规范的总称。债是特定人与特定人之间得请求为特定行为的法律关系。各国民法多将合同、无因管理、不当得利和侵权行为规定为能够引起债发生的重要法律事实。其中，合同引起的债称为合意之债；无因管理、不当得利与侵权行为引起的债称为法定之债。

债法
- 合同
- 无因管理
- 不当得利
- 侵权行为

1、合同，是指当事人双方设立、变更、终止债权债务关系的合意。

2、无因管理，是指没有法律规定的和约定的义务而为他人管理事务的行为。

3、不当得利，是指没有合法根据而取得利益，使他人遭受损害的事实。

4、侵权行为是指不法侵害他人合法权益，给他人造成损害的行为。

（三）物权法是调整人对物的支配关系的法律规范。物权法包括所有权、用益物权、担保物权、占有。

1、所有权是在法律限制的范围内，对于所有物永久全面与整体支配的物权。其包括不动产所有权、动产所有权、建筑物区分所有权、相邻关系和共有等。

2、用益物权是指占有他人所有的不动产于一定范围内使用收益的限制物权。其包括地上权（我国民法典中建设用地使用权与宅基地使用权的合称）、永佃权（我国民法典中的土地承包经营权）、地役权、居住权、典权（我国民法典中没有规定）。

3、担保物权是指为确保债务的清偿而于债务人或第三人的特定物或权利上成立的一种定限物权。其包括抵押权、质权、留置权。

4、占有是对于物有事实上的管领力。

（四）亲属法（我国民法典中的婚姻家庭法）是规定亲属关系的发生、变更和消灭，以及夫妻、父母子女和其他一定范围的亲属之间的身份地位、权利和义务的法律规范的总称。其主要包括亲属制度、结婚、离婚、收养。

（五）继承法是指调整因自然人的死亡而发生的继承法律关系的法律规范的总称。其主要包括继承法律关系、法定继承、遗嘱继承、遗赠、遗赠扶养协议、遗产的处理。

• 注意：人格权法，是调整因人格权的享有和保护而产生的民事关系的法律规范。其主要包括一般规定、生命权、身体权和健康权、姓名权和名称权、肖像权、名誉权和荣誉权、隐私权和个人信息保护。

四、马克思主义是民法学研究的理论基石

民法学应以马克思主义为指导。（马克思主义经典作家关于民法的论述既为民法学研究提供了方法论指导，也为民法学理论体系的构建提供了思想资源。我们的民法学研究必须坚持马克思主义方法论，以习近平新时代中国特色社会主义理论为指导，以社会主义法治理论为基础，只有这样，才能从根本上保障我们民法学研究的科学性。）

（一）民法学的研究方法

辩证唯物主义和历史唯物主义是马克思主义最根本的世界观和方法论，应作为民法学研究的基本方法。唯物史观和唯物辩证法也为民法学研究奠定了世界观和方法论基础。

（二）民法根植于市场经济

马克思主义在产生之时就认识到了民法与社会经济生活之间的内在关联，尤其是民法与商品经济之间的联系。马克思主义经典作家为了解民法与市场经济的关系、把握民法的发展规律提供了理论指导。

（三）从民法的调整对象来看，民法调整的财产关系实际上主要是财产归属关系和财产流通关系。

马克思主义观点对准确把握民法的调整对象和范围具有重要的理论指导意义。

（四）民法主要是权利法

马克思主义经典作家关于民法是权利法进行了深刻论述。

五、构建中国特色的民法学理论体系

（一）中国特色民法学理论体系的含义

中国特色民法学理论体系就是对中国民事立法、民事司法具有解释力的理论体系，在内容上以传统民法基本制度为参照，并结合中国的民事立法和实践形成了自己的理论体系。

• 注意:党的十九大报告提出，“发展中国特色社会主义法治理论”，并提出“保护人民人身权、财产权、人格权。”这为民法学的发展指明了方向。就民法学而言，我们要构建具有中国特色的民法学理论体系，这样一个体系应当立足于中国实践、内生于中国文化传统、回应中国社会现实需求，展示民族时代风貌。尤其需要注意的是，我国的民法学理论体系应坚持以马克思主义方法理论和习近平新时代中国特色社会主义理论为指导，以社会主义法治理论体系为基础，最充分地反映广大人民群众的利益和意愿，反映公平正义的法治理念，以全面保护公民权利、推进社会主义法治为重要目的。

（二）中国特色民法学理论体系的特征

1、本土性

中国特色的民法学应当从中国的实际出发，在结构和同容上应充分回应中国市场经济建设过程中出现的诸种问题，其研究对象包括作为市场经济基本规则和市民生活“百科全书”的民法和商法。中国民法学理论体系应当植根于中国大地，以中国问题为中心。

2、实践性

民法学研究应当来源并服务于中国改革开放的伟大实践，对社会生活中产生的现实问题提出创造性的解决方案，以此为民主法治建设作出贡献。

3、包容性

中国特色的民法学应当具有对世界优秀民法文化的开放和包容态度。

4、时代性

一方面，中国特色的民法学应当不断地与时俱进，随着我国市场经济的发展而不断发展，并与改革相伴而行，不断反映和确认改革开放的成果，为国家的法治改革建言献策。另一方面，民法学也应当反映时代精神、体现时代特征。具体来说，应当不断反映互联网时代、高科技时代、大数据时代的特点，反映经济全球化的发展趋势。

5.科学性

民法学本身具有科学的理论体系和科学的研究方法。

第一编 绪论

第一章民法概述

第一节 民法的概念与含义

一、民法的概念

民法是调整平等主体的自然人、法人、非法人组织之间的财产关系和人身关系的法律规范的总称。

二、民法的语源

（一）就语源而言，民法一词可以追溯到罗马市民法；结合民法调整的社会关系的性质来说，民法源于中世纪后期市民国家的市民法。

（二）民法一词并非我国法律史上固有的概念。我国作为法律术语的“民法”一词是从日本移植而来。1929 年 5 月 23 日南京国民政府公布民法典（民法典的第一编），是我国法律上使用“民法”一词的开始。

三、民法与民法典

（一）成文法与习惯法

1、成文法，是指国家机关根据法定程序制定发布的具体系统的法律文件。

2、习惯法，是指独立于国家制定法之外,依据某种社会权威，具有一定强制性的行为规范的总和。

• 注意：

民法一般是成文法，包括民事法律、法规，也有习惯法。

（二）民法典与民事单行法

1、民法典，是按照一定体系将各种基本的民事法律制度编纂在一起的民事基本规范，它由国家立法机关制定和颁布，通常冠以“民法典”的称谓；也有不加“典”字的。

2、民事单行法，是指专门针对某个方面制定的民事规范。

•注意:按照一般法与特别法的分类，民法典属于一般法，民事单行法属于特别法。

（三）形式的民法与实质的民法

1、形式的民法，又称形式意义的民法，是指法典化的成文民法。

2、实质的民法，又称实质意义的民法，是指不论是否标明“民法”二字，不论是否成文，凡具有民法性质的法规或习惯都是民法。

四、民法与民法学

（一）民法与民法学的概念

1、“民法”一词有时指作为一个法律部门的民法，有时指作为法学学科的民法学。

2、民法学是研究民法规范及有关学理的一门学科。（教科书、专著、学术论文和演说）

（1）狭义的民法学，又称为民法规范学、民法解释学，是指以阐明现行民事法律规范为内容的民法学。

（2）广义的民法学，包括比较民法学、民法社会学、民法哲学和民法史学等。

（二）民法与民法学的关系

1、民法与民法学的区别

民法与民法学的性质不同。民法是由国家制定和由国家强制力保证实施的。民法学是一种学说，不具有国家强制力（法律明确规定法理作为民法渊源的是为例外）。

2、民法与民法学的联系

民法与民法学互有联系、互有影响。

五、民法与商法

商法，是调整商事关系的法律规范的总称。

商法
- 公司法
- 票据法
- 保险法
- 破产法
- 海商法

（一）民商分立

民法与商法分立制度，简称民商分立。是将民法与商法分开，其主要表现形式是既有民法典，又有商法典。（法、德、日）

（二）民商合一

民法与商法合一制度，简称民商合一。是民法和商法合为一体，其表现形式是只有民法典，没有商法典。（瑞士、意大利、我国民国时期的民法典和新的荷兰民法典。我国）

• 注意：无论民商分立还是民商合一，民法均为基本法，民法的基本原理、基本原则和基本规定适用于商法。

• 注意: 现在我国民法典已颁行，我国立法采取的是民商合一制，通常说的民法包括商法在内。在立法上采取民商合一，并不排除在学理和学科设置上区分民法学与商法学，因此从学理上讲，有些情况下讲的民法包括商法，有些情况下讲的民法不包括商法。

相关法条：

《民法典》第一条 为了保护民事主体的合法权益，调整民事关系，维护社会和经济秩序，适应中国特色社会主义发展要求，弘扬社会主义核心价值观，根据宪法，制定本法。

相关法条：

《民法典》第二条 民法调整平等主体的自然人、法人和非法人组织之间的人身关系和财产关系。

第二节 民法的沿革

一、罗马法的编纂及其影响

（一）历史背景

商品经济的发展为罗马奴隶制法律奠定了良好的基础。

（二）内容

1、《国法大全》（又称为《民法大全》或《罗马法大全》），包括《查士丁尼法典》、《法学阶梯》、《法学总论》、《学说汇篡》、《新律》。

2、按照内容，罗马法分为人法（人格和身份的法）、物法（财产法）和诉讼法（诉讼程序和法官职权等）。（《法学阶梯》）

（三）特点

1、罗马法对罗马奴隶制时期的商品经济关系作了详细规定。

2、罗马法和在罗马法基础上形成的中世纪后期的市民法成为反映资本主义商品经济要求的民法的渊源。

二、19 世纪民法典的编纂及其典型

（一）《法国民法典》

1、历史背景

19 世纪资本主义经济迅速发展，为巩固资产阶级革命成果，法典编纂运动随之兴起。

2、内容

《法国民法典》共 2283 条，分为三编：第一编人，第二编财产及对于所有权的各种变更，第三编取得财产的各种方法。

注意:《法国民法典》体系参考了罗马法的《法学阶梯》的体例，但把诉讼法分离出去，开创了实体法与程序法分别立法的先例。

3、特点

（1）《法国民法典》巩固了大革命的重要成果，文字生动明朗，对许多国家的民法产生了深远的影响。

（2）《法国民法典》不仅没有和大革命以前的旧法律一刀两断，而且吸收了传统的与先进的民法理论。

（二）《德国民法典》

1、历史背景

为了经济发展的需要，并通过民法典统一各邦的法制，以加强帝国在政治上的统一。

2、内容

《德国民法典》共 2385 条，分五编：第一编总则，第二编债务关系法，第三编物权法，第四编亲属法，第五编继承法。（潘德克顿体系）

3、特点

（1）《德国民法典》结构严谨、概念精确、逻辑清晰，被法制史学者称为 19 世纪德国法律科学的集成，对 20 世纪一些国家的民法典产生了巨大的影响。

（2）《德国民法典》对契约自由原则作了一些限制，规定了一些一般条款，如“诚实信用”、“善良风俗”，后来在司法实践中这些规定发挥了灵活适用法律的积极作用。

（3）《德国民法典》是为法律家制定的，文字艰深晦涩，有些规定苛细难懂。

三、20 世纪至今有代表性的民法典

（一）《瑞士民法典》

1、历史背景

适应经济发展需要、统一各州的私法。

2、内容

《瑞士民法典》共五编：第一编人格法，第二编亲属法，第三编继承法，第四编物权法，第五编债务法。

3、特点

（1）《瑞士民法典》是<u>世界上第一部采取民商合一的民法典</u>。

（2）《瑞士民法典》的立法者抛弃了法、德两国立法者力求民法典完备的观念，明确规定“如本法无相应规定时，法官应依据惯例；无惯例时，依据自己作为立法者所提出的规则裁判”，并把诚实信用和禁止权利滥用提高到基本原则的地位。

（3）《瑞士民法典》保持了一种民族化的生动语言，具有清晰分明、相对有余地的体系。

（二）荷兰

1、内容

荷兰制定的新民法典为 10 编：第一编人法和家庭法，第二编法人，第三编财产法总则，第四编继承法，第五编物权法，第六编债法总则，第七编有名合同，第八编运输法，第九编智力成果法，第十编国际私法。

2、特点

（1）荷兰新民法典取代了 1838 年颁布的荷兰民法典和商法典，由民商分立转变为民商合一。

（2）荷兰新民法典的体系新颖、颇具特色，在世界上引起了广泛的关注。

（三）《苏俄民法典》

1、1922 年《苏俄民法典》

1922 年《苏俄民法典》分为总则、物权、债和继承四部分。婚姻家庭关系没有规定在民法典中，1926 年制定了《苏俄婚姻、家庭与监护法典》。

2、1964 年《苏俄民法典》

1964 年《苏俄民法典》共 569 条，分为 8 章：第一章总则，第二章所有权，第三章债权，第四章著作权，第五章发现权，第六章发明权，第七章继承权，第八章外国人和无国籍人的权利能力、外国民事法律、国际条约和国际协定的适用。

• 注意：苏联解体后，自 1994 年至 2006 年《俄罗斯联邦民法典》分四个部分先后通过。该法典分为七编：总则；所有权和其他物权；债法总则；债的种类；继承法；国际私法；智力活动成果和个别化手段的权利。共 77 章，1551 条。该法典在体例上继受了 1964 年的《苏俄民法典》的一些规定，包括总则编第 2 条明文规定民事立法所调整的关系；第 2 章规定民事权利和义务的产生，民事权利的实现与保护；婚姻家庭法不在民法典中规定。该法典一个突出的特点是关于知识产权的规定（第七编），共 327 条。

四、我国的民事立法

（一）我国古代公法特别发达，私法不发达。（商品经济发展迟缓和古代王朝法律侧重巩固政权）

（二）《大清民律草案》（未及公布）（我国历史上首次民法编纂）

（三）《中华民国民法》（该法典分为总则、债、物权、亲属、继承五编，共 1225 条，采民商合一制，这是我国第一部民法典。）

（四）《中华人民共和国民法典》（2020）

• 注意：当今，我国民法以《民法典》为基本法，《著作权法》、《专利法》和《商标法》等知识产权法与《公司法》、《证券法》、《票据法》、《海商法》、《保险法》和《破产法》等商事法，是民事特别法。

第三节 民法的调整对象

根据《民法典》第二条：民法调整平等主体的自然人、法人和非法人组织之间的人身关系和财产关系。我国民法的调整对象为：<u>平等主体</u>的自然人、法人、非法人组织之间的<u>财产关系和人身关系</u>。

一、民法调整的财产关系

（一）财产的概念

1、狭义的财产，是指有金钱价值（即能用金钱表示或者有用金钱衡量的价值）的权利的总和。（物权、债权和知识产权等）

2、广义的财产，是指财产权利和财产义务（债务）的总和。

• 注意：

1、没有形成财产权利但具有金钱价值的利益，也属

于财产的范围。（商业秘密在归入知识产权之前，信息财产、网络虚拟财产在法律确定其为财产权之前。）

2、具有精神、文化或者纪念价值的私人书信、照片、手稿和录音等，可以用保护财产权的方式予以保护，其中有些也可以成为具有金钱价值的财产。

（二）民法调整以平等自愿为基础的财产关系

1、民法调整平等主体之间的财产关系，基于行政经济管理发生的财产关系，属于不平等主体之间的财产关系，由行政法、经济法调整。

2、主体地位的平等性，决定了他们之间发生财产关系必须坚持自愿原则，由当事人自主决定，国家一般不干预。

（三）民法调整财产归属关系与财产流转关系

根据财产关系的内容，财产关系可分为财产归属关系与财产流转关系。

1、财产归属关系，是指财产所有和支配关系。

2、财产流转关系，是指某项财产由一方向另一方转移而发生的关系。

二、民法调整的人身关系

（一）人身关系的概念与种类

1、人身关系的概念

人身关系是与人身不可分离、以人身利益为内容、不直接体现财产利益的社会关系。

2、人身关系的种类

（1）人格关系是基于人格利益而发生的社会关系。

（2）身份关系是以特定的身份利益为内容的社会关系。

注意：人身关系不是仅由民法调整，但主要由民法调整，根据宪法确认和保护各种人身权利是民法的基本任务。行政法和刑法也保护人身权，其保护方法与民法不同。人身权受到非法侵害时，民法采用恢复名誉、赔偿损失等民事责任方式予以保护；行政法和刑法对人身权的保护，分别采用行政制裁和刑罚的方法。

（二）民法调整的人身关系的特征

1、主体地位平等

2、与人身不可分离

3、不直接体现财产利益

第四节 民法的性质

一、民法是私法

（一）公法与私法的区别标准

1、利益说

保护公益的法律为公法；保护私益的法律为私法。

2、隶属说

公法的根本特征在于调整隶属关系；而私法的根本特征在于调整平等关系者。

3、主体说

如果至少一方当事人是以公权主体的性质参加这项法律关系的，则这项法律关系就属于公法范围；不符合这一条件的所有法律关系都属于私法范围。

4、折中说

只有国家等公共机构行使职权的时候的关系才属于公法的调整范围。

（二）公法与私法区别的意义

1、有助于认识二者的特色，即私法与公法有不同的规范规则：私法以个人自由决定为特征，公法则以强制或拘束为内容；私法强调自主决定，公法须有法律依据及一定的权限。

2、诉讼时的法院管辖及救济程序不同。

（三）民法属于私法

民法属于私法，因为民法旨在规范个人间的利益，以平等为基础，其主体均为私人或非基于公权力的地位，对任何人皆可适用。民法的主要特征及规范意义在于私法自治，即个人得自主决定，自我负责地形成彼此间的权利义务关系。

• 注意：

1、我国民法与资本主义的民法在理论上和立法技术上有共同点，这是由市场经济规律和人类社会生活都有其共性所决定的。

2、由于社会制度、指导思想和国情的不同，我国民法必然有其特点。

二、民法是调整市场经济的基本法

商品经济是民法产生和发展的经济基础，要进行商品生产和商品交换，必须具备三个基本条件：一是有进行商品生产和商品交换的人，二是有商品，三是有商品与货币（或者商品）交换。

各国民法的体系和具体内容有所不同，但是都有民事主体制度、物权或者财产权制度、债权债务制度或者合同制度，这三项制度是民法的基本制度，是调整商品经济的基本制度。

三、民法是调整市民社会关系的基本法

（一）在观念上应当区分市民社会与政治国家，区分市民与公民。民法调整市民社会关系，重在保护市民的私权，协调市民利益，以构建各谐的市民社会秩序。

（二）市民社会是市场经济社会，我国民法作为调整市场经济的基本法，重在反映市场经济的发展规律，促进市场经济健康发展。

第五节 民法的本位

一、权利本位的要义

在整个法律体系中，应当以权利为起点、核心和主导。（在权利和义务的关系中，权利本位的法律精神意味着：权利是目的，义务是手段，法律设定义务的目的在于保障权利的实现。在权利和义务的关系中，权利本位的法律精神意味着：公民的权利是国家权力的源泉，也是国家权力配置和运作的目的和界限。）

二、民法的本位——权利本位

（一）我国民法以权利为本位是以人为本的理念在法律上的体现。

（二）民法的基本任务是确认和保护民事权利，以权

利为本位发挥民法功能之本。

第六节 民法的渊源

民法的渊源，是指民法的表现形式。

一、制定法

（一）宪法中有关民法的规定

1、宪法是国家的根本法，具有最高的法律效力，是民事法律的立法根据。宪法不是作为“民法表现形式”的渊源。

2、基本权利对第三人的间接效力理论

宪法中有关基本权利的规定是否可以直接适用于民事法律关系，有不同的观点。德国学者创立了“基本权利对第三人的间接效力”理论，即宪法上规定的基本权利不具有私法上的直接效力，基本权利在私法领域产生效力应以民法上的概括条款或者不确定性概念为“桥梁”，通过法官对概括条款的“合宪解释”，以宪法精神和内容充实之，将基本权利转化为私法规范，从而使基本权利对民事法律关系发生间接效力。

（二）民事法律

1、民事法律，是指由全国人民代表大会及其常务委员会制定颁布的民事方面的规范性文件。

2、有些法律从整体上看其性质属于行政法或者经济法，但其中有关于民事问题的条款，也属于民法规范。

（三）民事法规

1、行政法规，是指作为国家最高行政机关即国务院所制定规范性文件。

2、部门规章，是指国务院所属各部（委）在各自权限内所发布的规范性文件。

（四）地方性法规中的民事规范

省、自治区、直辖市和设区的市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规中，有些属于民事规范，这些法规不能与宪法、法律和行政法规相抵触。

（五）特别行政区的民事规范

1、特别行政区的原有法规中有大量的民法规范，这些民法规范只适用于各该特别行政区。

2、在特别行政区实施的全国性法律中，没有民事规范。

（六）国家机关对民事法律规范的解释

根据我国现行法律规定，我国的法律解释分为立法解释和司法解释两种。其中立法解释由全国人大常委会作出，司法解释由最高人民法院和最高人民检察院作出。

（七）国际条约中的民事法律规范

国际条约是国际法的主要渊源，不属于我国国内法范畴。但是通过法定程序，国际条约可以具有与国内法同样的拘束力，因此也成为我国民法的渊源之一。

二、习惯

（一）习惯为民法的渊源。（这里的习惯既包括民间习惯，也包括商业习惯。商人间的交易惯例、村规民约，都为习惯。）

（二）适用习惯处理民事纠纷，须具备两个基本条件：一是该事项法律没有规定，即无法律可适用；二是可适用的习惯不违背公序良俗。

三、判例

（一）在我国判例并没有法律约束力，判例不是我国民法的渊源。

（二）对全国法院审判、执行工作具有指导作用的指导性案例，由最高人民法院确定并统一发布。最高人民法院发布的指导性案例，各级人民法院审判类似案例时应当参照。

四、法理

（一）法理，是指法的原理。作为民法渊源的法理，是由立法精神演绎而形成的处理民事关系的原理。（作用在于弥补民法法律规定之不足）

（二）我国民法没有规定法理是民法的渊源，但是法理对于解释民法和法官裁决民事案件实际上起着重要作用。

相关法条：《民法典》第十条 处理民事纠纷，应当依照法律；法律没有规定的，可以适用习惯，但是不得违背公序良俗。

相关法条：《民法典》第十一条 其他法律对民事关系有特别规定的，依照其规定。

相关法条：《民总解释》第一条 民法典第二编至第七编对民事关系有规定的，人民法院直接适用该规定；民法典第二编至第七编没有规定的，适用民法典第一编的规定，但是根据其性质不能适用的除外。

就同一民事关系，其他民事法律的规定属于对民法典相应规定的细化的，应当适用该民事法律的规定。民法典规定适用其他法律的，适用该法律的规定。

民法典及其他法律对民事关系没有具体规定的，可以遵循民法典关于基本原则的规定。

相关法条：《民总解释》第二条 在一定地域、行业范围内长期为一般人从事民事活动时普遍遵守的民间习俗、惯常做法等，可以认定为民法典第十条规定的习惯。

当事人主张适用习惯的，应当就习惯及其具体内容提供相应证据；必要时，人民法院可以依职权查明。

适用习惯，不得违背社会主义核心价值观，不得违背公序良俗。

第七节 民法的效力

民法的效力，又称民法的适用范围，是指民法发生效力的范围，即民法对什么人、在什么地方和在什么时间发生效力。

一、民法对人的效力

（一）民法对人效力的概念

民法对人的效力，是指民法适用于哪些人。

（二）民法对人的效力

1、在我国领域内有中国国籍的自然人，依据我国法律设立的中国法人和其他组织相互之间的民事法律关

系，均适用我国民法。外国人、无国籍人在我国领域内的民事关系，一般适用我国法律，但法律另有规定的除外。（我国自然人、法人在国外发生的民事关系，一般适用所在地国家的法律，但法律另有规定的除外。）

2、当事人依照法律规定可以明示选择涉外民事关系适用的法律。中华人民共和国法律对涉外民事关系有强制性规定的，直接适用该强制性规定。外国法律的适用将损害中华人民共和国社会公共利益的，适用中华人民共和国法律。

二、民法在空间上的效力

（一）民法在空间上的效力的概念

民法在空间上的效力，是指民法在哪些地方发生效力。

（二）我国民事法律规范的适用领域

1、适用于我国全部领域的民事法律、法规。

2、适用于局部地区的地方性民事法规。

3、适用于特别行政区的民事规范。

★领域：领域，是指我国领土、领空、领海，还包括我国驻外使领馆，以及在我国领域外航行的我国船舶和飞行于我国领空以外的我国飞行器等。

相关法条：《民法典》第十二条 中华人民共和国领域内的民事活动，适用中华人民共和国法律。法律另有规定的，依照其规定。

三、民法在时间上的效力

（一）民法在时间上的效力的概念

民法在时间上的效力，是指民法生效时间和失效时间，以及民事法律规范对其生效前发生的民事关系有无溯及力。

（二）民法生效的时间

1、自民事法律规范公布之日起开始生效。

2、民事法律规范公布后经过一段时间后生效。

（三）民法失效的时间

1、新法直接规定废止旧法。

2、旧法规定与新法相抵触的部分失效。

3、由国家机关颁布专门的决议规定，宣布某些法律失效。

★默示废止：如果新法与旧法规定相冲突时，应适用“新法优于旧法”、“后法优于前法”的原则，以新法、后法为准，在学理上称为默示废止。

（四）关于民法的溯及力问题

我国的民事法律规范贯彻法律不溯及既往的原则，一般没有溯及力，但也有例外。通常我国民事法律规范的追溯力，体现为“有利追溯”原则。所谓有利追溯原则，是指如果民事法律规范具有追溯力，有利于保护民事权益，就使其具有追溯力。

相关法条：《民法典》第十二条 中华人民共和国领域内的民事活动，适用中华人民共和国法律。法律另有规定的，依照其规定。

第二章民法的基本原则

第一节 民法基本原则概述

一、民法基本原则的含义

民法基本原则，是指民事立法、民事法律行为和民事司法的基本准则。

（一）民法基本原则是民事立法、民事法律行为和民事司法的基本准则。

（二）民法基本原则是贯穿于民事法律规范整体的基本准则。

（三）民法基本原则是民法调整的社会关系和民法观念的综合反映。

二、学理民法基本原则与法定民法基本原则

（一）学理民法基本原则与法定民法基本原则的含义

1、学理民法基本原则，是从学理上提出的基本原则，通常是由一定的观念、理论为指导概括出来的。

2、法定民法基本原则，是指在民事基本法中明文规定的基本原则。

（二）学理民法基本原则与法定民法基本原则的关系

1、区别

学理民法基本原则与法定民法基本原则性质不同，学理原则只有理论性，没有法律效力；法定原则具有法律效力。

2、联系

学理原则对法定原则有指导意义，如被立法者采纳，学理原则就成为法定原则。反之，法定原则一经公布，也会对民法基本原则的研究起推动作用。

三、民法基本原则的功能

民法基本原则的功能，是指民法基本原则在民事立法、民事法律行为和民事司法中的作用。

（一）指导功能

（二）约束功能（修正功能）

（三）补充功能

民法基本原则的修正功能：

1、从民事立法和司法的发展历史看，民法的一般条款和基本原则的重要作用在于克服民法规范的局限性，必要时司法机关在处理个案时，可以根据民法的基本原则限制法律条文的效力。学理上对这种功能称为修正功能。

2、在肯定民法基本原则的修正功能的同时，还应强调适用基本原则处理案件时，应充分阐明理由，并应有严格的程序。

民法基本原则的适用：

1、通常在民法规范有具体规定的情况下，必须适用具体规定，不能直接适用民法的基本原则。在民法规范没有具体规定的情况下，民法的基本原则对民法规范起补充作用。

2、补充法律漏洞和法院造法，比根据基本原则限制法律的效力有更高的要求，应当十分慎重，需要针对

个案，根据民法的基本原则，以正确的理论为指导，进行充分说理的创造性裁决。

★我国民法的基本原则：

1、权利不可侵原则（私权神圣原则）

2、平等原则

3、自愿原则

4、诚实信用原则

5、禁止权利滥用原则

6、公平原则

7、公序良俗原则

8、绿色原则

第二节 权利不可侵原则

一、民法主要保护人身、财产等权益

民法系统全面地规定了民事主体所享有的各项人身、财产权益，虽然其所保护的民事权益非常宽泛，但并非所有的权益都受到民法的保护，一些公法上的权利，如劳动权、受教育权、主要受公法保护，民法保护的主要是私权，其中以人身、财产权益为基本内容。

二、民法不仅保护权利，而且保护利益。

不论是权利还是利益，都受到法律保护。这为将来对新型民事权益的保护预留了空间，保持了民法总则规则的开放性。

三、对新型民事权益进行保护。

对新型民事权益的保护，体现了当代中国的时代特征，回应了当今社会的现实需求。（如个人信息保护规则）

四、在民事权益受到侵害时，民法主要通过民事责任对权利人进行救济。

在权利人的权利受到侵犯时，权利人可以依法请求有关行政机关给予保护，也可以诉请人民法院或者仲裁机关予以判决或仲裁。

相关法条：《民法典》第三条 民事主体的人身权利、财产权利以及其他合法权益受法律保护，任何组织或者个人不得侵犯。（权利不可侵原则）

第三节 平等原则

一、平等原则的意义

（一）平等原则是民法调整的社会关系的性质决定的，没有平等就没有民法，平等原则是民法的其他基本原则的基础。

（二）平等原则对于划清民法与行政法、经济法的界限，在立法和司法上都有实际意义。

二、平等原则的体现

（一）民事权利能力平等。

（二）民事主体地位平等。

（三）民事权益平等地受法律保护。

• 注意：

社会上存在的分配不公，贫富差距悬殊等问题，是行政法、经济法和社会保障法解决的问题；民法可以在其功能范围内保护弱者，限制形式上平等而事实上的不平等。

相关法条：《民法典》第四条 民事主体在民事活动中的法律地位一律平等。

第四节 自愿原则

一、自愿原则的含义

自愿原则，是指民事主体根据自己的意愿，自主地行使民事权利，参与民事法律关系，国家对于民事法律关系不过多干预。

二、自愿原则的体现

（一）民事主体根据自己的意愿自主行使民事权利。

（二）民事主体之间自主协商设立、变更或者终止民事关系。

（三）当事人的意愿优于任意性民事法律规范。

相关法条：《民法典》第五条 民事主体从事民事活动，应当遵循自愿原则，按照自己的意思设立、变更、终止民事法律关系。

私法自治（意思自治）

一、私法自治的概念

私法自治，是指个人得依其意思形成其私法上权利义务关系。

二、私法自治的表现

私法自治原则表现在各种制度上，如所有权自由，即所有人在法律限制的范围内，能够自由使用收益处分其所有物；遗嘱自由，即个人在其生前，能够以遗嘱处分财产，决定死后其财产的归属。然而，最主要的是契约自由。

★契约自由：契约自由，是指当事人能够依其意思的合致，缔结契约而取得权利，负担义务，其基本内容有四个方面：第一，缔结自由，即缔结契约与否，由当事人自由决定；第二，相对人自由，即与何人缔结契约，由当事人自由选择决定；第三，内容自由，即契约的内容，由当事人自由决定；第四，方式自由，即契约原则上仅依意思合致即可成立，不以践行一定方式为必要。

三、私法自治的功能

私法自治原则是建立在19世纪个人自由主义之上，排除了当时封建身份关系及各种法律对个人的束缚，废除了法人（尤其是公司）的特许主义，保障私有财产，实践营业自由，对于维护个人自由与尊严，促进社会经济发展，文化进步，贡献巨大。

四、私法自治的限制

（1）民法本身设有基本规范，即规定民事法律行为违反法律或者社会公共利益的为无效，其作为规制意思自治原则的规范基础。

（2）制定一些法律，以维护社会正义。如《劳动法》、《消费者权益保护法》等。

第五节 诚实信用原则

一、诚实信用原则的含义

（一）诚实信用原则的含义

1、人类社会的理想。

2、交易上的道德基础。

3、与罗马法上的一般的恶意抗辩的意义相同。

4、对当事人利益的公平较量。（多数说）

（二）诚实信用原则主要是针对民事法律关系中的弄虚作假、欺骗他人、损人利己的行为而形成的基本原则。诚实信用原则侧重于对民事主体的主观要求，但是衡量是否违反诚实信用原则，需要客观地衡量当事人之间的利益来认定。

二、诚实信用原则的功能

诚实信用原则具有法律价值判断、填补法律漏洞和修正制定法的功能。

三、诚实信用原则的体现

（一）在设立或者变更民事法律关系时，不仅要求当事人诚实、不隐瞒真相，不作假，不欺诈，还应当给对方提供必需的信息。

（二）民事法律关系建立后，当事人应当恪守诺言，履行义务，谨慎维护对方的利益，满足对方的正当期待，应当根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。

（三）民事法律关系终止后，当事人应当为维护对方的利益，实施一定行为或者不实施一定行为。

四、违反诚实信用原则的事例

（一）建筑施工企业文谎报资质等级，超出其实际资质等级许可的范围，订立施工合同。

（二）债务人交付的商品的瑕疵极小，债权人据此主张退货。

（三）债务人履行债务迟延 30 分钟，债权人没有因此受损失，债权人拒此主张退货。

（四）借款合同的甲乙双方约定偿还借款可以在任何地点，后来甲乙一起旅行，途中遭遇强盗，此时债务人提出还款。

（五）甲遗失贵重物品，登报称：拾得人送还遗失物时，给付酬金 10000 元。乙将拾得的该物送还给甲，甲以登报给付酬金是出于无奈，不是真实意思表示为由，拒绝给付酬金。

（六）病人出院时请求医院复制其病历，医院拒绝。

相关法条：《民法典》第七条 民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。

EG：甲、乙二人同村，宅基地毗邻。甲的宅基地倚山、地势较低，乙的宅基地在上将其环绕。乙因琐事与甲多次争吵而郁闷难解，便沿二人宅基地的边界线靠己方一侧，建起高 5 米围墙，使甲在自家院内却有身处监牢之感。乙的行为违背民法的诚信原则。

第五节 禁止权利滥用原则

一、权利滥用的含义

权利滥用是指行使民事权利超出了一定界限而损害他人权益或者公共利益的。

二、权利滥用的条件

（一）当事人有权利存在。

（二）权利人有行使权利的行为。

（三）当事人的行为有滥用权利的违法性。认定是否权利滥用，主要是从行为人的利益和他人或者社会受到的损害程度的比较，根据不同情况判断。

三、滥用权利的法律后果

不同的权利滥用的后果不同，应区别对待。权利人虽滥用权利，但其原有权利并不丧失。

四、诚实信用原则和禁止权利滥用原则的关系

关于诚实信用原则和禁止权利滥用原则的关系，有不同的观点：

（一）诚实信用原则是最高原则，禁止权利滥用原则是违反诚实信用原则的效果。

（二）诚实信用原则是从主观上要求建立的权利的内在界限，禁止权利滥用原则是划出客观界限。民法就权利的行使，自主观的及客观的两方面作规定，二者的范围有时偶然一致，但其基准不同。二者有重合现象，难以绝对区分清楚，但是权利滥用有其不同于一般的违背诚实信用原则的特点。

五、权利滥用的判例

（一）故意损害邻人利益。一被告设置一段高 10.15 米，长 15.80 米，漆成黑色的木板围栏，目的是使邻人具有“监狱的感觉”，法国法院判决被告拆除该围栏。

（二）对越界建筑的处理。比利时法院认为，越界建筑侵犯邻人权利轻微，要求拆除建筑，是权利滥用；我国台湾地区也有这类判例。法国法院对侵犯地产的违法建筑减损了地产的功用的，判决拆除该建筑。

（三）被上诉人本于所有权请求上诉人拆除地上变压设备，地上变压设备一旦被拆除，高雄市都会区居民的生活将限于瘫痪，所有生产工厂均停顿。台湾地区法院判决认定被上诉人行使权利违反公共利益，应为法所不允许。

（四）某石油公司向缔约人出借一些专门的罐，借用人考虑到为避免罐体穿底，以及将罐从土中取出后恢复土地原状的费用，提出归还出借人类似的新罐，或者给付相当的价金，但是出借人拒绝了这一建议，要求归还原来出借的罐。法国法院判决认定出借人滥用权利。

（五）股东权滥用。股东对股东大会作出的决议提起撤销之诉，因股东引发的法律纠纷，使公司在很长时间内无法采取必要的经济措施。股东此举目的，是迫使公司以高出股票价值数倍的价钱来购买股东的股票，对此德国法院判决为权利滥用。在法国，对股东大会上由多数股东滥用权利所作出决定的判例非常多，也有少数股东滥用权利的判例。

相关法条：《民法典》第一百三十二条 民事主体不得滥用民事权利损害国家利益、社会公共利益或者他人

合法权益

相关法条：《民总解释》第三条 对于民法典第一百三十二条所称的滥用民事权利，人民法院可以根据权利行使的对象、目的、时间、方式、造成当事人之间利益失衡的程度等因素作出认定。

行为人以损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益为主要目的行使民事权利的，人民法院应当认定构成滥用民事权利。

构成滥用民事权利的，人民法院应当认定该滥用行为不发生相应的法律效力。滥用民事权利造成损害的，依照民法典第七编等有关规定处理。

第六节 公平原则

一、公平原则的含义

（一）公平，是指民事主体之间的利益平衡。

（二）公平原则，是指衡量当事人之间利益的标准。

（三）公平与否，应当从我国民法规范的基本精神出发，以我国现阶段的交易习惯和人们的一般观念为标准。

二、公平原则与诚实信用原则的关系

（一）联系 认定是否违反公平原则或者诚实信用原则，都是在客观上判断当事人之间的利益是否失衡。

（二）区别 公平原则主要是从客观上判断当事人之间的利益是否失衡。诚实信用原则主要是从道德观念上要求当事人应当怎样做，不应当怎样做，在人身关系方面贯彻诚实信用原则，更注重道德标准。

三、公平原则的体现

（一）当事人的权利与义务的平衡

（二）当事人承担民事责任平衡

（三）负担与风险的平衡

相关法条：《民法典》第六条 民事主体从事民事活动，应当遵循公平原则，合理确定各方的权利和义务。

第七节 公序良俗原则与绿色原则

一、公序良俗原则

（一）公序良俗原则的含义

公序良俗原则，是指民事法律行为不得违反公共秩序或者善良风俗。

（二）公共秩序与善良风俗的含义

1、公共秩序，是指社会的存在及其发展所必要的一般秩序。

（1）通常，违反强制性规定的，即为违反公共秩序。

（2）法律难以将强制性规定列举周全，公共秩序比强制性规定的外延更宽，除包括涉及公共秩序的现行法律规范外，还包括现行法律没有规定的某些情况。

2、善良风俗，是指社会的存在及其发展所必要的一般道德。

作为民法基本原则的善良风俗，是将人们应当遵守的最低限度的道德法律化，违背人们应当遵守的最低限度的道德，就是违反公序良俗原则。

3、公共秩序与善良风俗的关系

公共秩序与善良风俗的范围大致相同，有时难以区分，不过公共秩序是从社会秩序方面立论，善良风俗是由人们道德方面着眼，概括起来就是要求行为具有社会妥当性

4、社会在不断发展、人们的观念在不断变化，公共秩序和善良风俗的内涵也会随之变化。

5、适用公序良俗原则，应当以整个法律的价值体系和一般道德观念为基准，区分不同的情况，慎重裁量。

（三）违反公序良俗原则的行为

1、暴利行为，利用他人处于急迫情势、没有经验、缺乏判断力或者意志显著薄弱，以法律行为使他人为某项给付，而向其自己或者第三人许诺或者给予和该项给付明显地不相当的财产利益。

2、恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益。

3、滥用垄断地位，规定不合理的流通条件，违背流通所需要的合理的法律秩序，获得不合理的好处。

4、订立限制人身自由或者限制近亲属往来的合同。

5、以婚外同居为条件赠与财产。

6、订立借腹生子协议。

7、订立以实施犯罪行为为目的的协议。

二、绿色原则

这一原则要求民事主体在从事民事活动时，应从有利于节约资源、保护生态环境出发，以是否有利于节约资源、保护生态环境作为应否从事相关民事活动的考量。民事主体从事民事活动，造成资源浪费、生态环境破坏的，应承担相应的民事责任。

1.当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。

2.在不能确定包装方式时，出卖人应采取足以保护标的物且有利于节约资源、保护生态环境的包装方式。

3.民事主体从事民事活动，违反国家规定造成生态环境损害的，应承担相应修复和赔偿损失的民事责任。

相关法条：《民法典》第八条 民事主体从事民事活动，不得违反法律，不得违背公序良俗。

相关法条：《民法典》第九条 民事主体从事民事活动，应当有利于节约资源、保护生态环境。

第三章 民事法律关系

第一节 民事法律关系的概念与意义

一、民事法律关系的概念与特征

（一）民事法律关系的概念

1、广义的民事法律关系，是指民法调整社会关系而形成的具有法律意义的社会关系。

2、狭义的民事法律关系，是指在现实生活中形成的以民事权利和民事义务为基本内容的社会关系。

（二）民事法律关系的特征

1.民事法律关系是民法调整平等主体之间的财产关系与人身关系所形成的社会关系。

2.民事法律关系是基于民事法律事实而形成的社会关

系。

3.民事法律关系是以民事权利义务为内容的社会关系。

注意：民事法律规范是民事法律关系发生的根据，民事法律事实是民事法律关系发生的原因，民事法律关系是民事法律规范调整平等主体之间的财产关系和人身关系的结果。

二、民事法律关系的意义

（一）民事法律关系理论是打开民法殿堂的钥匙

（二）民事法律关系是处理民事案件的思维方法

三、民事法律关系与民法体系

民法是民事法律关系法，民法学是民事法律关系学。

第二节 民事法律关系的要素

一、民事法律关系要素的构成及其意义

（一）民事法律关系要素的构成

1、民事法律关系的要素，是指构成民事法律关系的必要因素。

2、民事法律关系要素的构成：主体、客体、内容。

（二）民事法律关系要素的意义

民事法律关系要素理论，对民事法律关系的成立、变更、终止的判断，对其性质及效力的认定，有以简驭繁、纲举目张的功能。

二、民事法律关系的主体

民事法律关系的主体，简称民事主体，是指参加民事法律关系，享有民事权利、负有民事义务和承担民事责任的人。

（一）我国的民事主体有自然人、法人和其他组织。在有些情况下，国家也作为民事主体，参与民事法律关系。

（二）通常称参加民事法律关系的主体为当事人。当事人中，享有权利的一方为权利主体，又称为权利人；负有义务的一方为义务主体，又称为义务人；承担责任的一方为责任主体，又称为责任人。

（三）多数民事法律关系当事人双方都既享有权利，又负有义务；既是权利主体，又是义务主体。有些民事法律关系中，一方仅为权利人，只享有权利，不承担义务；另一方仅为义务人，只承担义务，不享有权利。

（四）民事法律关系可以是双方的，也可以是多方的。每一方当事人可以是一人，也可以是两个以上的人。

（五）在不同的民事法律关系中当事人的称谓不同。

三、民事法律关系的客体

民事法律关系的客体，是指民事权利和民事义务指向的对象。

（一）民事法律关系的客体既是民事权利与民事义务的依托，也是确认民事法律关系性质的重要依据。

（二）民事法律关系的客体主要有四类：物、行为、智力成果和人身利益。

四、民事法律关系的内容

民事法律关系的基本内容是民事权利和民事义务，民事责任是维护正常的民事法律关系的保障。在发生民事责任的情况下，其内容是民事权利和民事责任。

（一）民事权利与民事义务、民事责任有些是由民事法律规范直接规定的，有些是在法定范围内由当事人协商决定的。

（二）不同的民事法律关系有不同的内容，不同的民事权利义务是不同的民事法律关系的具体表现，也是民事法律关系的性质的具体表现。从民事法律关系的内容也可以认定该项民事法律关系的性质。

第三节 民事法律事实与民事法律关系的发生、变更与消灭

一、民事法律事实

（一）民事法律事实的概念

民事法律事实，是指能够引起民事法律关系的发生、变更或者消灭的客观现象。

注意：<u>不是</u>任何事实都能成为民事法律事实，哪些事实属于民事法律关系事实，是民法上的价值判断问题。只有受民法调整，能够引起民事法律关系发生、变更或者消灭的事实才是民事法律事实。

1、有些客观现象，不会引起民事法律关系的发生、变更或者消灭，故不是民事法律事实。

2、有些客观现象则因民事法律规范的规定而成为民事法律事实。

（二）民事法律事实构成

民事法律事实构成，又称为民事法律事实结合，是指引起法律关系发生、变更或者消灭的<u>两个以上</u>的民事法律事实的总和。

1、有时民事法律关系的发生、变更或者消灭，需要有两个以上的民事法律事实。

2、有时民事法律关系的成立，除民事法律事实外，还需要与行政法律事实结合。

（三）民事法律事实的分类

1、行为

（1）概念

行为，是指人有意识的活动。人的行为是人有意识的身体动、静，<u>“动”为“作为”，“静”为“不作为”</u>，总称为“行为”。

（2）分类

A、以是否合法为标准，行为可分为合法行为和违法行为。违法行为包括侵权行为和债务不履行行为。

B、以是否以意思表示为要素为标准，行为可分为民事法律行为、准民事法律行为和事实行为。

（A）民事法律行为,是基于当事人的意思表示而发生民法上效力的表意行为。

（B）准民事法律行为，是表意行为之一种，但其效力非基于表意人的表意，而是基于法律的规定。

（C）事实行为，是指行为人没有产生一定民事法律后果的意思表示，根据法律规定发生一定民事法律后

果的行为。

• **注意**：行政行为和司法行为，有时也会发生一定的民事法律后果，例如，国家财政机关向机关法人按预算拨款、法院裁决某项财产归原告或者被告所有等。

2、非行为事实

（1）概念

非行为事实，又称自然事实，是指人的行为以外的，能够引起民事法律关系发生、变更或者消灭的事实。

（2）分类

A、事件：是指某种客观现象的发生。

B、状态：是指某种客观现象的持续。

二、民事法律关系的发生、变更与消灭

（一）民事法律关系的发生

民事法律关系的发生，是指因一定的民事法律事实出现，民事主体之间形成民事权利义务关系。

（二）民事法律关系的变更

1、概念

民事法律关系的变更，是指因一定的民事法律事实出现，原有的民事法律关系发生了变化。

（1）广义的民事法律关系的变更，包括主体变更、客体变更和内容变更。

（2）狭义的变更是指客体变更和内容变更。

2、内容

（1）主体变更

民事法律关系主体变更，是指原权利主体或者义务主体变为另一个主体。

（2）客体变更

民事法律关系客体变更，是指民事权利和民事义务所由发生的事物变化。

（3）内容变更

民事法律关系内容变更，是指民事权利义务发生变化。

（三）民事法律关系的消灭

1、概念

民事法律关系的消灭，是指因一定的民事法律事实出现，原有的民事法律关系终结。

2、内容

（1）绝对消灭

民事法律关系绝对消灭，是指民事法律关系主体的权利义务已不存在。

（2）相对消灭

民事法律关系相对消灭，主要是指民事法律关系的主体变更；客体完全变更。

第四节 民事权利、民事义务、民事责任

一、民事权利

（一）民事权利的概念

民事权利，是指民事主体实现其特定利益的法律手段。

1、民事权利是民事主体享有的特定利益。

2、民事权利是民法规定或者有权的国家机关认可的。

3、民事权利受国家强制力保障。

（二）民事权利的分类

1、财产权与人身权（又称财产权与非财产权）

以民事权利所体现的利益的性质为标准，民事权利可分为财产权与人身权。

（1）财产权

财产权是以财产利益为内容的权利。（物权、债权）

A、财产权有财产价值，可以用货币衡量。

B、财产权一般可以转让、继承，依法可以抛弃。

（2）人身权

人身权是以人身利益为内容的权利。（人格权和身份权）

A、人身权不直接体现财产利益，不能用货币衡量。

B、人身权不能放弃、转让和继承。

C、有的人身权可以在限制的范围内由他人行使。

D、在特定条件下，有些人身权的行使可能形成财产价值。

★特殊性权利：知识产权；继承权；社员权。

A 知识产权是财产权，但知识产权又有人身因素（例如著作权中的署名、发表、修改等权利）。、

B 继承权就其内容看属于财产权，而通常继承权是基于近亲属关系而取得的。

C 社员权是民法上的社团成员基于其成员地位享有的权利。（社员有参与社团的管理、监督的权利。有些社团的社员权有财产权、有些社团的社员权没有财产权。）

2、支配权、请求权、形成权和抗辩权

以民事权利的作用为标准，民事权利可分为支配权、请求权、形成权和抗辩权。

（1）支配权

A、支配权，是指权利人可以直接支配权利客体，具有排他性的权利。

B、支配权的作用

（A）从积极方面说，权利人可以直接支配其权利客体，以满足自己的利益需要，不需要他人行为的介入。

（B）从消极方面看，权利人可禁止他人妨碍其支配行为，具有排他性。

C、物权是典型的支配权，知识产权、人格权也是支配权。

（2）请求权

A、请求权，是指权利人请求他人作为或者不作为的权利。

B、请求权是基于基础权利而发生的，有基础权利，才能有请求权。

C、债权请求权是典型的、独立的请求权，债权请求权可以转让。

（3）形成权

A、形成权，是指权利人以自己的意思表示，使民事

法律关系发生、变更或消灭的权利。
B、属于形成权的有追认权、选择权、撤销权、抵销权、解除权及继承权的抛弃权等。
C、形成权由法律规定或者当事人约定，没有法律规定或者当事人约定的，当事人一方的意思表示不能使民事法律关系发生、变更或者消灭。

（4）抗辩权

A、抗辩权，是指对抗他人行使权利的权利。
B、抗辩权通常对抗的是请求权，但不限于请求权，对于其他权利（例如抵销权）的行使也可以抗辩。
C、抗辩权的分类（根据抗辩权作用的不同）
（A）永久性抗辩权，是指权利人有永久阻止他人行使权利的权利。
（B）延期性抗辩权，是指权利人在一定时期内一定条件下可以提出的抗辩权。
D、抗辩权的作用在于对抗和阻止他人行使权利，但他人的权利并不因此而消灭。
E、抗辩权的行使，以权利存在并且提出为前提。在未提出权利的情况下，抗辩权无从行使。在权利已经消灭的情况下，不适用抗辩权。
• **注意：**一方当事人否认另一方当事人权利存在，这在性质上可称为否认权，不属于抗辩权。

3、绝对权与相对权

以民事权利的效力范围为标准，民事权利可分为绝对权和相对权。
（1）绝对权
A、绝对权，又称对世权，是指无须通过义务人实施一定的行为即可实现，并可以对抗不特定人的权利。
B、物权、人格权、知识产权属于绝对权。
C、绝对权的特征
（A）权利人无须通过义务人的行为，自己可以直接实现其权利。
（B）义务主体是不特定的。
（2）相对权
A、相对权，又称为对人权，是指必须通过义务人实施一定的行为才能实现，只能对抗特定人的权利。
B、债权是典型的相对权。
C、相对权的特征
（A）权利人自己不能直接实现其权利，必须通过义务人的行为其权利才能实现。
（B）只能请求特定的人为一定行为，义务主体是特定的人。

4、主权利和从权利

以民事权利的依存关系为标准，民事权利可分为主权利和从权利。
（1）主权利
主权利是相互关联的两个民事权利中，能够独立存在的权利。
（2）从权利
从权利是相互关联的两个民事权利中，不能独立存在而从属于主权利的权利。
（3）主权利与从权利是在相关联的法律关系中相对应的概念，没有主权利，则从权利不能存在；没有从权利，无所谓主权利。说主权利能独立存在，仅指在权利有依存关系的情况下而言，因此不能笼统地说所有权、债权、人格权、身份权就是主权利。
（4）主权利与从权利的主从关系的体现
A、主权利存在，从权利才能存在。主权利因履行、抵销、免除等原因而消灭时，从权利同时消灭。
B、在一般情况下从权利不能与主权利分离而单独转让。

5、专属权和非专属权

以民事权利与主体的关系，民事权利可分为专属权和非专属权。
（1）专属权
A、专属权，是指专属于某特定民事主体的权利。
B、人格权、身份权均为专属权。
C、专属权一般不得让与和继承，但也有例外。
（2）非专属权
A、非专属权是指不属于某特定民事主体专有的权利。
B、财产权通常为非专属权，但也有专属权。
C、非专属权可以让与和继承。

6、既得权和期待权

以民事权利是否已经取得为标准，民事权利可分为既得权和期待权。
（1）既得权
既得权，是指权利人已经取得而可以实现的权利。
（2）期待权
期待权，是指将来可能取得的权利。

7、原权与救济权

以权利发生的先后及相互关系为标准，民事权利可分为原权（又称原权利）与救济权。
（1）原权
原权是原有民事法律关系中存在的权利。
（2）救济权
A、救济权是原权受到侵害或者有受到侵害的现实危险时发生的权利。
B、救济权是基于原权利而派生的权利，其目的在于救济被侵害的原权。在很多情况下，救济权是权利人请求侵权行为人或者不履行债务的人承担民事责任的权利，从学理上讲，这种请求权可被称为救济请求权。

（三）民事权利的行使

1、民事权利的行使，是指民事权利主体实现其权利的行为。
2、行使民事权利的方法有多种多样，大体上可概括为事实行为方法和民事法律行为方法两种。
3、民事权利的行使，是民事主体的自由。

4、民事主体行使民事权利应依权利的目的行使，不得滥用权利。

5、民事主体行使权利时，应当履行法律规定和当事人约定的义务。

（四）民事权利的保护

民事权利的保护，是指用民事保护方法，防止权利受到侵害，或者使受到侵害的权利得到恢复。

- 民事权利保护
  - 国家保护
  - 自我保护
    - 自卫行为
      - 正当防卫
      - 紧急避险
    - 自助行为

1、民事权利的国家保护

（1）民事权利的国家保护，又称公力救济，是指民事权利受到侵害时，由国家机关通过法定程序予以保护。

（2）国家保护民事权利是由多种机关采取多种手段完成的，经常性的是由民事权利主体提起民事诉讼，请求法院予以保护。

2、民事权利的自我保护

（1）概念

民事权利的自我保护，又称为私力救济或者自力救济，是指民事权利受到侵害时，权利人在法律规定的限度内，自己采取必要的措施保护其权利。

（2）内容

A、自卫行为

自卫行为，是当民事权利受到侵害或者有受到侵害的现实危险时，权利人采取必要的措施，以防止损害的发生或者扩大。

（A）正当防卫

a、概念

正当防卫，是指为了保护本人或者他人的民事权益或公共利益，对于现实的不法侵害采取的防卫行为。

b、条件

（a）有不法侵害。

（b）须为现实的不法侵害，不是过去或将来的。

（c）正当防卫只能针对不法侵害人，不能对侵害人以外的人实施。

（d）防卫的目的是为了保护本人或者他人的合法权益或者公共利益。

（e）正当防卫不得超过必要的限度。

★刑法上的正当防卫和民法上的正当防卫

刑法上的正当防卫和民法上的正当防卫的区别主要体现在对防卫过当的判断上。在民事责任方面，正当防卫超过必要限度造成不应有的损害的，应当承担相应的民事责任。在刑事责任方面，要求明显超过必要限度造成重大损害的，应当负刑事责任，强调了“明显”和“重大”两个条件。

（B）紧急避险

a、概念

紧急避险，又称为紧急避难，是为了避免本人或者他人的民事权益或者公共利益受到急迫的危险所为的行为。

b、条件

（a）须有急迫现实的危险存在。

（b）须是关系到本人或者他人的民事权益或者公共利益的急迫的危险。

（c）避险的行为不得超过危险所能造成损害的程度。

B、自助行为

（A）概念

自助行为，是指权利人在符合法定条件时，通过对他人财物加以扣留、人身自由施以拘束等措施从而保护自己合法权益的行为。

（B）条件

a、合法权益受到侵害，即自助行为人是为了保护自己的合法权益。

b、情况紧迫且不能及时获得国家机关保护，不立即采取措施将使其合法权益受到难以弥补的损害。

c、必须是在保护自己合法权益的必要范围内采取合理的措施。

d、应当立即请求有关国家机关处理。

（C）效果

a、如果构成自助行为，自助行为人无需就其采取的扣留侵权人的财物等合理措施而承担侵害民事权益的侵权责任。

b、如果不构成自助行为，则需要承担侵权责任。

c、即便行为人的行为构成自助行为，如果其采取的措施不当，造成他人损害的，也应当承担侵权责任。（采取的措施不当,主要是指超出维护自己合法权益的必要范围而采取措施，具体应当根据案件的具体事实、受害人被保护的权益、受害人有无选择其他措施的可能性、该措施对侵权人权益的影响程度等加以判断。）

相关法条：《民法典》第一百八十一条 因正当防卫造成损害的，不承担民事责任。

正当防卫超过必要的限度，造成不应有的损害的，正当防卫人应当承担适当的民事责任。

相关法条：《民法典》第一百八十二条 因紧急避险造成损害的，由引起险情发生的人承担民事责任。

危险由自然原因引起的，紧急避险人不承担民事责任，可以给予适当补偿。

紧急避险采取措施不当或者超过必要的限度，造成不应有的损害的，紧急避险人应当承担适当的民事责任。

相关法条：《民法典》第一百八十三条 因保护他人民事权益使自己受到损害的，由侵权人承担民事责任，

受益人可以给予适当补偿。没有侵权人、侵权人逃逸或者无力承担民事责任，受害人请求补偿的，受益人应当给予适当补偿。

相关法条：《民法典》第一千一百七十七条 合法权益受到侵害，情况紧迫且不能及时获得国家机关保护，不立即采取措施将使其合法权益受到难以弥补的损害的，受害人可以在保护自己合法权益的必要范围内采取扣留侵权人的财物等合理措施；但是，应当立即请求有关国家机关处理。

受害人采取的措施不当造成他人损害的，应当承担侵权责任。

二、民事义务

（一）民事义务的概念与特征

民事义务，是指法律规定或者当事人依法约定，义务人为一定的行为或者不行为，以满足权利人的利益的法律约束手段。

1、民事义务是由民事法律规定或者当事人依法约定的。

2、民事义务是为了满足权利人利益的法律约束手段。

（二）民事义务的分类

1、法定义务与约定义务

以民事义务发生的根据为标准，民事义务可分为法定义务和约定义务。

（1）法定义务

A、法定义务，是指民法规定的民事主体应负的义务。

B、物权、人格权、知识产权属于绝对权，法律一般不直接规定义务人的义务，但在相关的法律规定中可以理解义务人对绝对权有不得侵害的义务，即不作为义务。

（2）约定义务

A、约定义务，是由当事人协商约定的义务。

B、约定义务主要体现在合同关系中，约定的义务不得超出法律规定的范围。

2、作为义务和不作为义务

以民事义务人行为的方式为标准，可分为作为义务和不作为义务。

（1）作为义务

作为义务，又称为积极义务，是指义务人应作出一定积极行为的义务。

（2）不作为义务

不作为义务，又称为消极义务，是指义务人应为消极行为或者容忍他人的行为。

注意：

1、对世义务和对人义务

（1）对世义务，也称为绝对义务，是指绝对权的义务人对权利人所负担的义务，事实上对所有的绝对权人都负有这样的义务。

（2）对人义务，也称为相对义务，是相对权的义务人对特定的权利人所负担的义务，其义务仅仅对相对的权利人承担，对他人不负有这样的义务。

2、主给付义务和附随给付义务

（1）主给付义务，也叫做主义务，是指债权的关系所固有的、必备的、直接影响到债的目的实现的义务。

（2）附随给付义务，是指合同当事人依照法律或者依照诚实信用原则、交易习惯以及合同约定产生的义务。

3、真正义务和不真正义务

（1）真正义务，是指违反该义务能够发生民事责任的民事义务。

（2）不真正义务，是指虽然某人依法应当实施某行为，但在义务人不履行时，相对人也不能请求其承担民事责任，而只是使其遭受权利丧失或减损的不利后果。

三、民事责任

（一）民事责任的概念与特征

1、民事责任的概念

民事责任，是指民事主体违反民事义务应当承担的民事法律后果。

2、民事责任的特征

（1）民事责任是当事人一方对他方承担的责任。

（2）民事责任既有过错责任，又有无过错责任。

（3）民事责任主要是为了补偿权利人所受损失和恢复民事权利的圆满状态。

（4）民事责任的内容可以由当事人在法律允许的范围内协商。

（5）民事责任有独立性和实现上的优先性。

（二）民事责任与民事义务的区别

1、性质不同

义务是“当为”，反映正常的社会秩序。当为而不为产生责任。义务是责任之因，责任是违反义务之果。责任反映不正常的社会秩序，责任人承担责任是恢复正常的社会秩序。

2、功能不同

义务是权利主体实现权利的必要条件，通常权利人实现权利与义务人履行义务同时存在，二者相辅相成。责任是促使义务人履行义务，保证权利人实现权利的辅助条件。

3、拘束力不同

义务和责任均具有拘束力，但是拘束的程度和方式不同。义务的拘束力是指义务人应当履行义务，不是可履行可不履行；不履行义务或者侵害他人的权利，义务人就变为责任人，必要时司法机关可以对责任人采取强制措施。

（三）民事责任的分类

1、财产责任与非财产责任

（1）概念

A、财产责任，是指以一定的财产为内容的责任。

B、非财产责任，是指不具有财产内容的责任。

（2）分类意义

侵害财产权的，承担财产责任，一般不承担非财产责任。侵害人身权的，造成财产损失的，承担财产责任，还要依法承担非财产责任。

2、违约责任、侵权责任和其他责任

（1）概念

A、违约责任，是指因违反合同约定的义务或者违反合同法规定的义务而产生的责任。

B、侵权责任，是指因侵害他人的财产权益与人身权益产生的责任。

C、其他责任，是指违约责任与侵权责任之外的民事责任，包括基于不当得利和无因管理产生的责任，以及缔约过失责任和基于后合同义务产生的责任等。

（2）分类意义

责任发生的事由不同、责任的构成要件、责任方式也有所不同。

3、无限责任与有限责任

（1）概念

A、无限责任，是指责任人以自己的全部财产承担责任。

B、有限责任，是指责任人以其部分财产承担责任。

（2）分类意义

民事责任以无限责任为原则，有限责任为例外，有限责任适用于法律有特别规定的场合。

4、单独责任与共同责任

（1）概念

A、单独责任，是指由一个民事主体独立承担的民事责任。

B、共同责任，是指两人以上的民事主体共同承担的责任。

根据各责任人之间的共同关系，可将共同责任分类为按份责任、连带责任和补充责任。

（A）按份责任，是指责任人一方主体为多数，各自按照一定份额承担责任。

（B）连带责任，是指责任人一方主体为多数，各个责任人对外不分份额，向权利人承担全部责任。（在共同责任人内部，仍然存在着责任份额的划分）。在权利人提出请求时，各个责任人不得以超过自己应承担的部分为由而拒绝，承担超过自己份额的责任人有权向其他责任人请求予以补偿。

（C）补充责任，是指在责任人的财产不足以承担其应负的民事责任时，由有关的人对不足部分予以补充的责任。

（2）分类意义

按份责任、连带责任和补充责任承担责任的范围不同。连带责任是为了充分保护权利人的权利，加重了责任人的负担，因此连带责任的承担必须有<u>法律规定或者当事人约定</u>。补充责任也需要有<u>法律规定或者当事人约定</u>。

5、过错责任、无过错责任、公平责任

A、过错责任，是指行为人给他人造成损害，有过错才承担责任，无过错就不承担责任。

B、无过错责任，是指行为人只要给他人造成损害，不问其主观上是否有过错，都应当承担责任。

C、公平责任，是指当事人对造成损害都没有过错，又不能根据无过错责任原则由加害人承担赔偿责任，但是如果不赔偿受害人的损失显失公平的情况下，可以根据实际情况，由当事人分担民事责任。

注意：哪些情况适用过错责任，哪些情况适用无过错责任，是立法政策问题，在不同的时期，立法政策可能有变动。

（四）承担民事责任的方式、民事责任的承担与免除

1、承担民事责任的方式

（1）停止侵害

（2）排除妨碍

（3）消除危险

（4）返还财产

（5）恢复原状

（6）修理、重作、更换

（7）继续履行

（8）赔偿损失

（9）支付违约金

（10）消除影响、恢复名誉

（11）赔礼道歉

注意：《民法典》规定的责任方式具有开放性，在条件成熟的时候可能增加其他责任方式。

2、民事责任的承担

（1）各种民事责任形式，可以单独适用，也可以合并适用。单独适用还是合并适用，需要根据具体情况而定。

（2）根据区分责任与制裁的原理和民事责任的特征，民事责任承担有自动承担、请求承担和强制承担三种途径。

A、自动承担是指责任人自动向权利人承担责任。

B、请求承担是指责任人向责任人提出请求以后，责任人向权利人承担责任。

（2）根据区分责任与制裁的原理和民事责任的特征，民事责任承担有自动承担、请求承担和强制承担三种途径。

A、自动承担是指责任人自动向权利人承担责任。

B、请求承担是指责任人向责任人提出请求以后，责任人向权利人承担责任。

3、民事责任的免除

（1）具有法律规定的免责事由的，免除民事责任。

（2）根据民法的自愿原则，权利人可以放弃追究责任人的责任。

相关法条：《民法典》第一百零九条 自然人的人身自由、人格尊严受法律保护。

相关法条：《民法典》第一百一十条 自然人享有生命权、身体权、健康权、姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权、婚姻自主权等权利。

法人、非法人组织享有名称权、名誉权、荣誉权等权利。

相关法条：《民法典》第一百一十一条 自然人的个人信息受法律保护。任何组织和个人需要获取他人个人信息的，应当依法取得并确保信息安全，不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息，不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息。

相关法条：《民法典》第一百一十二条 自然人因婚姻、家庭关系等产生的人身权利受法律保护。

相关法条：《民法典》第一百一十三条 民事主体的财产权利受法律平等保护。

相关法条：《民法典》第一百一十四条 民事主体依法享有物权。

物权是权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利，包括所有权、用益物权和担保物权 。

相关法条：《民法典》第一百一十五条 物包括不动产和动产。法律规定权利作为物权客体的，依照其规定。

相关法条：《民法典》第一百一十六条 物权的种类和内容，由法律规定。

相关法条：《民法典》第一百一十七条 为了公共利益的需要，依照法律规定的权限和程序征收、征用不动产或者动产的，应当给予公平、合理的补偿。

相关法条：《民法典》第一百一十八条 民事主体依法享有债权。

债权是因合同、侵权行为、无因管理、不当得利以及法律的其他规定，权利人请求特定义务人为或者不为一定行为的权利。

相关法条：《民法典》第一百一十九条 依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。

相关法条：《民法典》第一百二十条 民事权益受到侵害的，被侵权人有权请求侵权人承担侵权责任。

相关法条：《民法典》第一百二十一条 没有法定的或者约定的义务，为避免他人利益受损失而进行管理的人，有权请求受益人偿还由此支出的必要费用。

相关法条：《民法典》第一百二十二条 因他人没有法律根据，取得不当利益，受损失的人有权请求其返还不当利益。

相关法条：《民法典》第一百二十三条 民事主体依法享有知识产权。

知识产权是权利人依法就下列客体享有的专有的权利：

（一）作品；

（二）发明、实用新型、外观设计；

（三）商标；

（四）地理标志；

（五）商业秘密；

（六）集成电路布图设计；

（七）植物新品种；

（八）法律规定的其他客体。

相关法条：《民法典》第一百二十四条 自然人依法**享有**继承权。

自然人合法的私有财产，可以依法继承。

相关法条：《民法典》第一百二十五条 民事主体依法享有股权和其他投资性权利。

相关法条：《民法典》第一百二十六条 民事主体享有法律规定的其他民事权利和利益。

相关法条：《民法典》第一百二十七条 法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定。

相关法条：《民法典》第一百二十八条 法律对未成年人、老年人、残疾人、妇女、消费者等的民事权利保护有特别规定的，依照其规定。

相关法条：《民法典》第一百二十九条 民事权利可以依据民事法律行为、事实行为、法律规定的事件或者法律规定的其他方式取得。

相关法条：《民法典》第一百三十条 民事主体按照自己的意愿依法行使民事权利，不受干涉。

相关法条：《民法典》第一百三十一条 民事主体行使权利时，应当履行法律规定的和当事人约定的义务。

相关法条：《民法典》第一百七十六条 民事主体依照法律规定和当事人约定，履行民事义务，承担民事责任。

相关法条：《民法典》第一百七十七条 二人以上依法承担按份责任，能够确定责任大小的，各自承担相应的责任；难以确定责任大小的，平均承担责任。

相关法条：《民法典》第一百七十八条 二人以上依法承担连带责任的，权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任。

连带责任人的责任份额根据各自责任大小确定；难以确定责任大小的，平均承担责任。实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，有权向其他连带责任人追偿。

连带责任，由法律规定或者当事人约定。

相关法条：《民法典》第一百七十九条 承担民事责任的方式主要有：

（一）停止侵害；

（二）排除妨碍；

（三）消除危险；

（四）返还财产；

（五）恢复原状；

（六）修理、重作、更换；

（七）继续履行；

（八）赔偿损失；

（九）支付违约金；

（十）消除影响、恢复名誉；

（十一）赔礼道歉。

法律规定惩罚性赔偿的，依照其规定。

本条规定的承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。

相关法条：《民法典》第一百八十条 因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。

不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

相关法条：《民法典》第一百八十四条 因自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的，救助人不承担民事责任。

相关法条：《民法典》第一百八十五条 侵害英雄烈士等的姓名、肖像、名誉、荣誉，损害社会公共利益的，应当承担民事责任。

相关法条：《民法典》第一百八十六条 因当事人一方的违约行为，损害对方人身权益、财产权益的，受损害方有权选择请求其承担违约责任或者侵权责任。

相关法条：《民法典》第一百八十七条 民事主体因同一行为应当承担民事责任、行政责任和刑事责任的，承担行政责任或者刑事责任不影响承担民事责任；民事主体的财产不足以支付的，优先用于承担民事责任。

相关法条：《民总解释》第三十条 为了使国家利益、社会公共利益、本人或者他人的人身权利、财产权利以及其他合法权益免受正在进行的不法侵害，而针对实施侵害行为的人采取的制止不法侵害的行为，应当认定为民法典第一百八十一条规定的正当防卫。

相关法条：《民总解释》第三十一条 对于正当防卫是否超过必要的限度，人民法院应当综合不法侵害的性质、手段、强度、危害程度和防卫的时机、手段、强度、损害后果等因素判断。

正当防卫没有超过必要限度的，人民法院应当认定正当防卫人不承担责任。正当防卫超过必要限度的，人民法院应当认定正当防卫人在造成不应有的损害范围内承担部分责任;实施侵害行为的人请求正当防卫人承担全部责任的，人民法院不予支持。

实施侵害行为的人不能证明防卫行为造成不应有的损害，仅以正当防卫人采取的反击方式和强度与不法侵害不相当为由主张防卫过当的，人民法院不予支持。

相关法条：《民总解释》第三十二条 为了使国家利益、社会公共利益、本人或者他人的人身权利、财产权利以及其他合法权益免受正在发生的急迫危险，不得已而采取紧急措施的，应当认定为民法典第一百八十二条规定的紧急避险。

相关法条：《民总解释》第三十三条 对于紧急避险是否采取措施不当或者超过必要的限度，人民法院应当综合危险的性质、急迫程度、避险行为所保护的权益以及造成的损害后果等因素判断。

经审理，紧急避险采取措施并无不当且没有超过必要限度的，人民法院应当认定紧急避险人不承担责任。紧急避险采取措施不当或者超过必要限度的，人民法院应当根据紧急避险人的过错程度、避险措施造成不应有的损害的原因力大小、紧急避险人是否为受益人等因素认定紧急避险人在造成的不应有的损害范围内承担相应的责任。

相关法条：《民总解释》第三十四条 因保护他人民事权益使自己受到损害，受害人依据民法典第一百八十三条的规定请求受益人适当补偿的，人民法院可根据受害人所受损失和已获赔偿的情况、受益人受益的多少及其经济条件等因素确定受益人承担的补偿数额。

第二分编 民事法律关系主体

第四章 自然人

第一节自然人的民事权利能力

一、自然人的概念

自然人是基于自然规律出生而享有法律人格的人。

二、自然人民事权利能力的概念

（一）民事权利能力，是指民事主体依法享有民事权利和承担民事义务的资格。

（二）自然人的民事权利能力，是指自然人依法享有民事权利和承担民事义务的资格。

自然人民事权利能力与民事权利的关系

1、民事权利能力与民事权利的联系

民事权利能力是取得民事权利的资格和前提条件，它为民事主体取得民事权利提供可能性；民事权利是凭借民事权利能力所获得的结果，是权利能力的具体体现。

2、民事权利能力与民事权利的区别

（1）民事权利能力包括取得民事权利和承担民事义务两方面的内容，而民事权利只具有权利这一单方面的内容，不包括民事义务。

（2）民事权利能力是一种抽象的、客观性的能力，即民事权利能力仅仅是法律赋予自然人作为民事主体的资格，无论自然人是否参与具体的民事法律关系，民事主体都享有此种资格；民事权利是一种具体的、主观性的权利，即民事权利是民事主体已经实际取得的现实性的权利，民事权利只存在于自然人已经参加的具体的民事法律关系中，如果未能参加某种民事法律关系，就不可能享有民事权利。

（3）自然人的民事权利能力始于出生、终于死亡，即终身享有。而部分民事权利只在特定的期间内享有，即民事权利具有期限性。

（4）民事权利能力与自然人的人身不能分离，权利能力不具有让与性，民事权利除人身权以外的其他权利，可以转让或抛弃。

（5）自然人不仅享有现行民法规定的权利的能力，

而且享有将来制定的法律所规定的权利的能力，民事权利只限于已经取得的权利，不包括将来取得的权利。

三、自然人民事权利能力的开始

（一）自然人的民事权利能力始于出生。

因出生这一自然事实的完成，自然人当然取得民事权利能力，而无需履行任何法定手续。

（二）关于自然人出生时间的认定，曾有阵痛说、一部产出说、全部产出说、断带说、泣声说、独立呼吸说等多种学说。通说认为，胎儿脱离母体并开始独立生存的时间作为出生的时间。（现代医学不以呼吸行为的开始而以生命特征的存在作为生存的证明。）

（三）自然人的出生时间，以出生证明记载的时间为准；没有出生证明的，以户籍登记或者其他有效身份登记记载的时间为准。有其他证据足以推翻以上记载时间的，以该证据证明的时间为准。

四、胎儿利益的保护

（一）对于保护胎儿利益的立法例

1、概括保护主义（总括保护主义）：胎儿以将来非死产者为限，视为已出生。

2、列举保护主义（个别保护主义）：对于胎儿有重要事项如继承权、损害赔偿请求权等列举规定的情况下，视为已出生。

3、绝对主义：胎儿不具有民事权利能力。

（二）我国规定

涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的，胎儿视为具有民事权利能力。但是胎儿娩出时为死体的，其民事权利能力自始不存在。

1、涉及胎儿利益保护的，胎儿视为具有民事权利能力的意义在于，胎儿视为民法上的自然人，胎儿视为民事主体。

（1）保护胎儿的遗产继承利益，胎儿享有继承权。

（2）保护胎儿的赠与利益。

2、胎儿娩出时为死体的，其民事权利能力自始不存在。其法律意义在于：

（1）保留的遗产份额，由被继承人的法定继承人继承。

（2）接受赠与的财产，如已经由死产胎儿的父母占有或控制的，其父母应予返还，赠与人也可依不当得利主张返还；如赠与财产未转移给死产胎儿父母的，死产胎儿的父母不享有赠与财产的请求权。

五、自然人民事权利能力的终止

自然人民事权利能力终于死亡。

（一）生理死亡

1、生理死亡，又称为自然死亡、真实死亡或者绝对死亡，是指自然人生命的终结。

2、我国民事立法没有对自然死亡的时间标准作出规定，对于生理死亡时间的确定，有不同的学说。我国通常的经验是以心跳停止、呼吸停止及瞳孔放大为标准。

3、自然人的死亡时间，以死亡证明记载的时间为准；没有死亡证明的，以户籍登记或者其他有效身份登记记载的时间为准。有其他证据足以推翻以上记载时间的，以该证据证明的时间为准。

（二）宣告死亡

1、宣告死亡，是指通过法定程序确定失踪人死亡。

2、被宣告死亡的人，人民法院宣告死亡的判决作出之日视为其死亡的日期；因意外事件下落不明宣告死亡的，意外事件发生之日视为其死亡的日期。

3、被宣告死亡人的民事主体资格消灭。如果被宣告死亡人实际上还活着，则应视为其权利能力仍然存在。

（三）自然人死亡后的利益保护

1、肯定说：自然人的民事权利能力终于死亡，这只是一般性规定，对此存在例外情况，但这种例外的存在是以法律规定为限的。

2、否定说：自然人死亡则其民事权利能力终止。对死者某些权利的维护，在理论上又有些权利仍然存续说、遗族利益维护说、社会利益维护说、遗族利益与社会利益共同维护说、遗族利益与有关人员利益维护说、死者人格利益延伸说等。

相关法条：《民法典》第九百九十四条，死者的姓名、肖像、名誉、荣誉、隐私、遗体等受到侵害的，其配偶、子女、父母有权依法请求行为人承担民事责任；死者没有配偶、子女且父母已经死亡的，其他近亲属有权依法请求行为人承担民事责任。

相关法条：《民法典》第十三条 自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力，依法享有民事权利，承担民事义务。

相关法条：《民法典》第十四条 自然人的民事权利能力一律平等。

相关法条：《民法典》第十五条 自然人的出生时间和死亡时间，以出生证明、死亡证明记载的时间为准；没有出生证明、死亡证明的，以户籍登记或者其他有效身份登记记载的时间为准。有其他证据足以推翻以上记载时间的，以该证据证明的时间为准。

相关法条：《民法典》第十六条 涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的，胎儿视为具有民事权利能力。但是胎儿娩出时为死体的，其民事权利能力自始不存在。

相关法条：《民总解释》第四条 涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护，父母在胎儿娩出前作为法定代理人主张相应权利的，人民法院依法予以支持。

第二节 自然人的民事行为能力

一、自然人民事行为能力的概念

自然人的民事行为能力，是指自然人能以自己的行为享有民事权利、承担民事义务的资格。

（一）行为能力与意思能力

1、意思能力，是指自然人可以判断自己的行为的法律后果的能力。

2、民事行为能力以意思能力为基础。

意思能力与行为能力的关系

1、如果将意思能力理解为一般的、抽象的辨认行为后果的能力，则意思能力是行为能力的基础，只有具备意思能力的人，才能赋予其行为能力，故意思能力自然是行为能力的要件，其表现为：年龄为判断自然人有无识别行为后果之能力的基本标准，但成年人如不具有意思能力（精神病人等），则仍然不具有行为能力，此即所谓"法定条件"（年龄）与"天然条件"（意思能力）共同作为行为能力条件的理由。（瑞士、法国）

2、如果将意思能力理解为实施具体的法律行为时之辨认行为后果的能力，则被一般认定为有行为能力即有意思能力的人，完全有可能因酗酒、吸毒等原因而于实施行为时不具有意思能力。这就是认为欠缺意思能力不等于无行为能力的理由。（德国、我国台湾地区）

（二）行为能力与责任能力

1、责任能力，又称为不法行为能力，民事责任能力，是指行为人对民事违法行为承担民事责任的能力。

2、民事责任能力包括侵权责任能力和债务不履行责任能力。我国没有明文规定责任能力，通常讲的民事责任能力一般是指侵权责任能力。

3、在我国，完全行为能力人有责任能力，无行为能力人和限制行为能力人没有责任能力。

★行为能力与责任能力关系的学说

1、民事行为能力有广义和狭义之分，广义的民事行为能力包括合法行为能力和违法行为能力；狭义的民事行为能力是指合法行为能力。

2、民事行为能力包括违法行为能力。（通说）

3、违法行为能力是责任能力，不属于行为能力的范畴。

二、自然人民事行为能力的种类

依《民法典》规定，将自然人的民事行为能力分为三类：完全民事行为能力、限制民事行为能力、无民事行为能力。这样划分的基础是智力状态，即意思能力，划分的基本标准是年龄与精神状况。这样划分的意义在于保护无民事行为能力和限制民事行为能力人的利益，维护交易安全。

（一）完全民事行为能力（有行为能力）

1、18 周岁以上的自然人。（成年人）

2、十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的。（视为）

以自己的劳动收入为主要生活来源，是指能够以自己的劳动收入维持当地群众一般生活水平。（《民通意见》）

（二）限制民事行为能力

1、限制民事行为能力人的类型

（1）8 周岁以上的未成年人。

（2）不能完全辨认自己行为的成年人。

2、限制民事行为能力人的行为能力所受限制的范围

（1）限制民事行为能力人只能进行与其年龄、智力相适应的民事法律行为，其他民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人的同意、追认。

限制民事行为能力人实施的民事法律行为是否与其年龄、智力、精神健康状况相适应，人民法院可以从行为与本人生活相关联的程度，本人的智力、精神健康状况能否理解其行为并预见相应的后果，以及标的、数量、价款或者报酬等方面认定。

（2）限制民事行为能力人可以独立实施纯获利益的民事法律行为。（奖励、赠与、报酬等）

（三）无民事行为能力

1、无民事行为能力人的类型

（1）不满 8 周岁的未成年人。

（2）不能辨认自己行为的成年人。

2、无民事行为能力人的行为能力所受限制的范围

无民事行为能力人的民事活动，由其法定代理人代理进行。

• **注意**：在实践中，不满 8 周岁的未成年人进行与他的年龄、智力相适应的民事活动，根据日常生活习惯，应认定其民事行为能力的效力。

相关法条：《民法典》第十七条 十八周岁以上的自然人为成年人。不满十八周岁的自然人为未成年人。

相关法条：《民法典》第十八条 成年人为完全民事行为能力人，可以独立实施民事法律行为。

十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人。

相关法条：《民法典》第十九条 八周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人，实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认，但是可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为。

相关法条：《民法典》第二十条 不满八周岁的未成年人为无民事行为能力人，由其法定代理人代理实施民事法律行为。

相关法条：《民法典》第二十一条 不能辨认自己行为的成年人为无民事行为能力人，由其法定代理人代理实施民事法律行为。

八周岁以上的未成年人不能辨认自己行为的，适用前款规定。

相关法条：《民法典》第二十二条 不能完全辨认自己行为的成年人为限制民事行为能力人，实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认，但是可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其智力、精神健康状况相适应的民事法律行为。

相关法条：《民总解释》第五条 限制民事行为能力人

实施的民事法律行为是否与其年龄、智力、精神健康状况相适应，人民法院可以从行为与本人生活相关联的程度，本人的智力、精神健康状况能否理解其行为并预见相应的后果，以及标的、数量、价款或者报酬等方面认定。

相关法条：《民法典》第二十三条 无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人。

相关法条：《民法典》第二十四条 不能辨认或者不能完全辨认自己行为的成年人，其利害关系人或者有关组织，可以向人民法院申请认定该成年人为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人。

被人民法院认定为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的，经本人、利害关系人或者有关组织申请，人民法院可以根据其智力、精神健康恢复的状况，认定该成年人恢复为限制民事行为能力人或者完全民事行为能力人。

本条规定的有关组织包括：居民委员会、村民委员会、学校、医疗机构、妇女联合会、残疾人联合会、依法设立的老年人组织、民政部门等。

第三节 监护

一、监护的概念与设立监护的目的

（一）监护的概念

监护是对未成年人和不能辨认自己行为或不能完全辨认自己行为的成年人（无行为能力人和限制行为能力人）的人身、财产及其他合法权益进行监督和保护的一种民事法律制度。

注意：履行监督和保护职责的人，称为监护人；被监督和保护的人，称为被监护人。

（二）监护与亲权

我国《民法典》未规定亲权，《民法典》仅设监护制度，父母为法定监护人。

★监护与亲权：亲权是父母对未成年子女以教养保护为目的，在人身和财产方面为避免他人侵害所享有的权利。它与监护不同，二者的区别体现在：

第一，亲权是一种身份权，是因为父母与子女间的身份关系而自然发生；监护是一种法定权，是法律为保护不完全行为能力人所赋予监护人的权利和义务的统一体；

第二，亲权只适用于未成年人，而监护则适用于未成年人和成年人；第三，亲权人只限于未成年人的父母，而负有监护职责的主体不局限于父母。

（三）监护设置的目的

设置监护的目的是保护无行为能力人和限制民事行为能力人的合法权益，进而利于社会秩序的稳定。

（四）监护的性质

监护性质是职责。监护职责既是监护人的职权，又是监护人的义务和责任。

二、监护人的设立

依照《民法典》的规定，监护的设立方式包括：

1、法定监护（由法律直接规定无民事行为能力人和限制民事行为能力人的监护人。）

2、遗嘱监护（是父母通过遗嘱的方式为未成年人指定监护人。）

3、协议监护（具有监护资格的人之间通过协议确定监护人。）

4、指定监护（没有法定监护人或者遗嘱监护人时，由法院或者有权指定监护人的机关指定监护人。）

5、临时监护（被监护人指定监护人前，由被监护人住所地的居民委员会、村民委员会、法律规定的有关组织或者民政部门担任临时监护人。）

（一）为未成年人设立监护人

1、父母为未成年人的当然法定监护人

（1）监护关系因子女出生而开始。

（2）父母分居或者父母离异，其监护人的资格不受影响。但父母一方或者双方作为监护人对未成年人明显不利的，人民法院可以取消父母一方或者双方担任监护人的资格。

（3）父母因正当理由，不能亲自履行监护职责的，实践中也允许父母委托他人代为履行部分或者全部监护职责，但父母仍为法定监护人。

2、除父母之外的未成年人的法定监护人

未成年人的父母双亡或者丧失监护能力或者被取消监护人资格的，由下列有监护能力的人按顺序担任监护人：（1）祖父母、外祖父母；（2）兄姐。

3、其他愿意担任监护人的个人或组织担任监护人

（1）未成年人的父母双亡，又没有祖父母、外祖父母以及成年兄、姐的，由其他愿意担任监护人的个人或组织担任监护人。

（2）其他愿意担任监护人的个人或组织担任监护人除应具有监护能力外，还应具备两个条件：一是他们愿意担任监护人；二是应得到未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门的同意。

4、指定未成年人的监护人

（1）指定未成年人的监护人，是指定未成年人父母之外的人担任监护人。

（2）指定未成年人的监护人在两种情况下发生，一是争当未成年人的监护人；二是都不愿担任监护人。

（3）有权指定未成年人监护人的有关组织是未成年人的住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门。指定监护人的原则是：有利于被监护人的成长。当事人不服上述组织指定的，可向人民法院提起诉讼。当事人对担任监护人有争议的，也可以直接向人民法院提起诉讼，由人民法院按照有利于被监护人成长的原则进行指定。

（4）指定监护人可指定一人，也可以指定数人。

（5）监护人被指定后不得擅自变更，擅自变更的，不免除被指定的监护人的责任。

5、有关组织担任未成年人的监护人

没有依法具有监护资格的人的，监护人由民政部门担任，也可以由具备履行监护职责条件的被监护人住所地的居民委员会、村民委员会担任。

6、未成年人的监护人的变更

（1）未成年人的监护人的变更原因主要有：

A、监护人丧失了监护能力。

B、监护人不履行监护职责。（实施严重损害被监护人身心健康行为、怠于履行监护职责，或者无法履行监护职责并且拒绝将监护职责部分或者全部委托给他人，导致被监护人处于危困状态的、实施严重侵害被监护人合法权益的其他行为的。）

C、在法律允许的情况下，监护人之间也可以签订变更协议，更换监护人。

（2）变更未成年人监护人的目的在于保护未成年人的合法权益。

（二）为无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人设立监护人

1、法定监护人

（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人的法定监护人的范围和顺序是：

A、配偶

B、父母、子女

C、其他近亲属

（2）其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意（其他个人或者组织担任无民事行为能力或者限制民事行为能力人的成年人的监护人，一是坚持自愿原则，而非法定义务，二是应得到被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意）

2、有关组织担任监护人

没有上述监护人，或者上述监护人均丧失了监护能力的，则由民政部门担任监护人，也可以由具备履行监护职责条件的被监护人住所地的居民委员会、村民委员会担任监护人。

3、无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人的指定监护人

（1）对监护人的确定有争议的，由被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门指定监护人，有关当事人对指定不服的，可以向人民法院申请指定监护人；有关当事人也可以直接向人民法院申请指定监护人。

（2）居民委员会、村民委员会、民政部门或者人民法院应当尊重被监护人的真实意愿，按照最有利于被监护人的原则在依法具有监护资格的人中指定监护人。

（三）成年监护

1、成年监护属于约定监护的范畴，是指具有完全民事行为能力的成年人，与他人书面约定在其丧失民事行为能力或者部分丧失民事行为能力时，由该他人担任监护人。

2、对于成年监护，监护人与被监护人之间的权利义务由监护协议确定。

3、监护人可为被监护人选定的近亲属或者愿意承担监护责任的非亲属自然人、有关组织。

4、监护人的职责、监护人资格的撤销依照监护协议以外，还可参照法定监护处理。

三、监护人的消极资格

监护人的消极资格，是指不得担任监护人的人。

（一）禁治产人、准禁治产人

我国未规定禁治产人、准禁治产人的概念。

（二）被判处刑罚的人、失踪人

我国对此未作规定。

（三）破产人

我国对此未作规定。

（四）外国人

我国对此未作规定。

（五）法人

我国《民法典》规定，未成年人、精神病人住所地的居民委员会、村民委员会或民政部门可为监护人。

四、监护人的职责

（一）保护被监护人的身体健康

（二）照顾被监护人的生活

（三）对被监护人进行管理和教育

（四）保护和管理被监护人的财产

1、监护人应当妥善管理和保护被监护人的财产，对被监护人应得的合法收益都应依法保护。

2、对于被监护人财产的经营和处分，监护人应尽善良管理人的注意。

3、非为被监护的利益，监护人不得处分其财产。

（五）代理被监护人进行民事活动

1、被监护人为无民事行为能力人的，其全部民事活动由监护人代理。

2、被监护人为限制民事行为能力人的，可以进行与他的年龄、智力相适应或者与他人精神状况相适应的民事活动；其他民事活动由他的法定代理人代理或者征得他的法定代理人的同意进行。

（六）代理被监护人进行诉讼

在被监护人的合法权益受到侵害或者与他人发生争议时，监护人应当代理被监护人进行诉讼，以维护其合法权益。

（七）监护人应当依法承担民事责任

1、无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，由监护人承担侵权责任。监护人尽到监护职责的，可以减轻其侵权责任。有财产的无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，从本人财产中支付赔偿费用；不足部分，由监护人赔偿。

2、无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害，监护人将监护职责委托给他人的，监护人应

当承担侵权责任；受托人有过错的，承担相应的责任。

五、监护人资格的撤销

（一）撤销监护人资格的事由

1、实施严重损害被监护人身心健康行为的。

2、怠于履行监护职责，或者无法履行监护职责并且拒绝将监护职责部分或者全部委托给他人，导致被监护人处于危困状态的。

3、实施严重侵害被监护人合法权益的其他行为的。

（二）撤销监护人的程序

经有关人员或组织申请并经人民法院依法作出撤销裁决。（具有申请资格的有关人员和有关单位是指其他依法具有监护资格的人，居民委员会、村民委员会、学校、医疗机构、妇女联合会、残疾人联合会、未成年人保护组织、依法设立的老年人组织、民政部门等。如果有关个人或者单位没有向人民法院及时提出申请撤销监护人资格，民政部门应当向人民法院提出申请，撤销监护人资格，民政部门申请撤销监护人资格是其法定义务。）

（三）被撤销监护人资格的效果

1、人民法院撤销监护人资格之前可以视情况先行中止其履行监护职责。

2、由被监护人住所地的居民委员会、村民委员会、法律规定的有关组织或者民政部门担任临时监护人。

3、监护人的资格撤销以后，人民法院应当按照最有利于被监护人的原则指定监护人。

4、作为监护人的父母、子女、配偶，对被监护人依法负担的抚养费、赡养费、扶养费不因监护的资格撤销而免除或减少。

（四）被撤销监护人资格的恢复

1、监护人资格恢复的要求

（1）恢复主体限于被监护人的父母或子女。

（2）不存在对被监护人实施故意犯罪。

（3）被撤销监护资格的监护人，确有悔改表现。

（4）尊重被监护人的真实意愿

（5）被撤销监护资格的人，应向人民法院提出申请，人民法院依据申请作出是否恢复监护资格的裁决。

2、被撤销监护资格恢复后的效力

（1）被撤销监护资格的监护人为被监护人的当然监护人。

（2）人民法院指定的监护人与被监护人的监护关系同时终止。

五、监护的终止

（一）被监护人取得或者恢复完全民事行为能力

（二）监护人或者被监护人死亡

（三）监护人丧失监护能力

（四）监护人辞去监护

1、监护人有正当理由时，法律应允许其辞去监护，但这不适用于未成年人的父母。

2、正当理由应包括监护人患病、迁居、家庭困难等，但监护人辞去监护应经有指定权的机关同意。

（五）监护人被撤销监护人资格

监护人不履行监护职责或者利用监护之便侵害被监护人合法权益的，经利害关系人申请，人民法院可以撤销监护人的资格，并由此终止监护关系。

监护关系终止后，被监护人仍然需要监护的，应当依法另行确定监护人。

相关法条：《民法典》第二十六条 父母对未成年子女负有抚养、教育和保护的义务。

成年子女对父母负有赡养、扶助和保护的义务。

相关法条：《民法典》第二十七条 父母是未成年子女的监护人。

未成年人的父母已经死亡或者没有监护能力的，由下列有监护能力的人按顺序担任监护人：

（一）祖父母、外祖父母；

（二）兄、姐；

（三）其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。

相关法条：《民法典》第二十八条 无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人，由下列有监护能力的人按顺序担任监护人：

（一）配偶；

（二）父母、子女；

（三）其他近亲属；

（四）其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。

相关法条：《民法典》第二十九条 被监护人的父母担任监护人的，可以通过遗嘱指定监护人。

相关法条：《民法典》第三十条 依法具有监护资格的人之间可以协议确定监护人。协议确定监护人应当尊重被监护人的真实意愿。

相关法条：《民法典》第三十一条 对监护人的确定有争议的，由被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门指定监护人，有关当事人对指定不服的，可以向人民法院申请指定监护人；有关当事人也可以直接向人民法院申请指定监护人。

居民委员会、村民委员会、民政部门或者人民法院应当尊重被监护人的真实意愿，按照最有利于被监护人的原则在依法具有监护资格的人中指定监护人。

依照本条第一款规定指定监护人前，被监护人的人身权利、财产权利以及其他合法权益处于无人保护状态的，由被监护人住所地的居民委员会、村民委员会、法律规定的有关组织或者民政部门担任临时监护人。

监护人被指定后，不得擅自变更；擅自变更的，不免除被指定的监护人的责任。

相关法条：《民法典》第三十二条 没有依法具有监护资格的人的，监护人由民政部门担任，也可以由具备

履行监护职责条件的被监护人住所地的居民委员会、村民委员会担任。

相关法条：《民法典》第三十三条 具有完全民事行为能力的成年人，可以与其近亲属、其他愿意担任监护人的个人或者组织事先协商，以书面形式确定自己的监护人。协商确定的监护人在该成年人丧失或者部分丧失民事行为能力时，履行监护职责。

相关法条：《民法典》第三十四条 监护人的职责是代理被监护人实施民事法律行为，保护被监护人的人身权利、财产权利以及其他合法权益等。

监护人依法履行监护职责产生的权利，受法律保护。

监护人不履行监护职责或者侵害被监护人合法权益的，应当承担法律责任。

相关法条：《民法典》第三十五条 监护人应当按照最有利于被监护人的原则履行监护职责。监护人除为维护被监护人利益外，不得处分被监护人的财产。

未成年人的监护人履行监护职责，在作出与被监护人利益有关的决定时，应当根据被监护人的年龄和智力状况，尊重被监护人的真实意愿。

成年人的监护人履行监护职责，应当最大程度地尊重被监护人的真实意愿，保障并协助被监护人实施与其智力、精神健康状况相适应的民事法律行为。对被监护人有能力独立处理的事务，监护人不得干涉。

相关法条：《民法典》第三十六条 监护人有下列情形之一的，人民法院根据有关个人或者组织的申请，撤销其监护人资格，安排必要的临时监护措施，并按照最有利于被监护人的原则依法指定监护人：

（一）实施严重损害被监护人身心健康行为的；

（二）怠于履行监护职责，或者无法履行监护职责并且拒绝将监护职责部分或者全部委托给他人，导致被监护人处于危困状态的；

（三）实施严重侵害被监护人合法权益的其他行为的。

本条规定的有关个人和组织包括：其他依法具有监护资格的人，居民委员会、村民委员会、学校、医疗机构、妇女联合会、残疾人联合会、未成年人保护组织、依法设立的老年人组织、民政部门等。

前款规定的个人和民政部门以外的组织未及时向人民法院申请撤销监护人资格的，民政部门应当向人民法院申请。

相关法条：《民法典》第三十七条 依法负担被监护人抚养费、赡养费、扶养费的父母、子女、配偶等，被人民法院撤销监护人资格后，应当继续履行负担的义务。

相关法条：《民法典》第三十八条 被监护人的父母或者子女被人民法院撤销监护人资格后，除对被监护人实施故意犯罪的外，确有悔改表现的，经其申请，人民法院可以在尊重被监护人真实意愿的前提下，视情况恢复其监护人资格，人民法院指定的监护人与被监护人的监护关系同时终止。

相关法条：《民法典》第三十九条 有下列情形之一的，监护关系终止：

（一）被监护人取得或者恢复完全民事行为能力；

（二）监护人丧失监护能力；

（三）被监护人或者监护人死亡；

（四）人民法院认定监护关系终止的其他情形。

监护关系终止后，被监护人仍然需要监护的，应当依法另行确定监护人。

相关法条：《民法典》第一千一百八十八条 无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，由监护人承担侵权责任。监护人尽到监护职责的，可以减轻其侵权责任。

有财产的无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，从本人财产中支付赔偿费用；不足部分，由监护人赔偿。

相关法条：《民法典》第一千一百八十九条 无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害，监护人将监护职责委托给他人的，监护人应当承担侵权责任；受托人有过错的，承担相应的责任。

相关法条：《民总解释》第六条 人民法院认定自然人的监护能力，应当根据其年龄、身心健康状况、经济条件等因素确定；认定有关组织的监护能力，应当根据其资质、信用、财产状况等因素确定。

相关法条：《民总解释》第七条 担任监护人的被监护人父母通过遗嘱指定监护人，遗嘱生效时被指定的人不同意担任监护人的，人民法院应当适用民法典第二十七条、第二十八条的规定确定监护人。

未成年人由父母担任监护人，父母中的一方通过遗嘱指定监护人，另一方在遗嘱生效时有监护能力，有关当事人对监护人的确定有争议的，人民法院应当适用民法典第二十七条第一款的规定确定监护人。

相关法条：《民总解释》第八条 未成年人的父母与其他依法具有监护资格的人订立协议，约定免除具有监护能力的父母的监护职责的，人民法院不予支持。协议约定在未成年人的父母丧失监护能力时由该具有监护资格的人担任监护人的，人民法院依法予以支持。

依法具有监护资格的人之间依据民法典第三十条的规定，约定由民法典第二十七条第二款、第二十八条规定的不同顺序的人共同担任监护人，或者由顺序在后的人担任监护人的，人民法院依法予以支持。

相关法条：《民总解释》第九条 人民法院依据民法典第三十一条第二款、第三十六条第一款的规定指定监护人时，应当尊重被监护人的真实意愿，按照最有利于被监护人的原则指定，具体参考以下因素：

（一）与被监护人生活、情感联系的密切程度；

（二）依法具有监护资格的人的监护顺序；

（三）是否有不利于履行监护职责的违法犯罪等情

形；

（四）依法具有监护资格的人的监护能力、意愿、品行等。

人民法院依法指定的监护人一般应当是一人，由数人共同担任监护人更有利于保护被监护人利益的，也可以是数人。

相关法条：《民总解释》第十条 有关当事人不服居民委员会、村民委员会或者民政部门的指定，在接到指定通知之日起三十日内向人民法院申请指定监护人的，人民法院经审理认为指定并无不当，依法裁定驳回申请；认为指定不当，依法判决撤销指定并另行指定监护人。

有关当事人在接到指定通知之日起三十日后提出申请的，人民法院应当按照变更监护关系处理。

相关法条：《民总解释》第十一条 具有完全民事行为能力的成年人与他人依据民法典第三十三条的规定订立书面协议事先确定自己的监护人后，协议的任何一方在该成年人丧失或者部分丧失民事行为能力前请求解除协议的，人民法院依法予以支持。该成年人丧失或者部分丧失民事行为能力后，协议确定的监护人无正当理由请求解除协议的，人民法院不予支持。

该成年人丧失或者部分丧失民事行为能力后，协议确定的监护人有民法典第三十六条第一款规定的情形之一，该条第二款规定的有关个人、组织申请撤销其监护人资格的，人民法院依法予以支持。

相关法条：《民总解释》第十二条 监护人、其他依法具有监护资格的人之间就监护人是否有民法典第三十九条第一款第二项、第四项规定的应当终止监护关系的情形发生争议，申请变更监护人的，人民法院应当依法受理。经审理认为理由成立的，人民法院依法予以支持。

被依法指定的监护人与其他具有监护资格的人之间协议变更监护人的，人民法院应当尊重被监护人的真实意愿，按照最有利于被监护人的原则作出裁判。

相关法条：《民总解释》第十三条 监护人因患病、外出务工等原因在一定期限内不能完全履行监护职责，将全部或者部分监护职责委托给他人，当事人主张受托人因此成为监护人的，人民法院不予支持。

第四节自然人的住所

一、住所的概念

自然人的住所，是指自然人生活和法律关系的中心地。

住所的立法例：

1、单一主义：法律规定一人不得同时有两个住所的。（我国采此）

2、复数主义：法律规定一人可以同时有两个以上住所的。

（一）住所和居所

1、居所是自然人居住的处所，通常指自然人为特定目的暂时居住的处所，它也可以是自然人经常居住的处所。

2、经常居所与住所不一致的，经常居所视为住所。

（二）住所和户籍

1、户籍是记载自然人姓名、出生、性别、籍贯、民族、结婚、离婚、住址等反映自然人基本情况的法律文件。在我国，户籍主要具有行政法上的意义。

2、户籍上的住址在多数情况下与自然人的住所是同一的。

二、自然人住所的法律意义

（一）确定自然人权利、义务的享有地和承担地

（二）确定有关组织或者机关的管辖

（三）宣告失踪和宣告死亡的时间计算

（四）在涉外民事案件，确定法律适用的准据法

三、确定住所的标准

（一）确定住所标准

1、主观说

主观说强调意思因素，认为以当事人长久居住的意思决定住所。（普通法系国家）

2、客观说

客观说强调事实因素，认为实际上长期居住地就是住所。（民法法系国家）

3、折中说

折中说把意思因素和事实因素结合起来，认为以久住的意思而经常居住的某一住所为住所。（瑞士、我国台湾地区）

（二）我国规定（户籍所在地为标准的方法）

1、自然人以户籍登记或者其他有效身份登记记载的居所为住所。

2、经常居所与住所不一致的，经常居所视为住所。（经常居住地，是指自然人离开住所地最后连续居住一年以上的地方，但住医院治病的除外。）

★管辖：当事人户籍迁出后尚未落户，有经常居住地的，由该地人民法院管辖，没有经常居住地的，户籍迁出不足一年的，由其原户籍所在地人民法院管辖，超过一年的，由其居住地人民法院管辖。

四、自然人住所的种类

我国民事立法只对自然人的住所作了概括性规定，而未作具体规定。

（一）意定住所

意定住所，又称任意住所，是指基于当事人的意思而设立的住所。（我国对此并未规定）

（二）法定住所

法定住所，是指不依当事人的意思而设立，而由法律规定的住所。（在我国，无民事行为能力人和限制民事行为能力人也有自己的户籍，因而应以其户籍所在地的居所地为其住所；如果他同监护人共同生活，则监护人的住所是被监护人的经常居住地，视为被监护人的住所。）

（三）拟制住所

拟制住所，是指法律规定在特殊情况下把居所视为住所。

注意：我国民法规范和司法实践肯定了拟制住所的存在：自然人经常居所与住所不一致的，经常居所视为住所。

相关法条：《民法典》第二十五条 自然人以户籍登记或者其他有效身份登记记载的居所为住所；经常居所与住所不一致的，经常居所视为住所。

第五节宣告失踪和宣告死亡

一、宣告失踪

宣告失踪，是指自然人离开自己的住所，下落不明达到法定期限，经利害关系人申请，由人民法院宣告其为失踪人的法律制度。

宣告失踪是对一种确定的自然事实状态的法律确认，目的在于结束失踪人财产关系的不确定状态，保护失踪人的利益和利害关系人的利益。

（一）宣告失踪的条件和程序

1、自然人失踪的事实

（1）自然人离开自己的住所或者居所没有任何音讯。

（2）无音讯状态持续时间满 2 年。2 年的期限是从失踪人最后离开住所或者居所失去音信之日起计算。战争期间下落不明的，下落不明的时间自战争结束之日或者有关机关确定的下落不明之日起计算。

2、利害关系人申请

（1）利害关系人是指：被申请人的近亲属；依据民法典第一千一百二十八条、第一千一百二十九条规定对被申请人有继承权的亲属；债权人、债务人、合伙人等与被申请人有民事权利义务关系的民事主体，但是不申请宣告失踪不影响其权利行使、义务履行的除外。

（2）有权申请自然人为失踪人的利害关系人没有先后顺序。

（3）人民法院应遵循“不告不理”的原则，不能依职权主动宣告某失踪的自然人为失踪人。

（4）利害关系人申请自然人为失踪人的，应用书面形式写明失踪自然人失踪的事实、时间、申请人的请求，并附有关的证明材料。

3、人民法院的受理与公告

（1）利害关系人应到失踪人住所地的基层人民法院提出失踪宣告申请。

（2）人民法院依法受理宣告自然人失踪申请案后，首先发出寻找失踪人的公告，公告期为 3 个月。公告期满，受理人民法院应当根据宣告失踪的事实是否得到确认，作出宣告失踪的判决或者驳回申请的判决。

注意：宣告失踪只能由人民法院作出判决，任何其他机关和个人无权作出宣告失踪的决定。

（二）宣告失踪的效力

1、失踪人的财产管理

（1）失踪人的配偶、成年子女、父母或者其他愿意担任财产代管人的人为失踪人的财产代管人。

（2）失踪人的上述财产代管人没有顺序限制，也不存在谁申请失踪谁享有财产代管权的问题，而只遵循谁管理财产对失踪人的财产有利的原则。（实务中一般遵循配偶、父母、成年子女的顺序确定财产代管人，但前一顺序的代管人对失踪人的财产管理不利时，可由后一顺序的近亲属为财产代管人。）

（3）财产代管人应具有完全民事行为能力；限制民事行为能力或者无民事行为能力人不具有财产代管人的资格。

（4）失踪人如果没有上述财产代管人，或者他们没有能力作为代管人，或者不宜作为代管人的，人民法院可以指定他人或者有关组织为失踪人的财产代管人。

（5）失踪人的财产代管人在代管期间丧失管理能力，或者无力履行代管职责，或者拒不履行代管职责，或者利用代管之便侵害失踪人财产权益的，经利害关系人申请，人民法院可以依法作出变更财产代管人的裁决。

财产代管人有正当理由可以向人民法院申请变更财产代管人，人民法院变更财产代管人的，变更后的财产代管人有权要求原财产代管人及时移交有关财产并报告有关财产代管情况。

（6）失踪人的财产代管人在管理失踪人的财产时，应妥善管理失踪人的财产，代管人在保管、维护、收益时，应与管理自己财产尽同一注意；在进行必要的经营和处分时，应尽善良管理人之注意。

（7）如果代管人不履行代管职责，因故意或者重大过失造成失踪人财产损失，或者侵害了失踪人的财产利益，失踪人的利害关系人可以向人民法院请求财产代管人承担民事责任。

2、失踪人义务履行

（1）失踪人的义务包括失踪人失踪前所应缴纳的税款、所欠债务以及失踪期间所应支付的其他费用（赡养费、抚养费和因代管财产所产生的管理费等必要费用）。

（2）在失踪人失踪期间，失踪人的义务由财产代管人从失踪人的财产中以支付财产的方式来履行。

注意：失踪期间，失踪人的财产代管人向失踪人的债务人要求偿还债务的，可以作为原告提起诉讼；失踪人的财产代管人拒绝支付失踪人所欠的税款、债务和其他费用，债权人提起诉讼的，人民法院应当将代管人列为被告。

（三）失踪宣告的撤销

1、撤销失踪宣告的情形

失踪人重新出现。

2、撤销失踪宣告的程序

（1）由失踪人本人或者他的利害关系人向人民法院

提出撤销失踪宣告的申请。

（2）人民法院对申请人提出的申请进行审核，确认失踪事实消除以后依法作出撤销失踪宣告的判决。

3、撤销失踪宣告的效力

失踪宣告一经撤销，代管人的代管权随之终止，他应当将其代管的财产及收益交还给被撤销失踪宣告的人，并负有将代管期间对其财产管理和处置的详情告知的义务。

二、宣告死亡

宣告死亡，是指自然人下落不明达到法定期限，经利害关系人申请，人民法院宣告其死亡的法律制度。

宣告死亡是法律上的死亡推定，即从自然人下落不明达到法定期限的事实，推定出他已死亡的事实。

宣告失踪制度与宣告死亡制度的设置目的不同。宣告失踪旨在解决失踪人的财产管理问题，但不能解决因失踪人生死不明而引起的民事关系的不确定问题，而宣告死亡制度使这一问题得到解决。宣告失踪制度重在保护失踪人的利益，而宣告死亡制度重在保护被宣告死亡人的利害关系人的利益。

★宣告失踪与宣告死亡的立法例：

1、只设立宣告失踪，不设立宣告死亡。

2、只设立宣告死亡，不设立宣告失踪。

3、同时设立宣告失踪和宣告死亡制度。（我国）

（一）宣告死亡的条件与程序

1、自然人失踪的事实

申请宣告死亡的，在通常情况下，自然人下落不明必须满 4 年；在意外事件的情况下，自然人下落不明的时限为 2 年，因意外事件下落不明，经有关机关证明该自然人不可能生存，利害关系人申请宣告其死亡的，不受 2 年时限的限制。

2、利害关系人的申请

（1）申请宣告死亡的利害关系人是：被申请人的配偶、父母、子女，以及依据民法典第一千一百二十九条规定对被申请人有继承权的亲属

（2）符合下列情形之一的，被申请人的其他近亲属，以及依据民法典第一千一百二十八条规定对被申请人有继承权的亲属：

A、被申请人的配偶、父母、子女均已死亡或者下落不明的；

B、不申请宣告死亡不能保护其相应合法权益的。

（3）不申请宣告死亡不能保护其相应合法权益的被申请人的债权人、债务人、合伙人等民事主体。

★申请自然人宣告死亡的利害关系人是否有顺序限制：

1、有顺序说：利害关系人提出申请是有顺序的，前一顺序人未申请宣告死亡的，后一顺序人不得申请，但同一顺序不受影响。（宣告死亡涉及配偶的身份权保护和其他亲属的继承权保护的冲突，基于人身保护优先于财产保护的原则，宣告死亡应采用有顺序说。）

2、无顺序说：只要是利害关系人均有同等的申请权，不受前顺序人是否申请或反对申请或者申请宣告死亡的影响。（即使宣告死亡，配偶的婚姻关系消灭，但基于被宣告死亡人重新出现后，其婚姻关系自然恢复的规定，配偶身份权的保护已得到救济，故宣告死亡应采用无顺序说。）

3、人民法院的受理和宣告

（1）人民法院受理利害关系人的书面申请后，应即发出寻找失踪人的公告，普通失踪的公告期为 1 年，因意外事件失踪的公告期为 3 个月，公告期满仍不能确定下落不明人尚生存的，即作出宣告死亡的判决。

（2）被宣告死亡的人，人民法院宣告死亡的判决作出之日视为其死亡的日期；因意外事件下落不明宣告死亡的，意外事件发生之日视为其死亡的日期。

（3）宣告失踪不是宣告死亡的必经程序。符合申请宣告死亡条件的，利害关系人可以不申请宣告失踪而直接申请宣告死亡。

（4）如果自然人下落不明满 4 年，利害关系人只申请宣告失踪的，人民法院仍只能作出失踪宣告，而不能作出死亡宣告。

（二）宣告死亡的效力

1、自然人宣告死亡应发生与自然死亡相同的效力，即宣告死亡人丧失民事主体资格，其民事权利能力和民事行为能力终止；其原先参加的民事法律关系归于消灭（法律另有规定的除外）；其婚姻关系自然解除；其个人合法财产变为遗产开始继承。

2、被宣告死亡和自然死亡的时间不一致的，被宣告死亡所引起的法律后果仍然有效，但自然死亡前实施的民事法律行为与被宣告死亡引起的法律后果相抵触的，则以其实施的民事法律行为为准。

（三）死亡宣告的撤销

1、撤销死亡宣告的情形

被宣告死亡人重新出现。

2、撤销死亡宣告的程序

（1）由被宣告死亡人本人或者他的利害关系人向人民法院提出撤销死亡宣告的申请。

（2）人民法院对申请人提出的申请进行审核，确认宣告死亡事实消除后依法作出撤销死亡宣告的判决。

3、撤销死亡宣告的效力

（1）被宣告死亡的人的婚姻关系，自死亡宣告之日起消灭。死亡宣告被撤销的，婚姻关系自撤销死亡宣告之日起自行恢复，但是其配偶再婚或者向婚姻登记机关书面声明不愿意恢复的除外。

（2）被宣告死亡的人在被宣告死亡期间，其子女被他人依法收养的，在死亡宣告被撤销后，不得以未经本人同意为由主张收养关系无效。（收养人和被收养人同意的除外）

（3）被撤销死亡宣告的人有权请求依照继承法取得其财产的民事主体返还财产。（法定继承人、遗嘱继

承人和受遗赠人。）无法返还的，应当给予适当补偿。（财产已由第三人取得，不论是有偿取得还是无偿取得，从维护新生法律关系的稳定性出发，本人无权向第三人请求返还。如果继承财产已经灭失或者消费或由第三人取得，本人只能向继承人请求适当补偿。适当补偿不是赔偿，而是根据本人和继承人的财产状况、财产灭失原因、当事人过错等因素予以综合衡量，根据公平原则给予补偿。返还财产不仅包括继承财产本身，而且包括继承财产所生孳息，但不应包含继承财产所获收益。）

利害关系人隐瞒真实情况，致使他人被宣告死亡取得其财产的，除应当返还财产外，还应当对由此造成的损失承担赔偿责任。

相关法条：《民法典》第四十条 自然人下落不明满二年的，利害关系人可以向人民法院申请宣告该自然人为失踪人。

相关法条：《民法典》第四十一条 自然人下落不明的时间从其失去音讯之日起计算。战争期间下落不明的，下落不明的时间自战争结束之日或者有关机关确定的下落不明之日起计算。

相关法条：《民法典》第四十二条 失踪人的财产由其配偶、成年子女、父母或者其他愿意担任财产代管人的人代管。

代管有争议，没有前款规定的人，或者前款规定的人无代管能力的，由人民法院指定的人代管。

相关法条：《民法典》第四十三条 财产代管人应当妥善管理失踪人的财产，维护其财产权益。

失踪人所欠税款、债务和应付的其他费用，由财产代管人从失踪人的财产中支付。

财产代管人因故意或者重大过失造成失踪人财产损失的，应当承担赔偿责任。

相关法条：《民法典》第四十四条 财产代管人不履行代管职责、侵害失踪人财产权益或者丧失代管能力的，失踪人的利害关系人可以向人民法院申请变更财产代管人。

财产代管人有正当理由的，可以向人民法院申请变更财产代管人。

人民法院变更财产代管人的，变更后的财产代管人有权要求原财产代管人及时移交有关财产并报告财产代管情况。

相关法条：《民法典》第四十五条 失踪人重新出现，经本人或者利害关系人申请，人民法院应当撤销失踪宣告。

失踪人重新出现，有权要求财产代管人及时移交有关财产并报告财产代管情况。

相关法条：《民法典》第四十六条 自然人有下列情形之一的，利害关系人可以向人民法院申请宣告该自然人死亡：

（一）下落不明满四年；

（二）因意外事件，下落不明满二年。

因意外事件下落不明，经有关机关证明该自然人不可能生存的，申请宣告死亡不受二年时间的限制。

相关法条：《民法典》第四十七条 对同一自然人，有的利害关系人申请宣告死亡，有的利害关系人申请宣告失踪，符合本法规定的宣告死亡条件的，人民法院应当宣告死亡。

相关法条：《民法典》第四十八条 被宣告死亡的人，人民法院宣告死亡的判决作出之日视为其死亡的日期；因意外事件下落不明宣告死亡的，意外事件发生之日视为其死亡的日期。

相关法条：《民法典》第四十九条 自然人被宣告死亡但是并未死亡的，不影响该自然人在被宣告死亡期间实施的民事法律行为的效力。

相关法条：《民法典》第五十条 被宣告死亡的人重新出现，经本人或者利害关系人申请，人民法院应当撤销死亡宣告。

相关法条：《民法典》第五十一条 被宣告死亡的人的婚姻关系，自死亡宣告之日起消灭。死亡宣告被撤销的，婚姻关系自撤销死亡宣告之日起自行恢复，但是其配偶再婚或者向婚姻登记机关书面声明不愿意恢复的除外。

相关法条：《民法典》第五十二条 被宣告死亡的人在被宣告死亡期间，其子女被他人依法收养的，在死亡宣告被撤销后，不得以未经本人同意为由主张收养关系无效。

相关法条：《民法典》第五十三条 被撤销死亡宣告的人有权请求依照继承法取得其财产的民事主体返还财产。无法返还的，应当给予适当补偿。

利害关系人隐瞒真实情况，致使他人被宣告死亡取得其财产的，除应当返还财产外，还应当对由此造成的损失承担赔偿责任。

相关法条：《民总解释》第十四条 人民法院审理宣告失踪案件时，下列人员应当认定为民法典第四十条规定的利害关系人：

（一）被申请人的近亲属；

（二）依据民法典第一千一百二十八条、第一千一百二十九条规定对被申请人有继承权的亲属；

（三）债权人、债务人、合伙人等与被申请人有民事权利义务关系的民事主体，但是不申请宣告失踪不影响其权利行使、义务履行的除外。

相关法条：《民总解释》第十五条 失踪人的财产代管人向失踪人的债务人请求偿还债务的，人民法院应当将财产代管人列为原告。

债权人提起诉讼，请求失踪人的财产代管人支付失踪人所欠的债务和其他费用的，人民法院应当将财产代管人列为被告。经审理认为债权人的诉讼请求成立的，人民法院应当判决财产代管人从失踪人的财产中支付失踪人所欠的债务和其他费用。

相关法条：《民总解释》第十六条 人民法院审理宣告死亡案件时，被申请人的配偶、父母、子女，以及依据民法典第一千一百二十九条规定对被申请人有继承权的亲属应当认定为民法典第四十六条规定的利害关系人。

符合下列情形之一的，被申请人的其他近亲属，以及依据民法典第一千一百二十八条规定对被申请人有继承权的亲属应当认定为民法典第四十六条规定的利害关系人：

（一）被申请人的配偶、父母、子女均已死亡或者下落不明的；

（二）不申请宣告死亡不能保护其相应合法权益的。

被申请人的债权人、债务人、合伙人等民事主体不能认定为民法典第四十六条规定的利害关系人，但是不申请宣告死亡不能保护其相应合法权益的除外。

相关法条：《民总解释》第十七条 自然人在战争期间下落不明的，利害关系人申请宣告死亡的期间适用民法典第四十六条第一款第一项的规定，自战争结束之日或者有关机关确定的下落不明之日起计算。

第六节 个体工商户和农村承包经营户

一、个体工商户

（一）个体工商户的概念与特征

1、个体工商户的概念

个体工商户，是指在法律允许的范围内，依法经核准登记，从事工商经营活动的自然人或者家庭。

2、个体工商户的特征

（1）从事工商个体经营的是单个自然人或者家庭。（自然人——民事行为能力）

（2）个体工商户必须依法进行核准登记。（申请——核准登记——营业执照，在核准登记的范围内从事经营活动）

（3）个体工商户应在法律允许的范围内从事工商经营活动。（手工业、加工业、零售商业、修理业、服务业等）

（二）个体工商户的法律地位

个体工商户为自然人。

★个体工商户与自然人的不同之处：

1、依照我国现行法律，个体工商户可以雇工经营；个体工商户可以起字号和刻制公章，在民事诉讼中，起字号的个体工商户应以该字号为诉讼主体。

2、个体工商户具有明确的目的，其目的就是其经营范围内享有经营权、起字号权、商标注册申请权等自然人不享有的权利，依法承担纳税及接受监督、检查的义务。

3、个体工商户具有相对独立的财产，该财产主要用于其所从事的工商经营活动。当然个体工商户的财产与个人财产、家庭财产不是严格区分的。

（三）个体工商户的债务承担

1、个体工商户的债务，个人经营的由个人财产承担该债务。（个人经营，是指由个人出资由个人开展工商业活动，并且经营所得不主要用于家庭消费。个人债务，是指经营人的财产与家庭财产严格区分。由个人财产承担债务，是指由个体工商户经营活动所产生的债务，由个体工商户的个人财产承担。）

2、个体工商户的债务，家庭经营的由家庭财产承担。（家庭经营，是指由家庭财产投资经营，或者由个体工商户自然人本人和家庭财产共同投资经营。）

3、个体工商户债务，无法区分个人财产投资经营还是家庭财产投资经营的，由家庭财产承担债务。

二、与农村承包经营户

（一）农村承包经营户的概念与特征

1、农村承包经营户的概念

农村承包经营户，是指在法律允许的范围内，按照承包合同的规定从事商品经营的农村经济组织的成员。

2、农村承包经营户的特征

（1）农村承包经营户是农村集体经济组织的成员。

（2）农村承包经营户是基于各种承包合同发生的。

（3）农村承包经营户是在法律允许的范围内从事商品生产经营活动。

3、农村承包经营户的法律地位

农村承包经营户为自然人。

注意：

1、农村承包经营户作为民事主体，仅限于与集体组织签订承包合同等与此有关的民事活动中。农民进城务工或者向城镇居民出售粮食、蔬菜等农产品，其主体地位为自然人，而不为农村承包经营户。

2、农村承包经营户主体资格的取得与工商个体户不同，不存在登记注册的问题。

3、对于违反承包合同或者侵犯其经济权利的集体经济组织或个人，他们有权向人民法院起诉要求保护。

4、农村承包经营户应接受集体经济组织的指导和管理，集体经济组织应当尊重农村承包经营户的自主权，不得非法干预。

（二）农村承包经营户的债务承担

农村承包经营户的债务，以从事农村土地承包经营的农户财产承担；事实上由农户部分成员经营的，以该部分成员的财产承担。

相关法条：《民法典》第五十四条 自然人从事工商业经营，经依法登记，为个体工商户。个体工商户可以起字号。

相关法条：《民法典》第五十五条 农村集体经济组织的成员，依法取得农村土地承包经营权，从事家庭承包经营的，为农村承包经营户。

相关法条：《民法典》第五十六条 个体工商户的债务，个人经营的，以个人财产承担；家庭经营的，以家庭财产承担；无法区分的，以家庭财产承担。

农村承包经营户的债务，以从事农村土地承包经营

的农户财产承担；事实上由农户部分成员经营的，以该部分成员的财产承担。

第五章 法人

第一节 法人概述

一、法人的概念与特征

（一）法人的的概念与法人制度的形成

1、法人的概念

法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

2、法人制度的形成

（1）现代法人制度和法人观念萌芽于罗马法。

（2）法人概念是中世纪注释法学派在总结概括罗马法的基础上提出来的，但所指并不是真正的法人，不过是团体及共同态。

（3）15 世纪末，在荷兰和英国合伙型的公司逐步向法人型公司过渡，1612 年英国东印度公司将各个个人的资本合并为共同资本，公司有了由其支配的相对独立的财产和团体人格。

（4）19 世纪出现了股份有限公司和有限责任公司，公司有了完全独立的人格。

3、关于法人的立法例

（1）1863 年的《萨克逊王国民法典》，规定了法人制度，将法人分为社团法人和财团法人。

（2）1804 年《法国民法典》没有规定法人制度。（后来在《法国民法典》修正的条文中用了法人概念）

（3）1896 年《德国民法典》将法人规定为与自然人并列的民事主体，将法人分为社团、财团和公法人，规定了社团法人的成立、登记、章程、法人机关、破产和清算等，建立了完备的法人制度。

（二）法人的特征

1、法人是社会组织

作为民事主体的法人或为多个自然人组成的社会集合体，或为以一定数量的财产集合为基础组成的社会组织。

2、法人是具有民事权利能力和民事行为能力的社会组织

（1）法人是社会组织，但并不是任何社会组织都能取得法人资格。只有具备法人的成立条件，具有民事权利能力和民事行为能力的社会组织，才能取得法人资格。

（2）即使取得法人资格的社会组织，也不是在任何情况下都以法人的名义进行活动。

3、法人是依法独立享有民事权利和民事义务的组织

（1）独立的组织

A、法人的民事主体资格与组成法人的自然人的民事主体资格是彼此独立的，某个或者某些成员的死亡或者退出法人组织，不影响法人的存续。

B、法人的组织无需依靠其他组织或者单位而独立存在。

（2）独立的财产

A、独立的财产，是指法人所有或者经营管理的全部财产。

B、法人的财产独立于其出资者的财产。

（3）独立的责任

如果法人违反民事义务，由法人独立承担民事责任。法人的财产不足清偿债务时，法人的出资者不承担责任（法律另有规定的除外）。

二、法人制度的作用

（一）营利法人的作用

1、聚集财产的优势

2、事业程序的永久性

3、分散风险

4、优化管理

（二）非营利法人的作用

1、实现公益价值

2、确保财产价值

三、法人的分类

（一）《民法典》对法人的分类

1、营利法人

以取得利润并分配给股东等出资人为目的成立的法人，为营利法人。营利法人包括有限责任公司、股份有限公司和其他企业法人等。

2、非营利法人

为公益目的或者其他非营利目的成立，不向出资人、设立人或者会员分配所取得利润的法人，为非营利法人。非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等。

3、特别法人

机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人，为特别法人。

（二）外国立法和学理对法人的分类

1、社团法人与财团法人

（1）社团法人与财团法人的概念

根据法人成立的基础不同，法人可分为社团法人与财团法人。

A、社团法人，又称为人的组合，是以社员为基础的人的集合体。

B、财团法人，又称为财产组合，是指为一定目的而设立的，并由专门委任的人按照规定的目的使用的各种财产。

（2）区分社团法人与财团法人的意义

A、成立基础不同

社团法人以人为基础，有自己的组织成员或者社员；财团法人以财产为基础，因而没有法人成员。

B、设立人的地位不同

社团法人的设立人，在法人成立时成为其成员，并

享有社员权；而财团法人的设立人，因于法人成立时与法人相脱离，故不为法人成员。

C、设立行为不同

社团法人的设立行为属于共同的民事法律行为，且为生前行为；而财团法人的设立行为则为单方，有的为死后生效的行为。

D、有无意思机关不同

社团法人有自己的意思机关，故又称自律法人；财团法人则没有该机关，故又称他律法人。

E、目的不同

社团法人设立的目的可以是为了营利，也可以为了公益，故社团法人可分为营利法人、公益法人和中间法人；财团法人的设立目的只能是为了公益，所以财团法人只能是公益法人。

注意：《民法典》未区分社团法人和财团法人。

2、营利法人与公益法人、中间法人

（1）营利法人与公益法人、中间法人的概念

根据法人成立或者活动的目的不同，法人可分为营利法人、公益法人和中间法人。

A、营利法人，是指以营利并分配给其成员为活动目的的法人。

B、公益法人，是指以公益为其活动目的的法人。

C、中间法人，是指既非以营利为目的又非以公益为目的的法人。

（2）区分营利法人与公益法人的意义

A、目的不同

营利法人以营利并分配给其成员为目的；公益法人以公益为目的。

B、设立准则不同

营利法人的设立依特别法的规定设立；而公益法人除有特别法外，一般依民法的规定设立。

C、设立程序不同

营利法人的设立，除有特别规定外，一般不需要得到主管机关的许可；公益法人则必须得到这种许可后才能成立。

D、法律形式不同

营利法人只能采取社团法人的形式；公益法人既可以采取社团法人形式，又可采取财团法人形式。

E、民事活动的范围不同

营利法人可从事各种营利性事业；公益法人无权从事以向其成员分配营利为目的的营利性事业，否则构成违法。

3、公法人与私法人

（1）公法人与私法人的概念

A、公法人，是指以社会公共利益为目的，由国家或者公共团体依公法所设立的行使或者分担国家权力或者政府职能的法人。

B、私法人，是指以私人利益为目的，由私人依私法而设立的法人。

（2）区分公法人与私法人的意义

A、诉讼方式不同

对于公法人因行使公共权力所生争执，依行政救济程序解决，或行政复议或行政诉讼。对于私法人间所生争执，依民事诉讼程序或者仲裁程序解决。

B、损害赔偿依据不同

公法人及其职员因侵权行为所生损害，依国家赔偿法或者特别规定承担损害赔偿责任；私法人及其职员因侵权行为所生损害，依民法规定承担损害赔偿责任。

注意：《民法典》未区分公法人和私法人。

4、本国法人与外国法人

（1）本国法人与外国法人的概念

根据法人的国籍不同，法人可分为本国法人与外国法人。

A、本国法人，是指具有本国国籍的法人。

B、外国法人，是指不具有本国国籍的法人。

注意：

1、凡依照中国法律，在中国设立的法人，为中国法人；而中国法人之外的法人，均属于外国法人。

2、外国投资人在中国设立的法人，应为中国法人；而中国投资人在外国设立的法人，应为外国法人。

（2）区分本国法人与外国法人的意义

对外国法人有专门的认许制度，及对外国法人在民事活动的范围上有所限制。

• **注意：**《民法典》未规定外国法人，《公司法》第 11 章对外国公司的分支机构有所规定，即外国公司（依照外国法律在中国境外成立的公司）属于外国法人，其在中国境内设立的分支机构不具有中国法人资格。外国公司应对其分支机构的经营活动承担民事责任。

相关法条：《民法典》第五十七条 法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

第二节 法人的成立

法人的成立是法人取得民事权利能力和民事行为能力的法律事实。（法人的成立需经法定程序，即须经设立和法人资格的取得两个阶段。）

一、法人的设立

（一）法人设立的概念

法人的设立，是指创办法人组织，使其具有民事权利主体资格而进行的多种连续准备行为，它是法人成立的前置阶段，是法人成立的必经程序。

★法人的设立与法人的成立的关系：

1、联系

没有法人的设立便没有法人的成立，凡法人成立必须经法人设立。

2、区别

（1）两者的性质不同

法人的设立是一种准备行为，这种准备行为既有法

律性质上的，也有非法律性质上的；而法人的成立则不同，它属于法人产生的形成阶段，其行为性质均属于法律意义上的行为。

（2）两者的要件不同

法人的设立一般要有合法的设立人，存在设立基础和设立行为本身合法等要件；而法人的成立一般应具备依法成立、有必要的财产和或者经费以及有自己的名称、组织机构和住所等要件。因此，法人的设立并不当然导致法人的成立，当设立无效时，法人就不能成立。

（3）两者的效力不同

法人的设立阶段，仍不具有法人资格，其行为是非法人组织的行为，所发生的债权债务，由设立后的法人享有和承担；如果法人不能成立，则由设立人承担设立行为产生的债务。而法人成立后，即享有民事主体资格，所发生的债权和债务，由法人享有和承担。

（二）法人设立的原则

1、自由设立主义（放任主义）：国家对于法人的设立完全听凭当事人自由，不要求具备任何形式，不加以任何干涉和限制。

2、特许设立主义：法人的设立，须经特别立法或者国家元首的许可。

3、行政许可主义：法人的设立须经行政机关的许可。

4、准则主义（登记主义）：法律对于法人的设立，预先规定一定的条件，设立人须遵照此条件设立，无须先经行政机关许可，依照法定条件设立后，仅须向登记机关登记，法人即可成立。

5、强制设立主义：国家对于法人设立，实行强制设立主义，此种主义仅适用于特殊产业或者特殊团体。

★我国现行法律对法人设立的原则：

1、营利法人的设立原则

（1）企业法人的设立一般实行准则主义。

（2）商业银行、保险公司等特殊法人，采取特许设立主义。

2、非营利法人的设立原则

事业单位法人和社会团体法人依法不需要办理法人登记的，其设立原则应属于特许设立主义；事业单位法人和社会团体法人依法需要办理登记的，应当经过业务主管部门审查同意，向登记机关申请登记，其设立原则应属行政许可主义。

3、特别法人

机关法人的设立取决于宪法和国家机关组织法的规定，相当于特许设立主义。

（三）法人设立的方式

1、命令设立

（1）命令设立，是指政府以其命令的方式设立法人。

（2）命令设立主要适用于国家机关和全民所有制事业单位。

2、发起设立

（1）发起设立，是指由发起人一次性认足法人成立所需资金而设立法人。

（2）发起设立主要适用于集体所有制企业法人、私营企业法人、股份合作企业法人、有限责任公司和一些股份公司。

3、募集设立

（1）募集设立是指法人组织所需的资金，在发起人未认足之时，向社会公开募集的一种法人设立方式。

（2）募集设立主要适用于股份有限公司。

4、捐助设立

（1）捐助设立，是指由法人或者自然人募足法人所需资金的一种法人设立方式。

（2）捐助设立主要适用于基金会法人。

（四）法人设立的条件

1、设立人或者发起人

2、设立基础

3、设立行为本身合法

（五）法人设立的民事责任

1、设立人为设立法人从事的民事活动，其法律后果由法人承受；法人未成立的，其法律后果由设立人承受，设立人为二人以上的，享有连带债权，承担连带债务。

2、设立人为设立法人以自己的名义从事民事活动产生的民事责任，第三人有权选择请求法人或者设立人承担。

★法人资格的取得：

1、营利法人依法登记为营利法人成立之日，营利法人自营业执照签发之日起取得法人资格。

2、事业单位法人或者社会团体法人依法不需要办理法人登记的，从设立时起即取得法人资格；依法需要办理法人登记的，经核准登记领取法人证书之日起取得法人资格。

3、捐助法人自登记之日起取得法人资格。

4、机关法人自成立之日起取得法人资格。

二、法人应具备的条件

法人应具备的条件，是指取得法人资格所必须具有的基本条件。

（一）依法成立

依法成立，是指依照法律的规定而成立。

1、法人组织的设立合法，其设立的目的、宗旨要符合国家和社会公共利益的要求，其组织机构、设立方式、经营范围、经营方式等要符合法律的要求。

2、法人的成立程序符合法律、法规的规定。

（二）有必要的财产或者经费

必要的财产或者经费，是指法人的财产或者经费应与法人的性质、规模等相适应。

（三）有自己的名称、组织机构和住所

1、法人应该有自己的名称，通过名称的确定使自己与其他法人相区别。

2、法人是社会组织，法人的意思表示必须依法由法

人组织机构来完成，每一个法人都应该有自己的组织机构。

3、法人应该有自己的住所。作为法人的住所，既可以是自己所有的，也可以是租赁他人的，还可以是和他人共用的。法人的场所可以是一个，也可以是多个。

注意：法人成立的条件，特别法有具体规定的，从其规定。

相关法条：《民法典》第五十八条 法人应当依法成立。

法人应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。法人成立的具体条件和程序，依照法律、行政法规的规定。

设立法人，法律、行政法规规定须经有关机关批准的，依照其规定。

相关法条：《民法典》第七十五条 设立人为设立法人从事的民事活动，其法律后果由法人承受；法人未成立的，其法律后果由设立人承受，设立人为二人以上的，享有连带债权，承担连带债务。

设立人为设立法人以自己的名义从事民事活动产生的民事责任，第三人有权选择请求法人或者设立人承担。

第三节 法人的民事能力

一、法人的民事权利能力

（一）法人民事权利能力的概念

1、法人的民事权利能力，是指法人依法享有民事权利和承担民事义务的资格。

2、法人的民事权利能力，从法人成立时产生，到法人终止时消灭。

（二）法人民事权利能力的限制

法人民事权利能力的限制的意义在于规制法人民事法律行为的范围，确认法人民事法律行为的效力。

1、法人的权利能力是否受限制，各国立法有所不同。

2、法人的权利能力是否受限制，学者有不同的观点。

3、法人权利能力有三个方面的限制（通说）

（1）因性质之限制

法人的民事权利能力受其自然性质的限制，即不享有与自然人的人身不可分离的那些权利。

（2）因法令之限制

法人只能在法律或行政命令的范围内具有享有权利和承担义务的能力。

（3）因目的之限制

法人的民事权利能力要受到其设立人的意志的约束，其设立人在设立法人时确立的目的范围直接决定法人的民事权利能力的范围。

二、法人的民事行为能力

（一）法人民事行为能力的概念

1、法人的民事行为能力，是指法人能以自己的行为取得民事权利和承担民事义务的资格。

2、法人的民事行为能力，从法人成立时产生，到法人终止时消灭。

（二）法人民事行为能力的特征

1、法人的民事行为能力享有的时间与其民事权利能力享有的时间一致。

2、法人的民事行为能力的范围与民事权利能力的范围一致。

3、法人的民事行为能力由法人机关或者代表人实现。

三、法人的民事责任能力

（一）法人民事责任能力的概念

法人的民事责任能力，是指法人对自己侵权行为承担民事责任的能力或者资格。

★法人本质：

1、法人拟制说：权利义务之主体，应以自然人为限。非自然人而得为权利义务之主体者，是以法律之力拟制其为自然人。质言之，所谓法人，即法律所拟制之人。

2、法人否认说：依实证的方法观察，社会生活中除个人及财产而外，别无所谓法人之存在。

（1）目的财产说：法人之本质，不过是为一定目的而存在的无主体财产而已。

（2）受益人主体说：以享有法人财产利益之多数人为其实质主体，所谓法人不过于形式上为其权利的归属者而已。

（3）管理人主体说：实际管理法人财产之人，为法人之本体。

3、法人实在说：法人在社会现实中得以独立的统一体而存在，法人并非单凭政府的权力来创造，而其本质就是适于而且必须赋予其人格的社会实在体，因此与法人拟制说相区别；同时，法人制度又并非仅为使法律关系单纯化的立法技术，而是对应现实所具有的实际主体承认其法律人格而已，因此也与法人否定说不同。故法人是依法承认的权利主体，其虽须待法律的承认方始存在，但法律所承认的法人人格的对象，本就是已经实际存在于社会的东西。

（1）有机体说：人类社会生活中，团体有其固有的生命。自然人为自然的有机体，有其个人意思；而团体则有其固有的生命。自然人为自然的有机体，有其个人意思；而团体则为社会的有机体，有其团体意思。对于此社会的有机体，赋予法律的人格，使之为权利义务之主体，即所谓法人。

（2）组织体说：此说乃针对有机体说，认为法人非社会的有机体，而是法律上的组织体。所谓法人，乃适于为权利义务主体之法律上的组织体。（通说）

（二）法人有无民事责任能力的学说

1、否定说

认为法人无民事责任能力，这属法人拟制说的主张。

2、肯定说（通说）

认为法人有民事责任能力，这属法人实在说的主张。

（三）法人的民事责任

1、法人对其法定代表人和其他工作人员的职务行为承担民事责任

（1）法定代表人的过错，就是法人的过错，法人对法定代表人的职务行为造成的损害承担民事责任，是自己责任，其原因不仅是因为法人对法定代表人的选任和职务授权负有直接责任，而且因为法人对其法定代表人的经营活动负有监督义务。

（2）法人承担民事责任后，依照法律或者法人章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。法人向法代表人行使追偿权的规则是：A、只能针对法定代表人的违反章程禁止的 行为或者违法行为，法定代表人正常的经营行为甚至一定限度内的越权行为，给法人造成损害的，法人也不得追偿。

B、法人行使追偿权以法定代表人存在过错为前提，在司法实践中该过错通常应为故意或重大过失。

（3）法人的其他工作人员与法人之间的关系为职务代理关系，法人对其他工作人员执行职务的行为承担民事责任，是基于对代理后果的承受。法人对其他工作人员执行职务承担责任，是因为法人对其他工作人员的选任和指示负有义务，并对其他工作人员执行职务的行为负有监督义务。当然，法人承担责任以后，对存在故意或者重大过失的工作人员享有追偿权。

2、法人对自己的民事违法行为承担民事责任

法人应当在核准登记的经营范围内从事经营活动，法人从事非法经营或者向登记机关、税务机关隐瞒真实情况，弄虚作假、抽逃资金、隐匿财产以逃避债务以及从事其他违法活动，损害国家利益或者社会公共利益，或者给他人造成损失的，应首先追究法人的责任。法人承担责任后可依据法律或公司章程的规定向违法或违章的法人代表人或工作人员追偿。

相关法条：《民法典》第五十九条 法人的民事权利能力和民事行为能力，从法人成立时产生，到法人终止时消灭。

相关法条：《民法典》第六十条 法人以其全部财产独立承担民事责任。

相关法条：《民法典》第六十一条 依照法律或者法人章程的规定，代表法人从事民事活动的负责人，为法人的法定代表人。

法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受。

法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人。

相关法条：《民法典》第六十二条 法定代表人因执行职务造成他人损害的，由法人承担民事责任。

法人承担民事责任后，依照法律或者法人章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

相关法条：《民法典》第一千一百九十一条 用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由用人单位承担侵权责任。用人单位承担侵权责任后，可以向有故意或者重大过失的工作人员追偿。

劳务派遣期间，被派遣的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由接受劳务派遣的用工单位承担侵权责任；劳务派遣单位有过错的，承担相应的责任。

法人的机关

一、法人机关的概念和特征

（一）法人机关的概念

法人机关，是指根据法律、章程或者条例的规定，于法人成立时产生，不需要特别委托授权就能够以法人的名义对内负责法人的生产经营或者业务管理，对外代表法人进行民事活动的集体或者个人。

（二）法人机关的特征

1、法人机关是根据法律、章程或者条例的规定而设立的。

2、法人的机关是法人的有机组成部分。

3、法人的机关是形成、表示和实现法人意志的机构。

4、法人的机关是法人的领导或者代表机关。

5、法人机关由单个的个人或者集体组成。

注意：法人的机关不同于法人的组织机构。法人的组织机构外延很大。法人机关的法人组织机构的重要组成部分，仅指法人组织机构中的权力机关、执行机关和监督机关。

二、法人机关构成及法定代表人

（一）法人机关的构成

1、权力机关

（1）权力机关，又称为决策机关，是指法人自身意思的形成机关，有权决定法人的生产经营或者业务管理的重大问题。

（2）权力机关是营利法人的必设机关，行使修改法人章程，选举或者更换执行机构、监督机构成员，以及法人章程规定的其他职权。

2、执行机关

（1）执行机关，是指法人权力机关的执行机关，有权执行法人章程、条例或者设立命令所规定的事项以及法人权力机关所决定的事项，有权代表法人对外进行民事活动，其主要负责人为法定代表人。

（2）法人的执行机关是营利法人的必设机关，执行机构行使召集权力机构会议，决定法人的经营计划和投资方案，决定法人内部管理机构的设置，以及法人章程规定的其他职权。

执行机构为董事会或者执行董事的，董事长、执行董事或者经理按照法人章程的规定担任法定代表人；未设董事会或者执行董事的，法人章程规定的主要负责人为其执行机构和法定代表人。

（3）非营利法人中的社会团体法人执行机关是其理事会，机关法人、事业单位法人的负责人为其执行机关。

3、监督机关

（1）监督机关，是指对法人执行机关的行为进行监督检查的机关。

（2）营利法人设监事会或者监事等监督机构的，监督机构依法行使检查法人财务，监督执行机构成员、高级管理人员执行法人职务的行为，以及法人章程规定的其他职权。

（3）监督机关不是一切法人的必设机关，是否设立监督机关依法律规定、法人章程、设立命令或者决策机关的决定而定。

（二）法定代表人

1、法定代表人的概念

法定代表人，是指依照法律或者法人章程的规定，代表法人行使职权的负责人。

2、法定代表人的特征

（1）法定代表人的资格是法定的或者章程确定的。

（2）法定代表人是代表法人行使职权的负责人。

（3）法定代表人是代表法人从事业务活动的自然人。

3、法定代表人的条件

（1）必须具有完全民事行为能力。

（2）必须具有一定管理能力和业务知识。

（3）须不存在不得担任法定代表人的情形。

（4）企业法人的法定代表人原则上可兼任其他法人的法定代表人，但法律有特别限制的除外。

三、法人机关决议（决定）的效力

（一）法人机关决议（决定）的概念

法人机关决议（决定）是指法人机关依照法律规定或章程规定的程序表决形成的决议，法人机关的决议（决定）是法人机关的意思表示。（法人机关的决议（决定）包括权力机关的决议（决定）、执行机关的决议（决定）、监督机关的决议（决定）。）

（二）法人机关决议（决定的）的无效和撤销

1、法人机关的决议（决定）内容违反法律、行政法规即属无效决议（决定）。（自始无效、确定无效、当然无效。）

2、法人的机关的决议（决定）违反法律规定的程序或章程规定的内容和程序的即属可撤销的决议（决定）。

（三）法人机关决议（决定）与善意相对人

法人机关的决议（决定）对善意第三人不生效力。

四、法人机关与法人的关系

（一）代理说

法人为拟制人，它本身没有意思能力和行为能力。因此，法人作为一个民事主体进行民事活动，只能由自然人代理。法人机关是法人的代理人，法定代表人是法人的法定代理人，法人机关与法人的关系是代理关系。法人对法人机关的活动承担责任是基于代理规则。

（二）代表说（通说）

法人是社会组织体，法人具有民事权利能力和民事行为能力，法人机关是法人意志的形成者和执行者，法人机关在其权限范围内的活动为法人本身的活动。法人机关是法人的代表者，法人机关与法人的关系是代表关系。

注意：

1、法人机关是法人的组成部分，法人机关与法人只有一层法律人格。法人机关在其权限范围内所为的一切行为，均为法人本身的行为，其行为后果由法人承担。

2、法人机关不是独立的权利主体，而是法人的有机组成部分。法人机关与法人的关系是部分与全体之间的关系。这种关系不同于代理关系。

（1）在代理关系中，代理人与被代理人是两个独立的民事主体，亦即存在代理人与被代理人的二元对立关系；而法人机关与法人的关系，为部分与全体的一元关系。

（2）在代理关系中，必须有代理人的意思和被代理人的意思，即存在两个意思；而在法人机关与法人的关系中，只有一个意思，即法人意思。

（3）在代理关系中，代理行为是代理人的行为，不是被代理人的行为，只不过这种行为后果依代理规则直接由被代理人承担；而法人机关的行为，就是法人的行为，其行为后果自然归属于法人。

第五节 法人的分支机构

一、法人分支机构的概念

（一）法人分支机构的概念

法人的分支机构是根据法人的意志在法人总部之外依法设立的法人分部，其活动范围限于法人的活动范围内。

★法人分支机构的分类：

1、领取了营业执照的分支机构。（法人可以依法设立分支机构，分支机构可以以自己的名义进行民事法律行为，从事民事活动。即可以以自己的名义签订合同，招募员工，从事生产与经营；分支机构进行民事法律行为所产生的民事责任由法人承担，分支机构不具有独立承担民事责任的能力，但可以首先由分支机构管理的财产予以承担，不足部分由法人财产承担。分支机构可以作为诉讼主体，成为诉讼中的原告和被告。依法领取营业执照的营利法人的分支机构还为纳税主体。）

2、未领取营业执照的分支机构（不能以自己的名义独立从事民事活动，而只能以法人的名义进行民事活动；不能以自己的名义起诉和应诉，其责任由所属法人直接承担）。

（二）法人分支机构的特征

1、外部形式上具有与企业法人相类似的特点。

（1）经过核准登记才能进行业务活动，须拥有自己的名称和组织机构，有可以使用和支配的财产或者经费。

（2）在通常情况下，分支机构以自己的名义进行民

事活动，享有民事权利，承担民事义务，以其经营的财产承担民事责任；分支机构不能清偿债务时，由法人的其他财产清偿。（分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。）

2、内容上具有从属于企业法人的特点。

（1）它是企业法人依法设立的不具有法人资格的组织，是所属法人的组成部分。

（2）它只能实现法人的宗旨，并在所属法人业务范围内经核准登记进行活动。

（3）它的名称必须标明与其所属法人的隶属关系。

（4）它所占有、使用的财产不属于自己所有，而是其所属法人财产的组成部分。

（5）它的管理人员不是由内部产生，而是由其所属法人指派。

注意：

1、企业法人的分支机构不同于法人的一般科、室、车间、班组等。后者不是法人的分支机构。只有能够独立执行法人职能，即在一定范围内从事业务活动的组织机构，才能作为法人的分支机构。企业法人的分支机构须进行登记，领取营业执照，才具有经营能力。

2、法人的分支机构也不同于法人所创立或者所持股设立的具有独立法律人格的新的法人组织，例如母公司的子公司。子公司虽由母公司控股，但子公司是独立的法人，它与母公司的财产和责任是彼此独立的。

二、企业法人分支机构的成立条件

（一）依法成立。

（二）有自己的名称、组织机构和住所。

（三）有一定的财产或者经费。

三、企业法人的分支机构的法律地位

我国相关立法承认法人的分支机构具有签约主体资格、诉讼主体资格和执行主体资格，不具有独立的责任主体资格，即分支机构进行民事法律行为所负民事责任由法人承担，而非由分支机构承担。

相关法条：《民法典》第七十四条 法人可以依法设立分支机构。法律、行政法规规定分支机构应当登记的，依照其规定。

分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。

第六节 法人的住所

一、法人住所的概念

法人的住所，是指法人的法律关系的中心地。

二、法人住所的确定

法人以它的主要办事机构所在地为住所。

相关法条：《民法典》第六十三条 法人以其主要办事机构所在地为住所。依法需要办理法人登记的，应当将主要办事机构所在地登记为住所。

第七节 法人的变更、终止与清算

一、法人的变更

（一）法人变更的概念

法人的变更，是指法人在存续期间内，法人组织上分立、合并以及在活动宗旨、业务范围上的变化。

（二）法人变更的类型

1、法人的合并

（1）概念

法人的合并，是指两个以上的法人合并为一个法人。

（2）分类

A、吸收合并

（A）吸收合并，是指一个法人归并到另一个现存的法人中去，参加合并的两个法人，只消灭一个法人，另一个法继续存在并吸收了已消灭的法人。

（B）吸收合并的特殊形式为一个法人分成若干部分并入其他法人之中，吸收已消灭的法人的，不是一个法人，而是几个法人。

B、新设合并

新设合并，是指两个以上的法人合并为一个新法人，原来的法人消灭，新的法人产生。

注意：对于法人合并后其债权债务关系的处理，法人合并后的债权债务关系由合并后的法人享有或承担。

2、法人的分立

（1）概念

法人的分立，是指一个法人分成两个以上的法人。

（2）分类

A、新设分立

新设分立，是指解散原法人，而分立为两个以上的新法人。

B、派生分立

派生分立，是指原法人存续，但从中分出新的法人。

注意：对于法人分立后原法人债权债务关系的处理，其权利和义务由分立后的法人享有连带债权，承担连带债务，但是债权人和债务人另有约定的除外。

3、组织形式的变更

（1）公司法人存在公司组织形式的变更问题。

（2）有限责任公司依照规定可以变更为股份有限公司；股份有限公司依照规定也可以变更为有限责任公司。

4、法人其他重要事项的变更

（1）法人其他重要事项的变更，是指法人的活动宗旨和业务范围等事项的变化。

（2）法人存续期间登记事项发生变化的，应当依法向登记机关申请变更登记。

（3）企业法人改变名称、住所、经营场所、法定代表人、经济性质、经营范围、经营方式、注册资金、经营期限以及增设或者撤销分支机构，均属重要事项的变更。

二、法人的终止

（一）法人终止的概念

法人的终止，又称为法人的消灭，是指法人丧失民事主体资格，其民事权利能力和民事行为能力终止。

（二）法人终止的原因

1、法人解散

法人解散，是指法人的目的事业完成或者无法完成，法人机关的决议、法人章程规定的存续期限届满或者解散事由的发生而自动解散的情况。

（1）法人章程规定的存续期间届满或者法人章程规定的其他解散事由出现；

（2）法人的权力机构决议解散；

（3）因法人合并或者分立需要解散；

（4）法人依法被吊销营业执照、登记证书，被责令关闭或者被撤销；

（5）法律规定的其他情形。

2、依法被宣告破产

法人被宣告破产，是指企业法人不能清偿到期债务时，人民法院可根据债权人或者债务人的申请，依法宣告其破产。

3、法律规定的其他原因（如国经济政策的调整和发生战争等。）

三、法人的清算

（一）法人清算的概念

法人清算，是指清理将终止的法人的财产，了结其作为当事人的法律关系，从而使法人归于消灭的必经程序。

注意：机关法人以及事业单位法人的解散适用法律或行政法规的特别规定，其他法人的解散除合并和分立情形外应当及时组成清算组进行清算。

（二）法人清算的种类

1、破产清算

破产清算，是指依破产法规定的清算程序进行清算。

2、非破产清算

非破产清算，是指不依破产法规定的清算程序进行清算。

（三）清算义务人和清算组

1、清算义务人概念与职责

（1）清算义务人，是指法人解散时对法人债权债务及时予以清算的义务人，法人的董事、理事等执行机构或者决策机构的成员为清算义务人。法律、行政法规另有规定的，依照其规定。（在营利法人中，董事会的董事或者执行董事为清算义务人，在非营利法人中，理事会的理事为清算义务人。）

（2）清算义务人的职责是及时清理法人的债权债务，清算义务人未及时履行清算义务造成损害的应当承担民事责任。

2、清算组的概念与职责

（1）清算组是指公司解散时为清理法人的债权债务而组成的清算小组，清算组既可以由清算义务人成立，也可以由主管机关中利害关系人申请，由人民法院指定有关人员成立清算组。

（2）清算组织的职责

A、清算公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；

B、通知、公告债权人；

C、处理与清算有关的公司未了结的业务；

D、清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；

E、清理债权、债务；

F、处理公司清偿债务后的剩余财产

G、代表公司参与民事诉讼活动。

（四）法人在清算期间的性质

（1）清算法人说

法人一经解散，即为法人的终止，法人的民事主体资格消灭。但是为了便于清算，应在清算时把原法人视为一个以清算为目的的清算法人，清算法人不享有原法人的民事权利能力和民事行为能力。

（2）同一法人说（通说）

法人的解散并不等同于法人的消灭，只有清算终结时，法人资格才归于消灭。虽然法人在清算期间，已经不能进行各种积极的民事活动，但它还必须以原法人的名义，对外享有债权和负担债务。在法人清算期间，法人资格仍然存续。

（3）拟制法人说

法人解散即为法人消灭，只是为了清算的目的，法律上拟制法人在清算目的范围内享有民事权利能力，从法人解散至清算完结视为法人仍然存续。

（五）清算终结

（1）清算终结，即清算人完成上述清算职责。

（2）清算结束并完成法人注销登记时，法人终止；依法不需要办理法人登记的，清算结束时，法人终止。

相关法条：《民法典》第六十七条 法人合并的，其权利和义务由合并后的法人享有和承担。

法人分立的，其权利和义务由分立后的法人享有连带债权，承担连带债务，但是债权人和债务人另有约定的除外。

相关法条：《民法典》第六十八条 有下列原因之一并依法完成清算、注销登记的，法人终止：

（一）法人解散；

（二）法人被宣告破产；

（三）法律规定的其他原因。

法人终止，法律、行政法规规定须经有关机关批准的，依照其规定。

相关法条：《民法典》第六十九条 有下列情形之一的，法人解散：

（一）法人章程规定的存续期间届满或者法人章程规定的其他解散事由出现；

（二）法人的权力机构决议解散；

（三）因法人合并或者分立需要解散；

（四）法人依法被吊销营业执照、登记证书，被责令

关闭或者被撤销；

（五）法律规定的其他情形。

相关法条：《民法典》第七十条 法人解散的，除合并或者分立的情形外，清算义务人应当及时组成清算组进行清算。

法人的董事、理事等执行机构或者决策机构的成员为清算义务人。法律、行政法规另有规定的，依照其规定。

清算义务人未及时履行清算义务，造成损害的，应当承担民事责任；主管机关或者利害关系人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

相关法条：《民法典》第七十一条 法人的清算程序和清算组职权，依照有关法律的规定；没有规定的，参照适用公司法的有关规定。

相关法条：《民法典》第七十二条 清算期间法人存续，但是不得从事与清算无关的活动。

法人清算后的剩余财产，根据法人章程的规定或者法人权力机构的决议处理。法律另有规定的，依照其规定。

清算结束并完成法人注销登记时，法人终止；依法不需要办理法人登记的，清算结束时，法人终止。

相关法条：《民法典》第七十三条 法人被宣告破产的，依法进行破产清算并完成法人注销登记时，法人终止。

第八节 法人的登记

一、法人登记的目的

法人的登记是法人取得民事权利能力和民事行为能力，乃至变更民事权利能力和民事行为能力及消灭民事权利能力和民事行为能力的要件。法人登记的目的在于保护相对人的利益，维护交易安全。此外，法人登记还有利于国家职能部门掌握情况，实现宏观经济调控。法人的成立必须采用公示方法，登记即为公示方法。

二、法人设立登记

（一）法人设立登记，是指法人依法成立，取得民事主体资格的要件。

（二）营利法人、部分事业单位法人和绝大多数社会团体法人应依法进行设立登记。

三、法人变更登记

（一）法人变更登记，是指法人将有关法人的变化情况向登记机关办理变更手续。

（二）对于因登记而取得法人资格的企业法人及部分社会团体法人和事业单位法人，其变更应予以登记，其登记机关为原登记机关。（对于非因登记而取得法人资格的机关法人及部分社会团体法人和事业单位法人，其变更则不须登记。）

（三）营利法人变更登记的事项通常包括：合并与分立，变更组织形式，增设或者撤销分支机构及法人经营范围，注册资本、住所、法定代表人、经营方式的变动等。

四、法人注销登记

（一）法人注销登记，是指法人依法终止，消灭其民事主体资格的要件。

（二）法人注销登记机关与设立登记机关相同，法人注销登记应提交的文件因法人种类不同而不同。

五、法人登记信息公开

登记机关应当依法及时公示法人登记的有关信息。

六、登记的效力

法人登记的效力，或为生效效力，或为对抗效力。

（一）营利法人的成立，只有经过成立登记，才能取得法人资格，即登记为法人成立的生效要件。

（二）事业单位法人经依法登记成立取得法人资格，但依法不需要登记的除外。

（三）社会团体法人经依法登记成立取得社会团体法人资格，但依法不需要办理登记的除外。

（四）除参加中国人民政治协商会议的人民团体，由国务院机构编制管理机关核定并经国务院批准免予登记的团体、机关、团体、企事业单位内部经本单位批准成立在本单位内部活动的团体外，其他社会团体须经过登记，才能取得法人资格。

（五）法人的其他登记仅具有对抗效力。

相关法条：《民法典》第六十四条 法人存续期间登记事项发生变化的，应当依法向登记机关申请变更登记。

相关法条：《民法典》第六十五条 法人的实际情况与登记的事项不一致的，不得对抗善意相对人。

相关法条：《民法典》第六十六条 登记机关应当依法及时公示法人登记的有关信息。

第九节 营利法人

一、营利法人的概念和特征

（一）营利法人的概念

营利法人是指以取得利润并分配给股东等出资人为目的成立的法人，即以营利为目的的法人。

（二）营利法人的特征

1、是以营利为目的法人

（1）营利法人具有依法营业的特点。

（2）营利法人具有连续营业的特点。

（3）营利法人以将其所获利润分配给出资者为目的。

2、必须具有独立财产

营利法人的财产是与出资者的财产彼此分离的。

3、是依核准登记程序成立的法人

营利法人是生产经营活动的主要参与者，为了规范经济秩序，其成立必须经过核准登记。

（三）营利法人的种类

1、有限责任公司

（1）有限责任公司又称有限公司，有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部的财产对公司的债务承担责任。

（2）有限责任公司既是我国营利法人的法定组织形式，又是我国营利法人的主要组织形式。

2、股份有限公司

股份有限公司又称股份公司，股份有限公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司债务承担责任，其中股票在证券交易所交易的股份有限公司又称“上市公司”，股份有限公司也是我国营利法人的法定组织形式和主要组织形式。

3、其他企业法人

除有限责任公司和股份有限公司外，其他企业法人也属于营利法人，如股份合作制企业。

注意：

1、邮政企业法人为省会城市的邮电局、邮政局、电信局以及市、县、大型矿山、部队等所在地设置的邮电局、电话局、长途电话局等，邮电所不具有法人资格。

2、人民银行总行和各商业银行总行具有法人资格，各银行分行、支行不具有法人资格。

3、保险分公司不具有法人资格。

4、各航空公司为法人，各机场（不包括临时机场）也为法人。

二、出资人违反不得滥用权利的义务的损害赔偿责任

（一）滥用出资人权利损害法人利益和其他出资人利益的，出资人应承担民事责任

股东不得滥用出资人权利损害公司利益和其他股东利益，如公司股东抽逃出资或者股本，公司股东故意转移公司财产，公司股东虚构债务侵害公司财产，公司股东违反《公司法》和公司章程损害公司利益的其他行为等，出资人滥用出资人权利给公司或者其他股东造成损害的应当承担民事责任。

（二）滥用法人独立地位和出资人有限责任损害债权人利益的，出资人对法人债务负连带责任（法人人格否认或公司人格否认）

1、公司资本显著不足，即公司资本不符合公司经营事业、规模或者经营风险的最低要求。

2、利用公司独立人格逃避合同义务，如为回避契约上特定的不作为义务而设立新公司等；“脱壳经营”行为，如控股股东为逃避原公司巨额债务而抽逃资金或解散公司或宣告该公司破产，再以原设备、场地、人员及相同经营目的而另设一新公司；当事人利用公司名义转移公司财产以逃避合同义务的行为。

3、滥用公司人格逃避法律义务或者获取非法利益的行为，如股东为避免其财产被强制执行而设立一新公司并将财产转移至该新公司，再如为享受本国公司的优惠而形式上设立一家符合该要求但事实上不符合该要求的公司。

4、公司与股东人格混同，这主要出现在一人公司和母子公司上，人格混同的基本特征为：

（1）财产混同，如股东财产和公司财产在经营上无严格区分。

（2）业务混同，如某公司完全以另一公司或股东的利益需要为准进行交易活动。

（3）组织机构混同，包括公司的意思机关、执行机关及监督机关发生混同，这主要出现在母子公司之中。

三、关联关系人利用关联关系损害法人利益的赔偿责任

（一）关联关系人

关联关系人包括营利法人的控股出资人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员。

1、控股出资人，又称控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2、实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

3、高级管理人员，是指公司的经理、副经理、财务负责人，上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员。

（二）关联关系的认定

关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

四、营利法人的社会责任

（一）营利法人的社会责任的概念

营利法人的社会责任，是指营利法人对消费者、社区和环境的责任。

（二）营利法人的社会责任的内容

1、支持并尊重对国际社会作出的维护人权的宣言。

2、不袒护侵犯人权的行为、劳动。

3、有效保证组建工会的自由与团体交涉的权利。

4、消除任何形式的强制劳动。

5、切实有效地废除童工。

6、杜绝在用工与职业方面的差别歧视。

7、主动承担环境保护责任。

8、推进环保技术的开发与普及。

9、积极采取措施反对强取和贿赂等任何形式的腐败行为等。

相关法条：《民法典》第七十六条 以取得利润并分配给股东等出资人为目的成立的法人，为营利法人。

营利法人包括有限责任公司、股份有限公司和其他企业法人等。

相关法条：《民法典》第七十七条 营利法人经依法登

记成立。

相关法条：《民法典》第七十八条 依法设立的营利法人，由登记机关发给营利法人营业执照。营业执照签发日期为营利法人的成立日期。

相关法条：《民法典》第七十九条 设立营利法人应当依法制定法人章程。

相关法条：《民法典》第八十条 营利法人应当设权力机构。

权力机构行使修改法人章程，选举或者更换执行机构、监督机构成员，以及法人章程规定的其他职权。

相关法条：《民法典》第八十一条 营利法人应当设执行机构。

执行机构行使召集权力机构会议，决定法人的经营计划和投资方案，决定法人内部管理机构的设置，以及法人章程规定的其他职权。

执行机构为董事会或者执行董事的，董事长、执行董事或者经理按照法人章程的规定担任法定代表人；未设董事会或者执行董事的，法人章程规定的主要负责人为其执行机构和法定代表人。

相关法条：《民法典》第八十二条 营利法人设监事会或者监事等监督机构的，监督机构依法行使检查法人财务，监督执行机构成员、高级管理人员执行法人职务的行为，以及法人章程规定的其他职权。

相关法条：《民法典》第八十三条 营利法人的出资人不得滥用出资人权利损害法人或者其他出资人的利益。滥用出资人权利给法人或者其他出资人造成损失的，应当依法承担民事责任。

营利法人的出资人不得滥用法人独立地位和出资人有限责任损害法人的债权人利益。滥用法人独立地位和出资人有限责任，逃避债务，严重损害法人的债权人利益的，应当对法人债务承担连带责任。

相关法条：《民法典》第八十四条 营利法人的控股出资人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害法人的利益。利用关联关系给**法**人造成损失的，应当承担赔偿责任。

相关法条：《民法典》第八十五条 营利法人的权力机构、执行机构作出决议的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规、法人章程，或者决议内容违反法人章程的，营利法人的出资人可以请求人民法院撤销该决议，但是营利法人依据该决议与善意相对人形成的民事法律关系不受影响。

相关法条：《民法典》第八十六条 营利法人从事经营活动，应当遵守商业道德，维护交易安全，接受政府和社会的监督，承担社会责任。

第十节 非营利法人

一、非营利法人的概念与特征

（一）非营利法人的概念与特征

1、非营利法人的概念

非营利法人,是指为公益目的或者其他非营利目的成立，不向出资人、设立人或者会员分配所取得利润的法人。

2、非营利法人的特征

（1）以公益为目的或者以其他非营利为目的成立。

以公益为目的，是指为适应社会经济发展需要，如从事文化、教育、卫生、体育、新闻等公益目的，而非以营利为目的。

（2）其所取得的利润不向出资人、设立人或者会员分配。

非营利法人虽然也从事一些经营活动，其经营活动也获得相应利润，如高等院校收取相应的学费，医院收取相应的治疗费、基金会用其资金进行投资获得投资利润等。

（3）非营利法人的成立有的需要依法办理登记，有的不需要办理法人登记，从成立时起即取得法人资格。

（4）非营利法人的财产或者来源于国家财政拨款；或者来源于国家财政拨款和相应经营收费；或者来源于社会捐助。

（5）非营利法人一般实行民主管理。

（6）为公益目的成立的非营利法人终止时，不得向出资人、设立人或者会员分配剩余财产。剩余财产应当按照法人章程的规定或者权力机构的决议用于公益目的；无法按照法人章程的规定或者权力机构的决议处理的，由主管机关主持转给宗旨相同或者相近的法人，并向社会公告。

二、事业单位法人

（一）事业单位法人的概念

事业单位法人，是指为了社会公益事业目的，从事文化、教育、卫生、体育、新闻等公益事业的单位。

（二）国有事业单位法人的分类

国有事业单位法人根据其性质不同，可分为：

（1）承担行政职能的事业单位，即承担行政决策、行政执行、行政监督等职能的事业单位。认定行政职能的主要依据是国家有关法律法规和中央有关政策规定。

（2）从事生产经营活动的事业单位，即所提供的产品或服务可以由市场配置资源、不承担公益服务职责的事业单位。（这类单位要逐步转为企业或撤销）

（3）从事公益服务的事业单位，即面向社会提供公益服务和为机关行使职能提供支持保障的事业单位。

（4）A、公益一类事业单位是指承担义务教育、基础性科研、公共文化、公共卫生及基层的基本医疗服务等基本公益服务，不能或不宜由市场配置资源的事业单位。公益一类事业单位不得从事经营活动。

B、公益二类事业单位是指承担高等教育、非营利医疗等公益服务，可部分由市场配置资源的事业单位。公益二类事业单位在确保公益目标的前提下，可依据相关法律法规提供与主业相关的服务。

C、公益二类事业单位是指承担高等教育、非营利医疗等公益服务，可部分由市场配置资源的事业单位。公益二类事业单位在确保公益目标的前提下，可依据相关法律法规提供与主业相关的服务。

注意：民办非企业单位，即企业事业单位、社会团体和其他社会力量以及公民个人利用非国有资产举办的，从事非营利性社会服务活动的社会组织。这类组织主要分布在教育、科研、文化、卫生、体育、交通、信息咨询、知识产权、法律服务、社会福利事业及经济监督事业的领域。民办非企业单位工多为民办事业单位，具备法人条件的应视为事业单位法人。

三、社会团体法人

（一）社会团体法人的概念

社会团体法人，是指自然人或者法人自愿组成，为实现会员共同意愿、按照其章程开展活动的非营利性社会组织。

（二）社会团体法人应具备的条件

1、社会团体由会员组成。

2、社会团体的宗旨是实现会员的共同愿望。

3、社会团体以非营利为目的。

（三）社会团体法人的分类

1、国家举办的社会团体法人（一般从成立之日起应具有法人资格，其经费主要由国家财政拨款。）

2、民间举办的社会团体法人（应依法登记取得法人资格，其经费主要由成员会费或捐助获得。）

四、捐助法人

捐助法人，是指以公益为目的，以社会捐助财产设立经依法登记成立的基金会法人、社会机构法人和宗教活动场所法人。

（一）基金会法人

1、基金会的概念

基金会，是指对国内外社会团体和其他组织以及个人自愿捐赠的资金进行管理以资助推进科学研究、文化教育、社会福利和其他公益事业发展为宗旨的民间非营利性组织。

2、基金会的特征

（1）其财产业源于社会捐赠。

（2）基金会法人没有会员。

3、基金会法人的分类

（1）国家主办的基金会法人（虽然其财产由社会捐助，但是由国家主办。）

（2）民间主办的基金会法人（由民间发起，财产由社会捐助而成立。）

（二）社会机构法人

1、社会机构法人的概念

社会机构法人是指为公益目的，以捐赠财产设立经依法登记的社会服务机构。（并非所有的社会服务机构都具有社会机构法人的资格，只有制定了法人章程，设立了理事会等决策机构，并经依法登记的社会机构才能取得社会机构法人资格。）

2、社会机构法人与基金会法人的区别

基金会法人是以资金资助实现社会公益目的；社会机构法人是以服务帮助实现社会公益。

（三）宗教活动场所法人

1、宗教活动场所法人的概念

宗教活动场所法人是以公益为目的，以捐赠财产设立，经依法登记的捐赠助法人。（并非所有的宗教活动场所都具有宗教活动场所法人的资格，只有制定了法人章程，成立了理事会等决策机构，并经依法登记的宗教活动场所才能取得宗教活动场所法人资格。）

2、确立宗教活动场所法人的意义

宗教活动场所所获得的善男信女的捐赠财产为宗教活动场法人所有，不为宗教人士个人所有或共有，也不为国家所有；宗教活动场所法人只能为非营利法人，不为营利法人，不能以股份公司或有限责任公司的形式出现，不能从事以营利为目的的经营性活动。

注意：宗教活动场所法人与宗教协会不同，宗教协会为社会团体法人，不是宗教活动场所法人。

相关法条：《民法典》第八十七条 为公益目的或者其他非营利目的成立，不向出资人、设立人或者会员分配所取得利润的法人，为非营利法人。

非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等。

相关法条：《民法典》第八十八条 具备法人条件，为适应经济社会发展需要，提供公益服务设立的事业单位，经依法登记成立，取得事业单位法人资格；依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有事业单位法人资格。

相关法条：《民法典》第八十九条 事业单位法人设理事会的，除法律另有规定外，理事会为其决策机构。事业单位法人的法定代表人依照法律、行政法规或者法人章程的规定产生。

相关法条：《民法典》第九十条 具备法人条件，基于会员共同意愿，为公益目的或者会员共同利益等非营利目的设立的社会团体，经依法登记成立，取得社会团体法人资格；依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有社会团体法人资格。

相关法条：《民法典》第九十一条 设立社会团体法人应当依法制定法人章程。

社会团体法人应当设会员大会或者会员代表大会等权力机构。

社会团体法人应当设理事会等执行机构。理事长或者会长等负责人按照法人章程的规定担任法定代表人。

相关法条：《民法典》第九十二条 具备法人条件，为公益目的以捐助财产设立的基金会、社会服务机构等，经依法登记成立，取得捐助法人资格。

依法设立的宗教活动场所，具备法人条件的，可以

申请法人登记，取得捐助法人资格。法律、行政法规对宗教活动场所有规定的，依照其规定。

相关法条：《民法典》第九十三条 设立捐助法人应当依法制定法人章程。

捐助法人应当设理事会、民主管理组织等决策机构，并设执行机构。理事长等负责人按照法人章程的规定担任法定代表人。

捐助法人应当设监事会等监督机构。

相关法条：《民法典》第九十四条 捐助人有权向捐助法人查询捐助财产的使用、管理情况，并提出意见和建议，捐助法人应当及时、如实答复。

捐助法人的决策机构、执行机构或者法定代表人作出决定的程序违反法律、行政法规、法人章程，或者决定内容违反法人章程的，捐助人等利害关系人或者主管机关可以请求人民法院撤销该决定，但是捐助法人依据该决定与善意相对人形成的民事法律关系不受影响。

相关法条：《民法典》第九十五条 为公益目的成立的非营利法人终止时，不得向出资人、设立人或者会员分配剩余财产。剩余财产应当按照法人章程的规定或者权力机构的决议用于公益目的；无法按照法人章程的规定或者权力机构的决议处理的，由主管机关主持转给宗旨相同或者相近的法人，并向社会公告。

第十节 特别法人

一、特别法人概念

特别法人，是指机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人。

二、机关法人

（一）机关法人的概念

机关法人，是指因行使职权的需要而享有相应的民事权利能力和民事行为能力的国家机关。

（二）机关法人的分类

机关法人包括权力机关法人、行政机关法人、司法机关法人和军事机关法人。

（1）权力机关法人，是指各级权力机构。

（2）行政机关法人，包括国务院及其职能机构和地方各级政府及其职能部门。

（3）司法机关法人，包括各级人民法院和各级人民检察院。

（4）军事机关法人，是指团以上具有独立编制的军事机关。

（三）机关法人的特征

（1）机关代表国家行使职权时，并不以法人的身份出现，它与有关社会组织或者自然人之间是领导与被领导或者监督与被监督的关系。

（2）机关因行使职权的需要而从事民事活动时，便是以法人的资格进行活动的，这时它与其他当事人处于平等的法律地位。

（3）机关法人与营利法人的区别是：机关法人从成立之日起就具有法人资格，而营利法人需经依法登记取得营业执照才具有法人资格；机关法人禁止经商，营利法人从事以营利为目的生产经营活动；机关法人的独立经费是由中央或者地方财政拨款而来，它主要用于参加各项必要民事活动。机关法人以自己的名言参加民事活动产生的债务，应以它的独立经费给予偿还，若超过经费而另需补 抵的，应由国家有关立法加以保证，而营利法人的财产由出资人出资所构成。

（4）机关法人与非营利法人的区别是：机关法人从事民事活动的目的主要是为了依法行使国家权力，非营利法人从事民事活动的目的主要是为了从事社会公益活动；机关法人的独立经费来源于国家财政拨款或者社会捐助或者经营所得；机关法人从成立之日起就具有法人资格，非营利法人多数需经依法登记才取得法人资格；机关法人对其占有的动产或不动产依法享有占有、使用和处分的权利，不享有收益权，财产所有权归国家所有，非营利法人对其财产依法享有所有权，国家主办的非营利法人的财产其所有权归国家，但享有占有、使用和依法收益、处分的权利。机关法人依法行使国家职权，在治理结构上不存在民主管理问题，非营利法人在治理结构上应实行民主管理。

三、农村集体经济组织法人

（一）农村集体经济组织法人的产生

在我国，农村集体经济组织产生于 20 世纪 50 年代的生产合作化运动，农村集体经济组织既为行政组织，又为生产经营组织，实现“政经合一”。作为行政组织，是国家政权机关的延伸部分，履行国家行政机关委托的相应的行政职能，作为生产经营组织，是该组织财产的所有权主体、生产经营活动的组织者等。

（二）农村集体经济组织法人的类型

农村集体经济组织法人包括乡镇农民集体经济组织法人、村农民集体经济组织法人、村民小组农民集体经济组织法人。

（三）农村集体经济组织法人的意义

1、农村集体土地的所有权主体为农村集体经济组织法人，不为集体组织成员共有。

2、农村集体经济组织法人是农村土地承包经营权合同中的发包方。

3、农村集体经济组织法人作为所办乡镇企业的出资人或股东，依法享有股权，并对投资收益享有所有权，乡镇企业的财产所有权应为该乡镇企业。

（4）农村集体经济组织法人在进行民事活动时具有民事主体地位，享有民事权利，履行民事义务，承担民事责任。

（四）农村集体经济组织法人的特殊性

1、其与营利法人的区别在于，农村集体经济组织依

法享有法人资格，不存在登记取得法人资格的问题；农村集体经济组织虽然从事生产经营活动，但不是以营利为唯一目的；农村集体经济组织所获利益主要用于集体经济组织成员的福利和农村集体经济组织所承担的管理职能的经费，而营利法人所获利益一般按出资比例分配给出资人。

（2）其与非营利法人的区别在于，农村集体经济组织不是为实现社会公益目的而存在，而是为行使委托的行政职能和行使集体经济组织财产所有权而存在。

四、城镇农村合作经济组织法人

（一）城镇农村合作经济组织法人的概念

城镇农村合作经济组织法人是劳动者自愿入股联合实现民主管理的经济组织法人。

（二）城镇合作经济组织法人的类型

1、生产合作社，即从事种植、采集、养殖、渔猎、牧养、加工、建筑等生产活动的各类合作社。

2、流通合作社，即从事推销、购买、运输等流通领域服务业务的合作社。

3、信用合作社，即接受社员存款贷款给社员的合作社。

4、服务合作社，即通过各种劳动、服务等方式，提供给社员生产生活一定便利条件的合作社。

（三）城镇农村经济合作组织法人的特征

1、须经登记依法设立。

2、成员自愿结合。

3、成员存在身份限制。

4、实行民主管理。

5、城镇农村经济合作组织的财产包括成员出资、公积金、国家补助、他人捐赠等。

（四）城镇农村经济合作组织法人的特殊性

1、其与营利法人的区别在于，城镇经济合作组织虽然存在营利之目的，但同时兼有帮助、扶持、合作之目的。营利法人的出资人一般不存在身份限制，城镇农村合作经济组织法人的成员存在身份限制。营利法人的财产由营利法人所有，出资人在出资方式、出资结构、出资种类上均依法律规定。

2、其与非营利法人的区别在于，城镇农村经济合作组织法人不以公益为目的，其所获利益按照章程规定按比例分配给合作组织成员。

五、基层群众性自治组织法人

（一）基层群众性自治组织法人的概念

基层群众自治性组织法人，是指居民委员会法人和村民委员会法人。

（二）基层群众性自治组织法人的特殊性

1、基层群众性自治组织法人是依照《居民委员会组织法》和《村民委员会组织法》设立的，不存在登记设立的问题。

2、基层群众性自治组织法人只能依法开展与其职能相关的民事活动。

（三）基层群众性自治组织法人的类型

1、居民委员会法人

（1）居民委员会的概念

居民委员会是居民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织。

（2）居民委员会的设立、撤销和规模调整

居民委员会根据居民居住状况，按照便于居民自治的原则，一般在一百户至七百户的范围内设立。居民委员会的设立、撤销、规模调整，由不设区的市、市辖区的人民政府决定。

（3）居民委员会为特别法人的意义

A、居民委员会为其财产的所有权人，其财产包括上级政府部门拨付的经费，向本聚居地的居民或受益单位筹集的经费及兴办服务业所获得收益。

B、居民委员会可作为民事主体开展便民利民的社会服务活动。居民委员会作为法人，在民事活动中享有民事权利、履行民事义务，承担民事责任。

2、村民委员会法人

（1）村民委员会的概念

村民委员会是村民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织，实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督。

（2）村民委员会的设立、撤销、范围调整

村民委员会根据村民居住状况、人口多少、按照便于群众自治，有利于经济发展和社会管理的原则设立。村民委员会的设立、撤销、范围调整，由乡、民族乡、镇的人民政府提出，经村民会议讨论同意，报县级人民政府批准。村民委员会可以根据村民居状况、集体土地所有权关系等分设若干村民小组织。

（3）村民委员会为特别法人的意义

A、村民委员会对于农村集体经济组织所有的土地和财产享有管理权。

B、村民委员会对其依法进行的民事活动享有民事权利，改造民事义务，承担民事责任。

C、未设村集体经济组织的，村民委员会可以依法代行村集体经济组织的职能。

相关法条：《民法典》第九十六条 本节规定的机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人，为特别法人。

相关法条：《民法典》第九十七条 有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构从成立之日起，具有机关法人资格，可以从事为履行职能所需要的民事活动。

相关法条：《民法典》第九十八条 机关法人被撤销的，法人终止，其民事权利和义务由继任的机关法人享有和承担；没有继任的机关法人的，由作出撤销决定的机关法人享有和承担。

相关法条：《民法典》第九十九条 农村集体经济组织依法取得法人资格。

法律、行政法规对农村集体经济组织有规定的，依

照其规定。

相关法条：《民法典》第九十九条 农村集体经济组织依法取得法人资格。

法律、行政法规对农村集体经济组织有规定的，依照其规定。

相关法条：《民法典》第一百条 城镇农村的合作经济组织依法取得法人资格。

法律、行政法规对农村集体经济组织有规定的，依照其规定。

相关法条：《民法典》第一百零一条 居民委员会、村民委员会具有基层群众性自治组织法人资格，可以从事为履行职能所需要的民事活动。

未设立村集体经济组织的，村民委员会可以依法代行村集体经济组织的职能。

第六章 非法人组织

第一节非法人组织概述

一、非法人组织的概念

（一）非法人组织的概念

非法人组织，又称为非法人团体，是指不具有法人资格但可以自己的名义进行民事活动的组织。

非法人组织的名称

1、德国：无权利能力社团

2、日本：非法人社团和非法人财团

3、台湾：非法人团体

注意：传统民法理论认为，非法人社团不包括合伙，合伙重视合伙成员的个人性，合伙人之间的关系是契约关系，合伙业务的执行专属于合伙人，合伙人的退伙对合伙有重大影响等。而非法人社团重视团体性，其业务执行属团体机关，成员变化对团体没有影响等。但是，现代合伙的发展，其团体属性的加强，使其越来越具有非法人组织的一般特性。（我国将合伙企业纳入非法人组织之列。）

二、非法人组织的特征

（一）非法人组织是组织体

1、非法人组织是人合组织体。

2、非法人组织虽然存在设立程序、机构设置、议事规则等事项，但这些更多的是由组织成员自己决定，法律对此一般不加规定。

（二）非法人组织是具有相应的民事权利能力和民事行为能力的组织体

非法人组织的民事权利能力和民事行为能力的享有是受限制的。

（三）非法人组织是<u>不能</u>完全独立承担民事责任的组织体

非法人组织的财产不足以清偿债务的，其出资人或设立人承担无限责任。法律另有规定的，依照其规定。

三、非法人组织应具备的要件

（一）须为有自己目的的社会组织体

目的，可以是非营利目的，也可以是营利目的（具有特定的经营范围）。

（二）须有自己的名称

非法人组织须有自己的名称并以组织的名义对外进行民事活动。

（三）须有自己能支配的财产或者经费

1、非法人组织并不要求财产或者经费属于自己独立享有，只要求独立支配即可。

2、非法人组织的财产也不要求必须与其成员的财产截然分开。

（四）应设有代表人或者管理人

非法人组织设有的代表人或者管理人，对外代表非法人组织，进行民事法律行为。

四、非法人组织的成立、解散与清算

（一）非法人组织的成立

非法人组织的成立<u>应当</u>办理设立登记，未办理设立登记的不能取得非法人组织的民事主体资格。对于涉及社会公益的非法人组织，还应依照相关法律规定由有关机关予以审批。

（二）非法人组织的解散

1、章程规定的存续期间届满或者章程规定的其他解散事由出现；

2、出资人或者设立人决定解散；

3、法律规定的其他情形。

（三）非法人组织的清算

非法人组织解散的，应当依法进行清算。在清算期间该非法人组织仍具有民事主体地位，其民事主体资格自办理注销登记之日起消灭。非法人组织的清算义务人和清算程序可参照法人清算的规定。

相关法条：《民法典》第一百零二条 非法人组织是不具有法人资格，但是能够依法以自己的名义从事民事活动的组织。

非法人组织包括个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的专业服务机构等。

相关法条：《民法典》第一百零三条 非法人组织应当依照法律的规定登记。

设立非法人组织，法律、行政法规规定须经有关机关批准的，依照其规定。

相关法条：《民法典》第一百零四条 非法人组织的财产不足以清偿债务的，其出资人或者设立人承担无限责任。法律另有规定的，依照其规定。

相关法条：《民法典》第一百零五条 非法人组织可以确定一人或者数人代表该组织从事民事活动。

相关法条：《民法典》第一百零六条 有下列情形之一的，非法人组织解散：

（一）章程规定的存续期间届满或者章程规定的其他解散事由出现；

（二）出资人或者设立人决定解散；

（三）法律规定的其他情形。

相关法条：《民法典》第一百零七条 非法人组织解散的，应当依法进行清算。

相关法条：《民法典》第一百零八条 非法人组织除适用本章规定外，参照适用本法第三章第一节的有关规定。

第二节 合伙

一、合伙概述

（一）合伙的含义与法律地位

1、合伙的含义与种类

（1）合伙的含义

合伙，是指二个以上的人互约出资，经营共同事业。

A、人，包括自然人、法人和其他组织。

B、事业，包括多种行业，可以是营利性的事务，也可以是非营利性的事务。

（2）合伙的种类

A、普通合伙与有限合伙（我国现行法律明文区分普通合伙与有限合伙）

B、民事合伙与商事合伙（我国现行法律没有明文区分民事合伙和商事合伙。民事合伙由民法典规定。商事合伙由商法典或者商事单行法规定。民事合伙不以营利为目的，商事合伙以营利为目的。）

2、合伙的法律地位

（1）合伙是一种独立的民事主体（合伙人格的相对独立性；合伙财产的相对独立性；合伙民事责任的相对独立性。）

（2）合伙不是一种独立的民事主体

注意：

1、实践中有些合伙虽然有二个以上的人出资，经营共同事业，但是没有合伙名称，组织松散，或者是临时性的，其性质属于合伙合同，没有民事主体资格。

2、隐名合伙（隐名合伙合同，是指当事人双方约定一方以其名义经营事业，另一方对一方所经营的事业出资并分享其经营所得的利益和在出资限度内分担经营亏损的合同。）也仅仅是合同关系，没有民事主体资格。

（二）关于合伙的基本法律规定（《合伙企业法》）

1、合伙企业，是指自然人、法人和其他组织依照合伙企业法在中国境内设立的普通合伙企业和有限合伙企业。

2、国有独资公司、国有企业、上市公司及公益性的事业单位、社会团体不得成为普通合伙人。

3、合伙协议依法由全体合伙人协商一致，以书面形式订立。

4、设立合伙企业需要根据法定条件和法定程序进行登记。

5、合伙企业设立分支机构，应当向分支机构所在地的企业登记机关申请登记，领取营业执照。

注意：

1、我国存在非企业合伙组织。（非营利性普通合伙）（民办非企业单位，是指企业单位、社会团体和其他社会力量以及公民个人利用非国有资产举办的，从事非营利性社会服务活动的社会组织。）

2、民办非企业单位的条件

（1）经业务主管单位审查同意

（2）有规范的名称、必要的组织机构

（3）有与其业务活动相应的从业人员

（4）有与其业务活动相应的合法财产

（5）有必要的场所

3、民办非企业单位经过登记，根据其依法承担民事责任的不同方式，分别发给《民办非企业单位（法人）登记证书》、《民办非企业单位（合伙）登记证书》、《民办非企业单位（个体）登记证书》。根据该条例规定的登记内容，发给《民办非企业单位（合伙）登记证书》的，应当具有民事主体资格。

4、民办非企业合伙的活动应当根据合伙协议进行，但不能违反《民法典》规定的有关基本原则和其他有关法律的强制性规定。

二、普通合伙

（一）普通合伙的概念与特征

1、普通合伙的概念

普通合伙，是指由两上以上的人根据协议，互约出资，经营共同事业，并对合伙债务承担无限连带责任的社会组织。

注意：普通合伙是常见的合伙形式，如果未加“有限”的限制词，通常说的合伙是指普通合伙，而且通常称“合伙”。

2、普通合伙的特征

（1）由两个以上的人组成的组织。

（2）合伙协议是合伙形成的基础条件。

（3）合伙人共同出资、共同经营、共享收益、共担风险，并对合伙的债务承担无限连带责任

（二）合伙的成立

1、有两上以上合伙人。（合伙人为自然人的，应当具有完全民事行为能力。）

2、有书面合伙协议。（合伙协议应当载明的事项，包括合伙企业的名称和主要经营场所的地点、合伙人的姓名或者名称、地址等。）

3、有合伙人认缴或者实际缴付的出资。（合伙人可以用货币、实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利出资，也可以用劳务出资。）

4、有合伙企业的名称和生产经营场所。（合伙企业的名称应当标明“普通合伙”字样。）

（三）合伙的财产

1、合伙财产的构成

（1）合伙人的出资。

（2）合伙从事经营活动取得的财产。

（3）依法从其他渠道取得的财产。

2、合伙财产的性质

合伙企业的财产属于合伙人按份共有。（为了维护合伙企业经营的连续性，对合伙人请求分割合伙企业中的财产份额及用合伙企业中的财产设定质押，法律规定了特别的限制。）

3、合伙财产的保全

（1）分割合伙财产的限制

合伙人在合伙企业清算前，不得请求分割合伙企业的财产（不包括退伙的情况在内），合伙人在合伙企业清算前私自转移或者处分合伙企业财产的，合伙企业不得以此对抗善意的第三人。

（2）财产份额转让与财产出质的限制

除合伙协议另有约定外，合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的全部或者部分财产份额时，须经其他合伙人一致同意。合伙人以其在合伙企业中的财产份额出质的，须经其他合伙人一致同意。

（3）合伙债权抵销与合伙人的债权人代位权的限制

合伙人发生与合伙企业无关的债务，相关债权人不得以其债权抵销其对合伙企业的债务；合伙人的债权人也不得代位行使合伙人在合伙企业中的权利。

（四）合伙事务执行

1、合伙事务执行权与执行人

（1）合伙人对执行合伙事务享有同等的权利。

A、每个合伙人都有合伙事务的执行权

B、合伙人之间互为代理

（2）内部合伙事务的执行有三种情况：

A、全体合伙人共同为合伙事务执行人。

B、几名合伙人为合伙事务执行人，合伙人可以约定某几名合伙人为合伙事务的执行人，也可以约定某些合伙事务由某几名合伙人为合伙事务执行人。

C、合伙负责人为合伙事务执行人，全体合伙人推荐能力强、威信高的合伙人为负责人，由负责人执行合伙事务。

（3）对外合伙事务执行，可以按照合伙协议约定或者经全体合伙人决定，委托一个或数个合伙人对外代表合伙，执行合伙事务。

（4）合伙企业对合伙人执行合伙事务以及对外代表合伙企业权利的限制，不得对抗善意的第三人。

注意：

企业的代表人不同于法人的代表人，法人的代表人是法人机关，合伙的代表人不是合伙机关。合伙的代表人在被委托执行合伙事务的范围内享有代表权，执行合伙事务的委托撤销或者合伙人辞去委托时，代表权随之终止。

（5）合伙企业可以聘任合伙人以外的人为合伙企业的经营管理人员，被聘人员被授权管理合伙内部事务，也可以被授权对外代表合伙企业。受聘人员按照授权进行的经营管理活动，其法律后果由合伙企业承担。

2、合伙事务执行人的权利与义务

（1）合伙事务执行人的权利

A、报酬请求权

B、提出异议权

（A）合伙人分别执行合伙事务的，执行合伙人可以对其他合伙人执行的事务提出异议。提出异议时，应当暂停该项事务的执行。

（B）不执行事务的合伙人提出异议，合伙事务可以不停止执行，可通过要求召开合伙人会议等方式对合伙的经营进行监督。

（2）合伙事务执行人的义务

A、忠实处理合伙事务的义务

合伙人对于合伙事务应亲自执行，合伙事务执行人借执行合伙事务谋取私利，给合伙企业或者其他合伙人造成损失的，应当承担赔偿责任。

B、报告义务

由一个或者数个合伙人执行合伙事务的，执行事务合伙人应当定期向合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营和财产状况。

C、遵守竞业禁止义务与交易禁止义务

（A）合伙人不得自营或者同他人合作经营与本合伙企业相竞争的业务。除合伙协议另有约定或者经全体合伙人一致同意外，合伙人不得同本合伙企业进行交易。

（B）合伙人违反法律规定或者合伙协议的约定，从事与本合伙企业相竞争的业务或者与本合伙企业进行交易的，该收益归合伙企业所有；给合伙企业或者其他合伙人造成损失的，依法承担赔偿责任。

3、合伙决议的表决权

（1）合伙人对合伙企业有关事项的决议，按照合伙协议约定的表决办法办理。

（2）合伙协议未约定或者约定不明确的，实行合伙人一人一票并经全体合伙人过半数通过的表决方法。

（3）除合伙协议另有约定外，下列事项应当经全体合伙人一致同意：

A、改变合伙企业的名称。

B、改变合伙企业的经营范围、主要经营场所的地点。

C、处分合伙企业的不动产。

D、转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利。

E、以合伙企业的名义为他人担保。

F、聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员。

4、对合伙事务执行的监督

（1）根据法律规定和合伙协议的约定，不执行合伙事务的合伙人有参与对合伙重大事务决定的权利和其他权利，包括了解合伙的经营状况和财务状况、监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况等权利。

（2）受委托执行合伙事务的合伙人不按照合伙协议或者全体合伙人的决定执行事务的，其他合伙人可以

撤销委托。

5、合伙人增加或者减少出资

合伙人按照合伙协议的约定或者经全体合伙人决定，可以增加或者减少对合伙企业的出资。（需要合伙人按照合伙协议的约定或者经全体合伙人决定。）

（五）合伙损益的分配与合伙债务的承担

1、合伙损益的分配

合伙利润的分配、亏损的分担，有合伙协议按合伙协议办理；合伙协议未约定或者约定不明确的，由合伙人协商决定。但是，合伙协议不得约定将全部利润分配给部分合伙人或者由部分合伙人承担全部亏损。合伙协议未约定或者约定不明确，又协商不成的，根据法律规定办理，即由合伙人按照实缴出资比例分配、分担；无法确定比例的，由合伙人平均分配、分担。（损益分配的时间由合伙人约定）

2、合伙债务的承担与清偿

（1）合伙企业对于其债务，应先以其全部财产进行清偿。合伙企业不能清偿到期债务的，合伙人承担无限连带责任。合伙人由于承担无限连带责任，清偿数额超过其应当承担的比例的，有权向其他合伙人追偿。（补充连带主义）

（2）合伙人以个人财产出资的，以合伙人的个人财产承担无限责任；合伙人以其家庭共有财产出资的，以其家庭共有财产承担无限责任；合伙人以个人财产出资，合伙的盈余分配所得用于其家庭成员生活的，应先以合伙人的个人财产承担，不足部分以合伙人的家庭共有财产承担无限责任。

（3）合伙人的自有财产不足清偿其与合伙企业无关的债务的，该合伙人可以以其从合伙企业中分取的收益用于清偿；债权人也可以依法请求人民法院强制执行该合伙人在合伙企业中的财产份额用于清偿。

★双重优先原则：

同时存在合伙债务与合伙个人债务，当合伙与合伙人都处于资不抵债的情况时，合伙人个人的债权人优先于合伙的债权人从合伙人的个人财产中得到清偿，合伙的债权人优先于合伙人个人的债权人从合伙财产中得到清偿。换句话说，合伙的财产优先清偿合伙的债务，合伙个人的财产优先清偿个人的债务。

（六）入伙、退伙

1、入伙

（1）入伙的概念

入伙，是指非合伙人加入已成立的合伙，而取得合伙人资格的行为。

（2）入伙的程序

合伙企业接纳新合伙人，除合伙协议另有约定外，应当经全体合伙人一致同意，并依法订立书面入伙协议。

（3）入伙的效力

A、入伙人与原合伙人依法签订入伙协议书后即取得合伙人的资格。

B、入伙的新合伙人与原合伙人享有同等的权利，承担同样的责任。入伙协议另有约定的，从其约定。

C、新入伙人对入伙前的合伙债务承担无限连带责任。

2、退伙

（1）退伙的概念

退伙，是指合伙人在合伙存续期间退出合伙组织，消灭合伙人资格的行为。

（2）退伙的形式

根据退伙的原因不同，可将退伙分为自愿退伙、除名退伙和法定退伙。

A、自愿退伙

a、自愿退伙，是指合伙人依约定或单方面向其他合伙人声明退伙。

b、合伙协议约定了合伙企业经营期限，出现下列情形之一的，合伙人可以退伙：①合伙协议约定的退伙事由出现；②经全体合伙人一致同意；③发生合伙人难于继续参加合伙的事由；④其他合伙人严重违反协议约定的义务。

c、合伙协议未约定合伙企业的经营期限的，合伙人在不给合伙企业事务执行造成不良影响的情况下可以退伙，并应提前 30 日通知其他合伙人。

d、合伙人违反《合伙企业法》上述规定退伙的，应当赔偿由此给合伙企业造成的损失。

B、除名退伙

a、除名退伙，又称为强制退伙，是指当某合伙人出现除名事由时，经体体合伙人一致同意，将合伙人开除，而使其丧失合伙人资格。

b、除名退伙的事由包括：①未履行出资义务；②因故意或重大过失给合伙企业造成损失；③执行合伙事务有不当行为；④发生合伙协议约定的事由。

c、对合伙人的除名决议，应当书面通知被除名人。被除名人接到除名通知之日起，除名生效。被除名人对除名决议有异议的，可在自接到除名通知之日起 30 日内向人民法院起诉。

C、法定退伙

a、法定退伙，又称为当然退伙，是指基于法律的事由而退伙。

b、法定退伙的事由包括：①作为合伙人的自然人死亡或者被依法宣告死亡；②个人丧失偿债能力；③作为合伙人的法人或者其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭、撤销，或者被宣告破产；④法律规定或者合伙协议约定合伙人必须具有相关资格而丧失相关资格⑤合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行。

c、退伙事由发生之日为退伙生效日。

（3）退伙的效力

A、退伙人的合伙人资格丧失

a、合伙人死亡或者被依法宣告死亡的，对该合伙人

在合伙企业中的财产份额享有合法继承权的继承人，按照合伙协议的约定或者经全体合伙人一致同意，从继承开始之日起，取得该合伙企业的合伙人资格。但是，有下列情形之一的，合伙企业应当向合伙人的继承人退还被继承合伙人的财产份额：一是继承人不愿意成为合伙人；二是法律规定或者合伙协议约定合伙人必须具备相关资格，而该继承人未取得该资格；三是合伙协议约定不能成为合伙人的其他情形

b、合伙的继承人为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人，经全体合伙人一致同意，可以依法成为有限合伙人，普通合伙企业依法转为有限合伙企业。全体合伙人未能一致同意的，合伙企业应当将被继承合伙人的财产份额退还给该继承人。

B、退伙人财产份额的退还办法

退伙人在合伙企业中的财产份额的退还办法，由合伙协议约定或者由全体合伙人决定，可以退还货币，也可以退还实物。

C、退伙人对合伙亏损的分担

a、合伙人退伙时，合伙企业财产少于合伙企业债务的，退伙人应当依照其应分担的比例分担亏损。

b、退伙人应对基于退伙前的原因发生的合伙企业债务，承担无限连带责任。

（七）特殊的普通合伙

1、特殊的普通合伙的概念与特征

（1）特殊的普通合伙的概念

特殊的普通合伙，是指在特定情况下，不由全体合伙人对合伙债务承担无限连带责任的普通合伙。

（2）特殊的普通合伙的特征

A、特殊的普通合伙是普通合伙的一种特殊形式

特殊的普通合伙的特殊性在于，在特定情况下各合伙人对合伙债务承担的责任不同；除此之外，都适用普通合伙的规定。

B、在特定情况下不由全体合伙人对合伙债务承担无限连带责任

a、一个合伙人或者数个合伙人在执业活动中因故意或者重大过失造成的合伙债务，应当承担无限责任或者无限连带责任，其他合伙人以其在合伙中的财产份额为限承担责任。

b、合伙人在执业活动中非因故意或者重大过失造成的合伙债务以及合伙的其他债务，由全体合伙人承担无限连带责任。

2、特殊的普通合伙的设立与名称

特殊的普通合伙的设立程序与普通合伙的设立程序相同，但是其名称应当标明“特殊普通合伙”字样。

3、特殊的普通合伙的适用范围

（1）以专业知识和专门技能为客户提供有偿服务的专业服务机构（会计师事务所、评估师事务所、建筑师事务所等），可以设立为特殊的普通合伙企业。

（2）非企业专业服务机构依据有关法律采取合伙制的，其合伙人承担责任的形式可以适用《合伙企业法》关于特殊的普通合伙企业合伙人承担责任的规定。

4、有过错的合伙人的责任承担

（1）一个合伙人在执业活动中因故意或者重大过失造成的合伙债务，应当承担无限责任，数个合伙人在执业活动中因故意或者重大过失造成的合伙债务，应当承担无限连带责任，其他合伙人以其在合伙中的财产份额为限承担责任。

（2）在合伙人在在执业活动中因故意或者重大过失造成合伙债务时，仍然按照合伙及合伙人对外清偿合伙企业债务顺序的规定，合伙的债务首先由合伙财产清偿，合伙财产不足以清偿其债务时，才由合伙人清偿。

（3）合伙人在执业活动中因故意或者重大过失造成的合伙债务，以合伙财产对外承担责任后，该合伙人应当按照合伙协议的约定对合伙造成的损失承担赔偿责任。如果合伙协议的约定不要求有过错的合伙人承担赔偿责任，从其约定。

5、执业风险基金的建立

特殊的普通合伙企业应当建立执业风险基金、办理职业保险；执业风险基金用于偿付合伙人执业活动造成的债务。

三、有限合伙

（一）有限合伙的概念与特征

1、有限合伙的概念

有限合伙，是指由对合伙债务承担有限责任的有限合伙人和对合伙债务承担无限责任的普通合伙人共同组成的合伙。

2、有限合伙的特征

（1）有限责任与无限责任相结合

A、在一个合伙企业中，普通合伙人对合伙的债务承担无限连带责任，有限合伙人对合伙的债务承担有限责任。

B、与有限公司相比，普通合伙人直接经营管理合伙事务，组织结构和组成程序简单，操作灵活。

C、与普通合伙相比，有限合伙人对合伙债务承担有限责任，有利于吸收投资。

D、通常有限合伙主要适用于从事高科技项目的风险投资，也适用于一般中小企业。

（2）由普通合伙人执行合伙事务

A、有限合伙由具有专业知识和技能的人作为普通合伙人，执行合伙事务。

B、有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表有限合伙。

（二）有限合伙的设立

有限合伙的设立，除需要具备普通合伙具备的条件外，还需要具备法律规定的与普通合伙不同的条件：

1、有 2 个以上 50 个以下的合伙人组成，其中至少有一个普通合伙人。

2、有与普通合伙协议内容不同的合伙协。（有限合伙协议除具有普通合伙应当载明的事项外）

（一）普通合伙人和有限合伙人的姓名或者名称、住所。

（二）执行事务合伙人应具备的条件和选择程序。

（三）执行事务合伙人权限与违约处理办法。

（四）执行事务合伙人的除名条件和更换程序。

（五）有限合伙人入伙、退伙的条件、程序以及相关责任。

（六）有限合伙人和普通合伙人相互转变程序。

3、有限合伙名称中应当标明"有限合伙"字样。

4、有限合伙人的出资。

（1）有限合伙人可以用货币、实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利作价出资。有限合伙人不得以劳务出资。

（2）有限合伙人应当按照合伙协议的约定按期足额缴纳出资；未按期足额缴纳的，应当承担补缴义务，并对其他合伙人承担违约责任。

（3）有限合伙企业登记事项中应当载明有限合伙人的姓名或者名称及认缴的出资数额 。

（三）有限合伙事务的执行

1、有限合伙由普通合伙人执行合伙事务，对外代表有限合伙。

（1）有限合伙由普通合伙人执行合伙事务时，应当遵守法律关于普通合伙的合伙人执行事务的规定，其具体办法由普通合伙人协议决定。

（2）有限合伙协议可以确定给予合伙事务执行人一定的报酬及报酬提取方式。

2、如果有限合伙人参与执行合伙事务，就应当承担无限连带责任。（表见合伙，是指第三人有理由相信有限合伙人为普通合伙人并与其交易的，该有限合伙人对该笔交易承担与普通合伙人同样的责任。）

3、有限合伙人未经授权以有限合伙的名义与他人进行交易，给有限合伙或者其他合伙人造成损失的，该有限合伙人应当承担赔偿责任。

4、在有限合伙中有限合伙人享有相应的权利，行使其权利的行为不属于执行合伙事务。参与决定普通合伙人入伙、退伙；对企业的经营管理提出建议；参与选择承办有限合伙企业审计业务的会计师事务所；获取经审计的有限合伙企业财务会计报告；对涉及自身利益的情况，查阅有限合伙企业财务会计账簿等财务资料；在有限合伙企业中的利益受到侵害时，向有责任的合伙人主张权利或者提起诉讼；执行事务合伙人怠于行使权利时，督促其行使权利或者为了本企业的利益以自己的名义提起诉讼；依法为本企业提供担保。

（四）有限合伙利润的分配

有限合伙企业不得将全部利润分配给部分合伙人；但是，合伙协议另有约定的除外。

（五）有限合伙人特有的权利与特殊规定

1、有限合伙人特有的权利（合伙协议另有约定的除外）

有限合伙人特有的权利，是指有限合伙人享有而普通合伙人不享有的权利。

（1）有限合伙人可以与本合伙进行交易。

（2）有限合伙人可以自营或者同他人合作经营与本合伙相竞争的业务。

2、有限合伙人的特殊规定（合伙协议另有约定的除外）

有限合伙人的特殊规定，是指同一事项，对有限合伙人的限制不像对普通合伙人限制那样严格。

（1）有限合伙人可以将其在合伙中的财产出质，不需要经其他合伙人一致同意。

（2）有限合伙人可以按照合伙协议的约定向合伙人以外的人转让其在有限合伙企业中的财产份额，不需要经其他合伙人一致同意。（转让其份额的有限合伙人应当提前 30 日通知其他合伙人）

（六）有限合伙人的入伙、退伙

1、入伙

新入伙的有限合伙人对入伙前有限合伙的债务，以其认缴的出资额为限承担责任。

2、退伙

（1）有限合伙人退伙的条件与普通合伙人退伙的条件主要不同之处在于：

A、作为有限合伙人的自然人在有限合伙存续期间丧失民事行为能力的，其他合伙人不得因此要求其退伙。（如果合伙协议约定有限合伙人丧失行为能力为退伙事由，从其约定。）

B、作为有限合伙人的自然人死亡、被依法宣告死亡或者作为有限合伙的法人及其他组织终止时，其继承人或者权利承受人可以依法取得该有限合伙人在合伙企业中的资格。

（2）有限合伙人退伙后，对基于其退伙前的原因发生的有限合伙债务，以其退伙时从有限合伙中取回的财产承担责任。

（七）有限合伙人与普通合伙人的相互转变

1、有限合伙人与普通合伙人的相互转变，除合伙协议另有约定外，其转变应当经全体合伙人一致同意。

2、有限合伙人转变为普通合伙人的，对其作为有限合伙人期间合伙发生的债务承担无限连带责任。

3、普通合伙人转变为有限合伙人的，对其作为普通合伙人期间合伙发生的债务承担无限连带责任。

（八）有限合伙的解散与转变

1、有限合伙仅剩余有限合伙人的，应当解散。

2、有限合伙仅剩余普通合伙人的，转为普通合伙企业。如果普通合伙人不愿意继续合作或者仅剩下一个普通合伙人，有限合伙即解散。

四、合伙的解散与清算

（一）合伙的解散

1、合伙解散的概念

合伙的解散，又称为合伙的终止，是指由于法定原因的出现或全体合伙人的约定使合伙关系消灭。

2、合伙解散的事由

（1）合伙期限届满，合伙人决定不再经营。

（2）合伙协议约定的解散事由出现。

（3）全体合伙人决定解散。

（4）合伙人已不具备法定人数满三十天。

（5）合伙协议约定的合伙目的已经实现或者无法实现。

（6）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销。

（7）法律、行政法规规定的其他原因。

3、合伙解散的后果

（1）合伙解散并不是合伙立即消灭，合伙解散后，应当开始清算。

（2）在清算期间合伙视为存续，合伙的活动限于与清算有关的事务，不得开展与清算无关的经营活动。

（二）合伙的清算

1、清算人

（1）清算人由全体合伙人担任；经全体合伙人过半数同意，可以自合伙企业解散后 15 日内指定一个或数个合伙人，或者委托第三人，担任清算人。

（2）自合伙企业解散事由出现之日起 15 日内未确定清算人的，合伙人或者其他利害关系人可以申请人民法院指定清算人。

2、清算事务

（1）清理合伙企业财产，分别编制资产负债表和财产清单。

（2）处理与清算有关的合伙企业未了结事务。

（3）清缴所欠税款。

（4）清理债权、债务。

（5）处理合伙企业清偿债务后的剩余财产。

（6）代表合伙企业参加诉讼或者仲裁活动。

清算人自被确定之日起十日内将合伙企业解散事项通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算人申报债权。

3、清偿与分配顺序

（1）清算费用。

（2）职工工资、社会保险费用、法定补助金。

（3）所欠税款。

（4）清偿债务。

（5）剩余的财产按照各合伙人应得的比例进行分配。

清算结束，清算人应当编制清算报告，经全体合伙人签名、盖章后，在十五日内向企业登记机关报送清算报告，申请办理合伙企业注销登记。

4、合伙企业注销后合伙人对合伙债务的责任

（1）合伙注销后，原合伙人对合伙企业存续期间的债务，仍应承担清偿责任。普通合伙人承担无限连带责任；特殊的普通合伙的合伙人一般承担无限连带责任，但是对于部分合伙人在执业活动中因故意或者重大过失造成的合伙债务，其他合伙人以其在合伙企业中的财产份额为限承担责任。在有限合伙企业中，普通合伙人承担无限连带责任，有限合伙人以其出资为限承担责任。

（2）合伙企业注销后，原合伙人清偿对合伙企业存续期间的债务应当有期限限制，即适用《民法典》一般诉讼时效期间的规定。

5、注销登记

清算结束，清算人应当编制清算报告，经全体合伙人签名、盖章后，在 15 日内向企业登记机关报送清算报告，申请办理企业注销登记。

第三节 其他非法人组织

一、个人独资企业

（一）个人独资企业的概念与特征

1、个人独资企业的概念

个人独资企业，是指一个自然人投资，财产属投资人个人所有，投资人以其个人财产对企业债务承担无限责任的经营实体。

2、个人独资企业的特征

（1）一个自然人出资，生产资料归投资者所有。

（2）雇工经营。

（3）具有一定的规模。（有投资者申报的资金；有自己的名称；有一定数量的从业人员；有固定的生产经营场所和必要的生产经营条件；有一套符合法律、法规的企业管理和财务、会计制度等。）

（二）个人独资企业的法律地位

1、自然人

2、非法人组织（个人独资企业具有团体性要件；有自己的经营目的和经营范围；不能独立承担民事责任。）

二、筹建中的法人

（一）筹建中的法人的概念与特征

1、筹建中的法人的概念与

筹建中的法人，又称为设立中的法人，是指为设立法人组织而进行筹建活动的非法人组织。（我国只规定了法人设立人而未规定筹建中的法人）

2、筹建中的法人的特征

（1）筹建中的法人是一种组织，而非筹建人或者设立人个人。

（2）筹建中的法人是为设立法人而存在的组织体。

（3）筹建中的法人是非法人组织，而不是法人。

（二）筹建中的法人的法律地位

1、筹建人或者设立人的个人行为。

2、同一体说，即筹建中的法人与成立后的法人视为同一法人。

（三）筹建中的法人的民事权利能力

筹建中的法人具有相应的民事权利能力，但受到以下限制：

1、应以筹建或者设立所必要的事项为限享有民事权利能力。

2、应以将来法人成立为条件享有民事权利能力。

三、其他

一、不具备法人条件的是中外合作企业和外资企业。（登记）

二、企、事业单位开办的不具有法人资格的经营实体。（登记）

三、不具有法人资格的专业服务机构。（登记）

四、不具有法人资格的公益团体。（登记）

第三分编 民事法律关系客体

第七章 民事法律关系客体的种类

第一节 民事法律关系客体概述

一、民事法律关系客体的概念与特征

（一）民事权利客体的概念

民事法律关系的客体，又称为民事权利客体，是指民事法律关系主体享有的民事权利和承担的民事义务所共同指向的对象。（物质利益与非物质利益）

注意：自罗马法以来的法律思想认为，民事法律关系的客体是权利客体，又称权利标的。权利客体受权利主体支配，权利客体远较“物”的概念含义广泛，是指受权利主体支配的各种权利的对象，不仅包括物，而且包括各种权利、利益以及无财产价值的作为或者不作为。

（二）民事法律关系客体的特征

1、利益性

2、客观性

二、民事法律关系客体的范围

（一）物

（二）行为

（三）智力成果

（四）有价证券

（五）权利

（六）非物质利益

（七）数据、虚拟财产

（八）自然人的个人信息

第二节 物

一、物的概念与特征

（一）物的概念

物，是指存在于人身之外，能够满足人们的社会需要而又能为人所实际控制或者支配的物质客体。

（二）物的特征

1、物存在于人身之外

2、物能满足人们的社会需要

3、物能为人所实际控制或者支配

4、物一般指有体物

5、物须有独立性

二、物的法律意义

（一）物是绝大多数民事法律关系的客体。

（二）物在很大程度上决定着民事法律关系的有效与否。

（三）物在某些情况下关系到案件的管辖。

三、物的分类

（一）动产与不动产

以物是否能够移动并且移动是否损害其价值为标准，可将物分为动产与不动产。

1、动产

动产，是指能够移动而不损害其价值或用途的物。

（1）在法律上各种可以支配控制的自然力，在性质上认定为动产。

（2）某些物在性质上能够移动，但因价值较高，且在交易习惯上转让程序较为慎重，在法律上亦具有不动产的某些特征，在学理上称为“准不动产”。

2、不动产

不动产，是指不能移动或者移动会损害其用途或者价值的物。

（1）土地（一定范围的地球表面，以及地面上空及地下）

A、地球表面不一定完全为土壤所覆盖，如有沟渠、水池等杂处其间，也属土地的一部分。

B、对于地面下的矿产资源，如煤炭、石油、天然气、虽为土地的一部分，但基于国民经济的通盘考虑，法律规定为国家所有。

（2）地上定着物（持续密切依附于土地，不易移动，按交易惯例非为土地的构成部分，而有独立使用价值的物。）

A、最主要的定着物是指房屋及其他建筑物。

B、依附于土地但在性质上成为土地一部分的财产，如水井、水沟、下水道，应成为土地的一部分，而非定着物；仅为临时或者非密 切依附于土地的建筑，如临时搭建的为建筑所用的工棚，为展览所用的展览棚等，都非定着物。

3、区分动产与不动产的意义

（1）物权变动的法定要件不同

（2）物权类型不同

（3）诉讼管辖不同

（二）流通物与限制流通物

以物在民事流转过程中是否受限制以及受限制的程度为标准，可将物分为流通物或限制流通物。

1、流通物

流通物，又称为融通物，是指法律允许民事主体之间依法定程序自由流转的物。

2、限制流通物

（1）限制流通物，又称为限制融通物，是指法律对

其流转给予一定程度的限制或禁止自由流转的物。

（2）限制流通物主要有专属国家所有的财产和非专属国家所有的财产。

3、区分流通物与限制流通物的意义

明确某一具体的物可以设立法律关系的性质与范围。

（三）特定物与种类物

以物是否具有独立的特征或者是否被权利人指定而特定化为标准，可将物分为特定物和种类物。

1、特定物

（1）特定物，又称为不可替代物，是指自身具有独立的特征，或者被权利人指定而特定化，不能以其他物代替的物。

（2）特定物包括在特定条件下独一无二的物和从一类物中根据民事主体的意志指定而特定化的物。

2、种类物

种类物，又称为可替代物，是指具有共同的特征，能以品种、规格、质量或者度量加以确定的物。

3、区分特定物与种类物的意义

（1）有些法律关系只能以特定物为标的物；而有些法律关系的标的物既可以是特定物也可以是种类物。

（2）物意外灭失的法律后果不同。

（四）主物与从物

根据两个物在物理上相互独立、而在经济用途上又相互联系的关系，可将物分为主物和从物。

1、主物

主物，是指在必须结合使用才能发挥经济效益的两个独立的物中，起主要作用的物。

2、从物

（1）从物，是指在两个独立物结合使用中处于附属地位，起辅助和配合作用的物。

（2）从物的条件

A、从物之使用目的须具有永久性。

B、从物与主物同属于一人。

C、从物须具有独立性，不为主物的部分。

D、须交易上视为从物。

（3）区分主物与从物的意义

在法律没有相反规定或者当事人没有相反约定时，从物的所有权属于主物的所有人，对此主物所有人无证明义务；主物的所有权转移，从物的所有权转移；担保物权的效力及于从物；解除主物合同的效力及于从物合同，但解除从物合同的效力不能及于主物合同。

（五）原物与孳息

以物的产生关系不同为标准，物可以分为原物和孳息。

1、原物

原物，是指依照法律规定或者依其自然性质产生新物的物。

2、孳息

（1）孳息，是指因物或者权益而生的收益。

（2）孳息可分为天然孳息（即直接孳息，依照物的自然性质而产生的收益物）和法定孳息（即间接孳息，依照法律规定产生的收益物）。

注意：

（1）随着劳动价值论的出现，劳动作为人们取得财产所有权的重要方式成为社会的共识，劳动生产物（农民所种的粮食、矿主的所挖的矿石、煤炭等），不再为孳息。

（2）随着管理学的出现，经营管理创造价值。因经营管理所产生的收益，特别是投资收益（因理财产生的收益、租赁经营的收益、股份投资的红利等）也应从孳息中间分离出来。

3、区分原物与孳息的意义

确定孳息收取权。天然孳息，由所有权人取得；既有所有权人又有用益物权人的，由用益物权人取得。当事人另有约定的，按照约定。法定孳息，当事人有约定的，按照约定取得；没有约定或者约定不明确的，按照交易习惯取得。标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有，交付之后产生的孳息，归买受人所有。质权人有权收取质物所生孳息，但另有约定的除外。

（六）可分物与不可分物

以物能否分割，以及分割是否损害其用途及价值为标准，可将物分为可分物与不可分物。

1、可分物

可分物，是指可以分割并且不因分割而损害其用途及价值的物。

2、不可分物

不可分物，是指按照物的性质不能分割，或者分割将损害其用途及价值的物。

3、区分可分物与不可分物的意义

（1）便于共有财产的分割

（2）便于明确多数人之债的债权债务

（七）消耗物与非消耗物

以物经使用后的形态变化性为标准，可将物分为消耗物与非消耗物。

1、消耗物

消耗物，又称为消费物，是指一次使用就归于消灭或者改变原有形态和性质的物。

2、非消耗物

非消耗物，又称为不消费物，是指可以长期多次使用，并不会改变其形态和性质的物。

3、区分消耗物与非消耗物的意义

消耗物不能作为转移物的使用权的债的标的物，只能作为消费借贷或者转移所有权等债的标的物；非消耗物可以成为转移使用权的债的标的物。

（八）有主物与无主物

以物在一定时期内是否有所有人为标准，可将物分

为有主物与无主物。

1、有主物

有主物，是指所有人明确的物。

2、无主物

无主物，是指没有所有人的物。

3、区分有主物与无主物的意义

（1）对于无主物，当事人可以依法以自己单方意志取得；对于有主物，不存在先占取得所有权的问题。

（2）确定无主物的归属。

（九）单一物、合成物与集合物

以物是由一个还是多个独立物构成为标准，可将物分为单一物、合成物与集合物。

1、单一物

单一物，是指独立成一体的物。

2、合成物

合成物，是指由数个单一物构成的，在法律上或者观念上视为一物的物。

3、集合物

集合物，是指由数个单一物或合成物聚合而成的，在法律上或者观念上视为一物的物的总体。

4、区分单一物、合成物和集合物的意义

无论是哪种物，作为权利的客体时，在法律上观念上都是一个完整的物。（在作为物权客体时，单一物、合成物与集合物有同一的法律性质，只能对物的整体设定一个所有权或者相容的数个他物权，或者另行设定他物权；在作为交易客体时，不得随意变更物的组合状况，否则将构成债的不履行。）

四、货币

（一）货币的概念

货币是充当一般等价物的特殊商品，属于民法上的种类物。

（二）货币在民事法律关系中的作用

1、担当物权的客体，自然人、法人及其他非法人组织可以对货币行使占有、使用、收益和处分的权利。

2、充当债权的标的物。

（三）货币的特殊性

1、货币占有权与所有权合二为一，货币的占有人视为货币所有人。

2、货币所有权的转移以交付为要件，即使在借款合同中，转移的也是货币所有权，而非货币的使用权。无行为能力人交付的货币也发生所有权的转移。

3、货币不发生返还请求权与占有回复诉权问题，仅能基于合同关系、不当得利或者侵权行为提出相应的请求。

第三节 有价证券

一、有价证券的概念与法律特征

（一）有价证券的概念

有价证券，是指设定并证明持券人有权取得一定财产权利的书面凭证。

（二）有价证券的法律特征

1、有价证券与证券上所记载的财产权利不能分离。

2、有价证券的债务人是特定的，即证券的权利人只能向证券上记载的债务人请求实现债权。而有价证券的债权人则可因证券的转让而发生变更。

3、有价证券的债务人的支付是单方义务，债务人不得请求权利人支付相应对价。

二、有价证券的分类

（一）依有价证券所设定的财产权利的性质不同所作的分类

1、设定一定股份权利的有价证券

2、设定一定物权的有价证券

3、设定一定债权的有价证券

（二）依有价证券记载权利人的方式不同所作的分类

1、记名有价证券

2、无记名有价证券

3、指示有价证券

（三）依有价证券指定的权利标的是金钱或者物品或者服务所作的分类

1、金钱证券

2、物品证券

3、服务证券

（四）依有价证券的给付人为标准所作的分类

1、自付证券

2、委托证券

三、有价证券的主要类型

（一）票据

1、汇票

2、本票

3、支票

（二）债券

1、公债券

2、企业债券

（三）股票

（四）提单

第四节 智力成果

一、智力成果的概念与法律特征

（一）智力成果的概念

智力成果，又称为知识产品，是指人们通过创造性劳动创造的，具有一定表现形式的成果。

（二）智力成果的法律特征

1、创造性

2、非物质性

3、公开性

二、智力成果的主要类型

（一）作品

（二）发明

（三）实用新型

（四）外观设计

（五）科学发现
（六）商标
（七）地理标志
（八）商业秘密
（九）集成电路布图设计
（十）植物新物种

第五节 其他客体

一、权利

权利成为民事法律关系客体的条件：

（一）必须是财产权利，人身权利通常不可成为民事法律关系的客体。

（二）必须是可转让的财产权利，不可转让的财产权利不可成为民事法律关系的客体。

（三）必须是法律规定可成为民事法律关系客体的权利。

二、非物质利益

非物质利益又称人身非物质利益或者精神利益，是物质利益或者财产利益的对称。

（一）就自然人而言，非物质利益包括生命、健康、自由、名誉、个人秘密等；就法人和其他社会组织而言，非物质利益包括名称、名誉（或商业信誉）等。

（二）非物质利益作为民事法律关系客体的特点是其不可转让性和不可转移性，除非法律有明确的规定。

三、虚拟财产

（一）虚拟财产是指在网络游戏中为玩家所拥有、存储于网络服务器上的、以特定电磁记录为表现形式的无形财产。

（二）虚拟财产作为一种新型财产，不仅具有一般财产的属性，如合法性、价值性等，还具有虚拟性、网络依附性等独特特征。

四、自然人个人信息

（一）自然人个人信息的范围包括自然人人格身份信息（姓名、职业、职务、年龄、血型、身高、指纹、病史、婚姻状况、宗教信仰、学历、兴趣爱好、专业资格、工作经历、家庭住址、电话号码、身份证号码等，）和自然人财产信息（信用卡号码、电子邮件、Q户账号、网络游戏装备、网店等）

（二）自然人个人信息是自然人个人信息权的客体，自然人个人信息权包含信息决定权、信息查阅权、信息反对权、信息封锁权、信息删除权和信息更正权。

第四分编 民事法律关系变动

第八章 民事法律行为

第一节 民事法律行为概述

一、法律行为、民事行为、民事法律行为的概念

（一）法律行为

1、理论上

（1）法律行为（合法行为）

（2）现代民法意义上的法律行为（以设权的意思表示行为）

2、立法方面

（1）外国：法律行为

（2）我国：民事法律行为

（二）民事行为

民事行为，是以意思表示为要素，发生民事法律后果的行为，包括民事法律行为、无效的民事行为、可撤销的民事行为、效力未定的民事行为。（《民法通则》的相关规定。民事行为是民事法律行为的上位概念，但不包括事实行为。）

（三）民事法律行为

民事法律行为是民事主体通过意思表示设立、变更、终止民事法律关系的行为。

二、民事法律行为的特征

（一）民事法律行为是民事法律事实的一种。

（二）民事法律行为是民事主体实施的以发生民事法律后果为目的的行为。

（三）民事法律行为是以意思表示为构成要素的行为。

三、民事法律行为与情谊行为、准民事法律行为

（一）民事法律行为与情谊行为

情谊行为，又称好意施惠行为，是指当事人因社交、帮助、道义等原因发生的，没有民法上的权利义务意思内容的行为。

（二）民事法律行为与准民事法律行为

1、准民事法律行为是表意行为之一种，但其效力非基于表意人的表意，而是基于法律的规定。

2、准民事法律行为可分为催告、通知和宽恕。

四、民事法律行为的分类

（一）单方行为、双方行为、多方行为

以是否由当事人一方的意思即可成立为标准，可以将民事法律行为分为单方行为、双方行为和多方行为。

1、单方行为，是指仅由一方行为人的意思表示就能成立的民事法律行为。

2、双方行为，是指由行为人双方相对的意思表示达成一致而成立的民事法律行为。

3、多方行为，是指由多个行为人的意思表示达成一致而成立的民事法律行为。

4、区分单方行为、双方行为、多方行为的意义

法律对三者成立的要求有所不同，单方行为，只要行为人一方作出意思表示，民事法律行为就成立；双方行为和多方行为一般则需要各方行为人的意思表示达成一致，民事法律行为方能成立（只有行为人一方的意思表示，民事法律行为不能成立）。

（二）财产行为与身份行为

以民事法律行为发生的效果的内容是财产性的、还是身份性的，可以将民事法律行为分为财产行为和身

份行为。

1、财产行为，是指以发生财产上法律效果为目的的行为，财产行为的后果是在当事人之间发生财产权利义务的变动。

2、身份行为，是指以发生身份上法律效果为目的的行为，身份行为的后果是在当事人之间发生身份关系的变动。

3、区分财产行为和身份行为的意义

（1）适用法律规范不同。财产行为主要适用财产法规范；身份行为主要适用身份法规范。

（2）法律效果的性质不同。财产行为的目的是取得财产权；身份行为的目的在于取得或者丧失身份权，维持伦理秩序，应特别尊重当事人的意思，通常不能由代理人代理。

（三）有偿行为与无偿行为

以民事法律行为的双方是否承担对待给付义务为标准，可以将民事法律行为分为有偿行为与无偿行为。

1、有偿行为，是指双方承担互为对待给付义务的民事法律行为。

2、无偿行为，是指一方当事人承担给付义务而对方当事人不承担给付义务的民事法律行为。

（四）诺成性行为与实践性行为

以民事法律行为的成立是否以实际交付实物为标准，可以将民事法律行为分为诺成性行为和实践性行为。

1、诺成性行为，是指当事人之间仅以意思表示为成立要件，无须交付实物就能够成立的民事法律行为。

2、实践性行为，是指当事人之间除了意思表示一致之外，还必须实际交付实物才能够成立的民事法律行为。

（五）要式行为与不要式行为

以民事法律行为的成立是否必须依照某种特定的形式为标准，可以将民事法律行为分为要式行为和不要式行为。

1、要式行为，是指依法律规定或者依约定，必须采取一定形式或者履行一定程序才能成立的行为。

2、不要式行为，是指法律不要求特定形式，行为人自由选择一种形式即能成立的行为。

3、区分要式行为和不要式行为的意义

不要式行为由当事人自由选择行为方式，要式行为当事人须采用法定方式。

注意：现代民法以方式自由为原则，除法律特别规定或者当事人特别约定外，均为不要式行为。

（六）主行为与从行为

以民事法律行为内容上的主从关系为标准，可以将民事法律行为划分为主行为和从行为。

1、主行为，是指不需要有其他行为的存在就可以独立成立的行为。

2、从行为，是指以其他行为的存在为前提的行为。

3、区分主行为和从行为的意义

从行为具有附随性，主行为无效或者消灭的，从行为也随之无效或者消灭。

（七）独立行为与辅助行为

以民事法律行为有无独立的实质性内容为标准，可以将民事法律行为分为独立行为和辅助行为。

1、独立行为，是指行为人凭借其意思表示即可成立的行为。

2、辅助行为，是指并不具有独立的内容，而仅仅是辅助其他行为生效的行为。

3、区分独立行为和辅助行为的意义

辅助行为只不过是独立行为生效的条件，自身没有独立的实质内容，而受其辅助的独立行为在没有辅助行为之前不生效。

（八）有因行为与无因行为

以民事法律行为与原因的关系为标准，可以将民事法律行为分为有因行为和无因行为。

1、有因行为，是指与原因不可分离的行为。

2、无因行为，是指行为与原因可以分离，不以原因为要素的行为。

3、区分有因行为和无因行为的意义

有因行为如原因不存在，则行为无效；而无因行为，原因不存在或者有瑕疵时，行为有效，仅发生不当得利问题。

五、民事法律行为的形式

（一）口头形式

口头形式，是指用谈话的方式进行意思表示，包括当面交谈、电话交谈等。

（二）书面形式

书面形式，是指以书面文字的方式进行意思表示。

1、一般书面形式

（1）一般书面形式，是指用文字来进行意思表示。

（2）一般书面形式，或为当事人约定采用，或为法律、法规规定采用。

（3）一般书面形式在民事法律行为中，具有不同的效力，即证据效力、成立效力和生效效力。

2、特殊书面形式

（1）特殊书面形式，主要指公证形式。（公证，是指行为人将其书面形式的民事法律行为交国家公证机关认证，使民事法律行为的真实性和合法性得到确认。）

（2）公证形式可以是法律的，也可以是当事人约定的，但多数是当事人之间约定采用的。

（3）公证文书具有较强的证明力，根据《民事诉讼法》及有关司法解释，公证债权文书是人民法院据以执行的法律文书，人民法院可以依据公证债权文书直接开始执行程序。

（三）默示形式

默示形式，是指行为人并不直接表示其内在意思，只是根据其某种行为（作为或不作为），按照逻辑推理的方法或者按照生活习惯推断出其内在意思的形式。

1、推定形式

推定形式，是指行为人并不直接用口头形式或者书面形式进行意思表示，而是通过实施某种行为来进行意思表示。

2、沉默形式

（1）沉默形式，是指行为人既不用语言表示，又不用积极行为表示，而是以消极的不作为的方式进行意思表示，即根据行为人的沉默来认定其具有某种意思。

（2）沉默只有在有法律规定、当事人约定或者符合当事人之间的交易习惯时，才可以视为意思表示。

相关法条：《民法典》第一百三十三条 民事法律行为是民事主体通过意思表示设立、变更、终止民事法律关系的行为。

相关法条：《民法典》第一百三十四条 民事法律行为可以基于双方或者多方的意思表示一致成立，也可以基于单方的意思表示成立。

法人、非法人组织依照法律或者章程规定的议事方式和表决程序作出决议的，该决议行为成立。

相关法条：《民法典》第一百三十五条 民事法律行为可以采用书面形式、口头形式或者其他形式；法律、行政法规规定或者当事人约定采用特定形式的，应当采用特定形式。

相关法条：《民法典》第一百三十六条 民事法律行为自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

行为人非依法律规定或者未经对方同意，不得擅自变更或者解除民事法律行为。

相关法条：《民总解释》第十八条 当事人未采用书面形式或者口头形式，但是实施的行为本身表明已经作出相应意思表示，并符合民事法律行为成立条件的，人民法院可以认定为民法典第一百三十五条规定的采用其他形式实施的民事法律行为。

第二节 意思表示

一、意思表示的概念与构成要素

（一）意思表示的概念

意思表示，是指行为人把进行某一民事法律行为的内心效果意思，以一定的方式表达于外部的行为。

（二）意思表示的构成要素

意思表示的构成要素，是指构成意思表示所必须具备的事实要素。

1、目的意思

目的意思，是指明民事法律行为具体内容的意思，它是意思表示据以成立的基础。

2、效果意思

效果意思，又称为法效意思、效力意思，是指意思表示人使其表示内容引起法律上效果的意思，即具有设立、变更、终止民事法律关系的意图。

3、表示行为

表示行为，是指行为人将内心意思以一定方式表现于外部，并足以为外界客观理解的行为。

二、意思表示的分类

（一）有相对人的意思表示与无相对人的意思表示

根据意思表示应否向相对人表示，意思表示可分为有相对人的意思表示与无相对人的意思表示。

1、有相对人的意思表示，是指表意人应向相对人为意思表示。

2、无相对人的意思表示，是指无须向相对人所为的意思表示。

3、区分有相对人的意思表示与无相对人的意思表示的意义

（1）有相对人的意思表示必须于到达相对人时才发生效力；无相对人的意思表示一般于意思表示完成时，立即发生效力，也有的在意思表示后遗嘱人死亡时发生法律效力。

（2）有相对人的意思表示的解释，文义解释居于中心地位，结合相关条款、行为性质和目的、习惯及诚信原则确立意思表示含义；无相对人的意思表示的解释，文义解释不居于中心地位，结合相关条款、行为性质和目的、习惯及诚信原则确立意思表示含义。

（二）对话的意思表示与非对话的意思表示

1、对话的意思表示，是指在有相对人的双方意思表示中，相对人可同步受领的意思表示。

2、非对话的意思表示，是指在有相对人的双方意思表示中，相对人不可同步受领的意思表示。

3、区分对话的意思表示与非对话的意思表示的意义

对话的意思表示与非对话的意思表示的生效时间不同：对话的意思表示从意思表示到达对方，处于客观上可了解的状态时起发生效力。至于相对人是否了解，则应依一般的情形而定。非对话的意思表示采用<u>到达主义</u>，即于意思表示到达相对人的支配范围时发生效力。（以非对话方式作出的采用数据电文形式的意思表示，相对人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统时生效；未指定特定系统的，相对人知道该数据电文进入其系统时生效。当事人对采用数据电文形式的意思表示的生效时间另有约定的，按照其约定。)

（三）独立的意思表示与非独立的意思表示

1、独立的意思表示，是指表意人独立完成且发生效力的意思表示。

2、非独立的意思表示，是指必待他人的意思表示，始能成立民事法律行为的意思表示。

3、区分独立的意思表示与非独立的意思表示的意义

独立的意思表示构成单方法律行为，非独立的意思

表示构成双方行为或者多方行为。

（四）明示的意思表示与默示的意思表示

1、明示的意思表示，是指行为人以语言、文字或者其他直接表意方法表示内在意思的表意形式。

2、默示的意思表示，是指从行为人的某种作为或不作为中推断出来的意思表示。

3、区分明示的意思表示与默示的意思表示的意义

有的意思表示必须是明示的；默示的意思表示必须在法律有明确规定或者有交易习惯或当事人有特别约定时才发生效力。

（五）健全的意思表示与不健全的意思表示

1、健全的意思表示，是指行为人出于真心或及自由的意思所为的表示。

2、不健全的意思表示，是指行为人并非出于真意的或者不自由的意思表示。

3、区分健全的意思表示与不健全的意思表示的意义

健全的意思表示与不健全的意思表示的效力不同，健全的意思表示为有效的意思表示，不健全的意思表示影响民事法律行为的效力。

三、意思表示的撤回

（一）意思表示的撤回的概念

意思表示的撤回，是指行为人作出意思表示后又撤回该意思表示，从而使该未生效的意思表示不发生效力的行为。

（二）意思表示撤回的作出

对于有相对人的意思表示，其意思表示的撤回通知应当在意思表示到达相对人之前或者与意思表示同时到达相对人；对于无相对人的意思表示，因其意思表示自表示完成时就发生效力，因此一般不发生意思表示的撤回问题，除非法律另有规定。

四、意思表示的解释

意思表示的解释，是指依照法律规定的原则和方式，阐明并确定当事人已为意思表示的正确含义。

（一）意思表示解释的原则

1、意思主义

（1）意思主义认为，意思表示的实质在于行为人的内心意思，民事法律行为本身是实现行为人意思自治的手段。因此对意思表示解释时，应贯彻探求真意而不拘泥于词语原则。

（2）意思主义的优点是反映了具体表意人的个性化要求，有利于保护表意人的意志自由和利益，保护私有财产的静态利益；缺点是不利于交易的安全和预期，不利于保护财产的动态利益，不利于对相对人利益的保护。

2、表示主义

（1）表示主义认为，内心的效果意思虽然是意思表示的起源，但当事人表现于客观效果的意思却是意思表示的核心或者根本。因此对意思表示进行解释时应贯彻客观主义原则，在表示与意思不一致的情况下，应以外部的表示为准，对于相对人意思表示的解释应当以相对人足以合理客观了解的表示内容为准。

（2）表示主义有利于保护相对人的利益，但不利于保护表意人的利益，可能放纵胁迫、欺诈等行为。

3、折衷主义

（1）折衷主义认为，当意思与表示不一致时，效力的重点既不绝对地放在意思上，亦不绝对地放在表示上，而根据具体情况或者以意思主义为原则，表示主义为例外；或者以表示主义为原则，意思主义为例外。

（2）折衷主义全面考虑各种利益的衡平关系，既顾及相对人利益与交易安全，又顾及表意方利益。

（二）意思表示解释的方法

1、文意解释

文意解释，是指通过对意思表示所使用的文字词句的含义的解释，以探求当事人的真实意思。

2、体系解释

体系解释，是指把意思表示的全部条款和构成部分看做一个统一的整体，从各个条款以及构成部分的相互关联、所处地位的总体联系上，阐释当事人有争议的用语的含义。

3、目的解释

目的解释，是指如果意思表示所使用的文字或某个条款有可能作两种解释时，应采取最适合于意思表示的目的的解释。

4、习惯解释

习惯解释，是指意思表示所使用的文字词句有疑义时，应参照当事人的习惯进行解释，包括语言习惯、行为习惯、交易习惯等。

5、诚信解释

诚信解释，是指对意思表示进行解释时，应遵循诚实信用原则进行的解释。

四、意思与表示不一致

意思与表示不一致，是指表意人的内心意思与外在表示不一致。

（一）单独虚伪表示

1、单独虚伪表示的概念

单独虚伪表示，又称为真意保留、心中保留，是指表意人把真实意思保留心中，所作出的表示行为并不反映其真实意思，它是一种自知并非真意的意思表示。

2、单独虚伪表示的构成要件

（1）一方当事人实施的虚伪表示行为，在内容上具有法律价值，并使人感觉其愿受其约束。

（2）当事人表示的意思与真实意思不一致，并且自知其不一致，并且不期望发生效力，也不准备履行所发生的义务。

3、单独虚伪表示的效力

单独虚伪表示原则上有效，表意人应受该表示的约束，但相对人明知表意人的表示与意思不一致的，该

表意行为无效。

（二）通谋的虚伪表示

1、通谋的虚伪表示的概念

通谋的虚伪表示，又称为伪装表示或虚伪表示，是指表意人与相对人通谋，不表示内心真意的意思表示。

2、通谋的虚伪表示的构成要件

（1）表意人欠缺内心的真意。

（2）表意人此项非真意的意思表示为对方所明知。

（3）对方故意实施非真意的合意表示。

3、通谋的虚伪表示的效力

表意人与相对人通谋所为的意思表示原则上无效，但不得以其无效对抗善意第三人。

（三）隐藏行为

1、隐藏行为的概念

隐藏行为，是指表意人为虚假的意思表示，但其真意为发生另外法律效果的意思表示。

2、隐藏行为的效力

隐藏行为中的虚假意思表示无效，隐藏的真实意思表示是否有效，应依该真实意思的相关法律确定。

（四）错误

1、错误的概念与构成要件

（1）错误的概念

错误，是指表意人为表意时，因认识不正确或者欠缺认识，以致内心的真实意思与外部的表现行为不一致。

（2）错误的构成要件

A、错误是由表意人自己的原因造成的。

B、表意人的内心真意与表示不一致。

C、表意人不知其内心真意与表示不一致。

D、错误必须具有严重性，即足以影响表意人决定为意思表示。

E、错误是否存在，以意思表示成立时为决定标准。

2、错误的种类

（1）动机错误

A、动机错误，是指在特别容易发生错误的意志形成阶段发生的错误。

B、在动机错误的情况下，表意人一般不得因此撤销民事法律行为。

（2）内容错误

A、内容错误，是指在发出意思表示时对其内容发生错误。（对当事人的错误、行为性质的错误、标的物本身的错误。）

B、在内容错误的情况下，表意人可以撤销民事法律行为。

（3）表示行为的错误

A、表示行为的错误，是指表意人若知其事情即不为该意思表示。

B、表示行为错误可成为撤销之理由。

（4）传达错误（属于表示行为错误）

A、传达错误，是指由于传达人或者传递机关的错误而使表意人的意思表示发生的错误。

B、在传达错误的情况下，表意人可以撤销民事法律行为。

（5）受领人错误

A、受领人错误，又称误解，是指受领人受错误理解的影响而作出的意思表示。

B、在受领人错误的情况下，受领人可以撤销民事法律行为。

注意：《民法典》并未直接规定错误，而是规定了重大误解。所谓重大误解，包含了错误和误解两个概念，包括了表意人的认识和表达错误，相对人的理解和表达错误，以及表意人的错误陈述（非欺诈）等情形。在司法实践中是指，行为人因对行为的性质、对方当事人、标的物的品种、质量、规格和数量等的错误认识，使行为的后果与自己的意思相悖，并造成较大损失的，可以认定为重大误解。

五、意思表示的不自由

意思表示的不自由，是指由于他人的不当干涉，使意思表示存在瑕疵。

（一）欺诈

1、欺诈的概念

欺诈，是指当事人一方故意编造虚假情况或者隐瞒真实情况，使对方陷入错误而为违背自己真实意思表示的行为。

2、欺诈的构成要件

（1）须有欺诈人的欺诈行为

A、无意识或者精神错乱中的所为不为欺诈，无行为能力人的欺诈不为欺诈。

B、欺诈情形有三：一是捏造虚伪事实；二是隐匿真实事实；三是歪曲真实事实。

C、沉默以行为人是否具有告知义务为限。

D、主观意见陈述以行为人是否具有故意为标准。

（2）欺诈人必须有欺诈的故意

A、使相对人陷于错误的认识，如果行为人非明知其表述的事实为虚假或者虽明知其表述之事为虚假，而无使相对人陷于错误的意思，不为欺诈。

B、使相对人因其错误而为一定意思表示的意思，因此行为人虽明知其所表示的事实为虚假，而无利用相对人的错误使其为一定意思表示的意思，不为欺诈。注意：行为人有无取得财产利益的意思，及使相对人受财产损失的意思，对欺诈的成立，没有影响。

（3）须表意人因相对人的欺诈而陷入错误

陷入错误，不仅指表意人原无错误，受欺诈人的欺诈而陷于错误，而且包括表意人已有错误，受欺诈人的欺诈而陷于更深的错误。

（4）须对方因陷于错误而为意思表示

A、无此错误，则根本不为意思表示。

B、无此错误，则不以此条件为意思表示。

注意：对于消费欺诈行为的认定存有争议，但一般认为经营者出卖的商品只存在较小瑕疵，而非假冒伪劣商品的，应认定为违约行为而非消费欺诈。

注意：第三人欺诈构成欺诈的条件除符合欺诈的上述构成要件外还要求对方知道或者应当知道该欺诈行为。

（二）胁迫

1、胁迫的概念

（1）胁迫包括威胁和强迫。

（2）威胁，是指行为人一方以未来的不法损害相恐吓，使对方陷入恐惧，并因此作出有违自己真实意思的表示。

（3）强迫，是指行为人一方以现时的身体强制，使对方处于无法反抗的境地而作出的有违自己真实意思的表示。

2、胁迫的构成要件

（1）须胁迫人有胁迫的行为

A、胁迫行为既可以是直接对相对人实施，也可对其亲友实施。

B、胁迫的对象不仅包括人的生命、身体健康和自由，也包括人的名誉、荣誉、隐私及财产。

C、已经开始的损害，不足以构成胁迫，但若告知对方将通过自己的作为或者不作为使其损害继续而使其陷入恐惧的，也为胁迫行为。

（2）胁迫人须有胁迫的故意

胁迫故意，是指胁迫人有通过胁迫行为而使表意人产生恐惧，并因此而为意思表示的故意。

A、使表意人陷于恐惧的意思。

B、使表意人因恐惧而为一意思表示的意思。

除此之外，胁迫人是否有取得财产上利益或者使表意人蒙受财产上的损失的意思，在所不问。

（3）胁迫的本质在于对表意人的自由意思加以干涉，所以胁迫应具有违法性。

A、目的违法，手段也违法。

B、目的合法，手段违法。

C、手段合法，目的违法。

（4）须相对人受胁迫而陷入恐惧状态

A、表意人原无恐惧，因行为人的胁迫而发生恐惧。

B、表意人原有恐惧，因行为人的胁迫而加深恐惧。

（5）须相对人受胁迫而为意思表示，即表意人陷入恐惧或者无法反抗的境地，与意思表示之间有因果关系。

注意：第三人胁迫也构成胁迫。第三人的胁迫视为行为人的胁迫。

相关法条：《民法典》第一百三十七条 以对话方式作出的意思表示，相对人知道其内容时生效。

以非对话方式作出的意思表示，到达相对人时生效。以非对话方式作出的采用数据电文形式的意思表示，相对人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统时生效；未指定特定系统的，相对人知道或者应当知道该数据电文进入其系统时生效。当事人对采用数据电文形式的意思表示的生效时间另有约定的，按照其约定。

相关法条：《民法典》第一百三十八条 无相对人的意思表示，表示完成时生效。法律另有规定的，依照其规定。

相关法条：《民法典》第一百三十九条 以公告方式作出的意思表示，公告发布时生效。

相关法条：《民法典》第一百四十条 行为人可以明示或者默示作出意思表示。

沉默只有在有法律规定、当事人约定或者符合当事人之间的交易习惯时，才可以视为意思表示。

相关法条：《民法典》第一百四十一条 行为人可以撤回意思表示。撤回意思表示的通知应当在意思表示到达相对人前或者与意思表示同时到达相对人。

相关法条：《民法典》第一百四十二条 有相对人的意思表示的解释，应当按照所使用的词句，结合相关条款、行为的性质和目的、习惯以及诚信原则，确定意思表示的含义。

无相对人的意思表示的解释，不能完全拘泥于所使用的词句，而应当结合相关条款、行为的性质和目的、习惯以及诚信原则，确定行为人的真实意思。

第三节 民事法律行为的成立与生效

一、民事法律行为的成立

民事法律行为的成立，是指符合民事法律行为的构成要素的客观情况。

（一）一般成立要件

1、一般成立要件的概念

民事法律行为的一般成立要件，是指一切民事法律行为成立所必不可少的共同要件。

2、一般成立要件的构成要素

（1）当事人

（2）意思表示

（3）标的

（二）特别成立要件

民事法律行为的特别成立要件，是指成立某一具体的民事法律行为，除须具备一般条件外，还须具备的其他特殊事实要素。

二、民事法律行为的生效

（一）民事法律行为生效的含义

民事法律行为的生效，是指已经成立的民事法律行为因符合法定有效要件而取得法律认可的效力。

（二）民事法律行为成立与生效的关系

1、民事法律行为成立与民事法律行为生效的联系

民事法律行为的成立是民事法律行为生效的前提。在大多数情况下，民事法律行为的成立与民事法律行为的生效在时间上是一致的，即在民事法律行为成立

时即具有法律效力。只有在少数情况下，民事法律行为的成立与生效不具有时间上的一致性，即一项民事法律行为已经成立，但却无效或尚未生效。

2、民事法律行为成立与民事法律行为生效的区别

（1）着眼点不同

民事法律行为的成立着眼于民事法律行为因符合法律构成要素，而在法律上视为一种客观存在；民事法律行为的生效着眼于成立的民事法律行为因符合法定的有效条件，而取得法律认可的效力。

（2）判断标准和构成要件不同

民事法律行为的成立以意思表示的成立或者意思表示一致为要件；民事法律行为的生效要件，则包括民事行为能力规则、意思表示自愿真实规则、行为内容不违反法律原则等。民事法律行为的成立要件着眼于表意行为的事实构成，此类规则的判断不依赖于当事人后来的意志；民事法律行为的有效要件却着眼于当事人的意思表示的效力。

（3）发生的时间不同

民事法律行为具备法定构成要素即为成立，自具备法定有效要件时生效。

（4）效力不同

民事法律行为成立即生效的，当事人应受效果意思的约束，所负担的义务主要是约定义务，可能产生的民事责任主要是违约责任；民事法律行为成立后不能生效或者被撤销或者在成立之后未生效之前，当事人所负担的主要义务是法定义务，违反了这种义务所产生的民事责任主要是缔约过失责任。

（三）民事法律行为的生效要件

1、实质要件

（1）行为人具有相应的民事行为能力。

（2）行为人的意思表示真实。

意思表示真实，是指行为人在自觉、自愿的基础上作出符合其意志的表示行为。

（3）不违反法律、行政性法规的强制性规定，不违背公序良俗。

注意：民事法律行为的内容还应具有可能性和确定性，可能和确定是民事法律行为的应有之义。

1、可能，是指民事法律行为的内容可能实现。内容不可能实现的称为标的不能，标的不能的，民事法律行为不生效。（标的不能分为事实不能与法律不能；自始不能与嗣后不能；客观不能与主观不能；全部不能与部分不能。）

2、确定，是指民事法律行为的内容自始确定，或者能够确定。标的不确定的行为，属于无效的行为。（能够确定，是指行为已包含了将来确定内容的方法；或者可以任意性法律规定补充当事人意思的不足，予以确定；或者可由人民法院或仲裁庭依职权对行为的内容进行解释，最终确定其内容。）

2、形式要件

在绝大多数情况下，民事法律行为只要具备实质要件就发生法律效力，但在某些特殊情况下，民事法律行为还须具备形式要件才发生效力。

相关法条：《民法典》第一百四十三条 具备下列条件的民事法律行为有效：

（一）行为人具有相应的民事行为能力；

（二）意思表示真实；

（三）不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。

相关法条：《民总解释》第二十三条 民事法律行为不成立，当事人请求返还财产、折价补偿或者赔偿损失的，参照适用民法典第一百五十七条的规定。

第四节 民事法律行为的附条件与附期限

一、附条件的民事法律行为

（一）附条件民事法律行为的概念

附条件的民事法律行为，是指在民事法律行为中规定一定的条件，并且把该条件的成就或者不成就作为确定行为人的民事权利和民事义务发生法律效力，或者失去法律效力的根据的民事法律行为。

注意：除了法律明确规定不得附条件的外，其他行为均可以由行为人设定条件，以此来限制行为的效力，从而满足行为人的各种不同需求。不得附条件的民事法律行为：（1）妨碍相对人利益的；

（2）违背社会公共利益或者社会公德的。

（二）民事法律行为所附条件的特点

1、应是将来发生的事实

2、应是发生与否不确定的事实

3、应是由行为人约定的事实

4、应是合法的事实

条件不确定的含义

1、主观说：只须于行为当时当事人不知其确定，即为不确定。

2、客观说：以民事法律行为当时客观不确定为必要，当事人知其不确定与否在所不问。

3、折中说：主观不确定为主，以客观不确定为辅；或者以客观不确定为主，以主观不确定为辅。

（三）条件的分类

1、延缓条件与解除条件

按照所附条件对民事法律行为效力所起作用的不同，可以将其划分为延缓条件和解除条件。

（1）附延缓条件

A、延缓条件，又称为停止条件，是指民事法律行为中所确定的民事权利和民事义务要在所附条件成就时才能发生法律效力。

B、当延缓条件成就时，民事法律行为发生法律效力；当延缓条件不成就时，民事法律行为不发生法律效力。（附延缓条件的民事法律行为，在条件成就之前已经成立，但效力处于停止状态。也就是说，在延缓条件成就以前，行为人之间的权利义务关系已经确

定，但是权利人尚不能主张权利，义务人还无须履行义务，即双方的民事权利和民事义务的法律效力尚处于停止状态。）

C、延缓条件的作用，是推迟行为所确定的民事权利和民事义务发生法律效力。

（2）附解除条件

A、解除条件，又称为消灭条件，是指民事法律行为中所确定的民事权利和民事义务在所附条件成就时失去法律效力。

B、当解除条件成就时，民事法律行为失去法律效力；当解除条件不成就时，民事法律行为继续发生法律效力。（附解除条件的民事法律行为，在所附条件成就以前，已经发生法律效力，当事人已经开始行使权利和承担义务，当条件成就时，权利和义务则失去法律效力。）

C、解除条件的作用，是使已经发生法律效力的民事权利义务关系失去法律效力。

2、肯定条件与否定条件

以某种客观事实的发生或者不发生为标准，所附条件可分为肯定条件和否定条件。

（1）肯定条件

A、肯定条件，又称为积极条件，是指以发生某种客观事实为其条件的内容。

B、肯定条件可分为肯定的延缓条件和肯定的解除条件。

C、肯定条件以一定客观事实的发生为条件成就，而以所附事实不发生为条件不成就。

（2）附否定条件的民事法律行为

A、否定条件，又称为消极条件，是指以不发生某种事实为条件的内容。

B、否定条件可分为否定的延缓条件和否定的解除条件。

C、否定条件以一定客观事实的不发生为条件成就，而以一定事实的发生为不成就。

（四）附条件民事法律行为的效力

1、条件成就

（1）条件成就，是指构成条件内容的事实已经实现。

（2）对于积极条件，以条件事实的发生为条件成就；对于消极条件，以条件事实的不发生为条件成就。

2、条件不成就

（1）条件不成就，是指构成条件内容的事实确定的不实现。

（2）对于积极条件，以条件事实的不发生为条件成就；对于消极条件，以条件事实的发生为条件成就。

3、条件成就或者不成就的拟制

（1）当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就；不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。

（2）拟制的构成要件

A、阻止条件成就或者不成就的人，须为因条件成就或者不成就而受利益的当事人。

B、此当事人须以不正当行为阻止条件的成就或者促成条件成就。

4、条件成就时的效力

附延缓条件的民事法律行为，条件成就时，该民事法律行为发生法律效力；附解除条件的民事法律行为，条件成就时，该民事法律行为失去法律效力。（附条件的民事法律行为，其效力因条件而受限制。条件成就后，民事法律行为当然发生效力，不需再有当事人的意思表示或者其他行为。此时又可分为两种情形：一是非要式行为。条件一旦成就，直接发生法律效力；二是要式行为，仅仅条件成就并不直接发生法律效力。）

5、条件不成就时的效力

附延缓条件的民事法律行为，条件不成就时，该民事法律行为视为不存在，不发生法律效力；附解除条件的民事法律行为，条件不成就时，该民事法律行为视为不再附有条件，维持原有法律效力。

6、延缓条件成就与否未确定前的效力

相对人在延缓条件成就与否未确定前，应有因条件成就而取得权利或者利益的希望。为了保护相对人的期待利益，当事人不得任意撤销该行为。当然延缓条件成就前，相对人向对方请求履行的，对方享有拒绝履行的权利。

二、附期限的民事法律行为

（一）附期限民事法律行为的概念

1、附期限的民事法律行为，是指在民事法律行为中约定一定期限，并把该期限的到来作为行为人的民事权利和民事义务发生、变更、消灭的前提的民事法律行为。

2、民事法律行为通常都可以附期限，但基于社会公共利益，也有不许附期限的，其范围与不许附条件的民事法律行为的范围大致相同。

3、期限与条件的关系

（1）联系

期限与条件都是对民事法律行为效力的某种限制，都是期待中的未来事实。

（2）区别

期限是将来一定能到来的；而条件则属将来是否发生不确定的事实。

（二）附期限民事法律行为的分类

1、延缓期限与解除期限（始期与终期）

根据所附的期限对民事法律行为的效力所起的作用不同，所附期限可以分为延缓期限和解除期限。

（1）附延缓期限的民事法律行为

附延缓期限的民事法律行为，是指民事法律行为虽然已经成立，但在所附期限到来之前不发生效力，待到期限届至时，当事人双方的权利义务才开始发生法

律效力的民事法律行为。

（2）附解除期限的民事法律行为

附解除期限的民事法律行为，是指在约定的期限到来时，该民事法律行为所确定的民事权利和民事义务的法律效力消灭的民事法律行为。

2、确定期限与不确定期限

根据所附期限是否确定，所附期限可以分为附确定期限和不确定期限。

（1）确定期限，是指不但期限事实的发生已确定，而且其发生的时期也已确定。

（2）不确定期限，是指期限事实的发生虽已确定，但其发生时期不确定。

（三）附期限民事法律行为的效力

1、期限到来时的效力

附期限的民事法律行为在所附期限到来时生效或者解除。附延缓期限的民事法律行为，期限到来时，民事法律行为发生效力；附解除期限的民事法律行为，期限到来时，民事法律行为效力消灭。

2、期限到来前的效力

附延缓期限的民事法律行为，期限到来前，民事法律行为不发生效力；附解除期限的民事法律行为，期限到来前，民事法律行为继续发生效力。

相关法条：《民法典》第一百五十八条 法律行为可以附条件，但是按照其性质不得附条件的除外。附生效条件的民事法律行为，自条件成就时生效。附解除条件的民事法律行为，自条件成就时失效。

相关法条：《民法典》第一百五十九条 附条件的民事法律行为，当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就；不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。

相关法条：《民法典》第一百六十条 民事法律行为可以附期限，但是按照其性质不得附期限的除外。附生效期限的民事法律行为，自期限届至时生效。附终止期限的民事法律行为，自期限届满时失效。

相关法条：《民总解释》第二十四条 民事法律行为所附条件不可能发生，当事人约定为生效条件的，人民法院应当认定民事法律行为不发生效力；当事人约定为解除条件的，应当认定未附条件，民事法律行为是否失效，依照民法典和相关法律、行政法规的规定认定。

第五节 无效的民事法律行为

一、无效民事法律行为的概念

（一）无效民事法律行为的概念

无效民事法律行为，是指自始、当然、确定不发生当事人预期的法律效果的民事法律行为。

1、自始无效，是指从行为开始时就没有法律约定力。

2、当然无效，是指无效民事法律行为，不论当事人是否提出主张，是否知道无效的情况，也不论是否经过人民法院或者仲裁机构在诉讼或者仲裁机构的确认，该民事法律行为都是无效的。

3、确定无效，是指无效的民事法律行为，从开始时就没有效力，以后任何事实都不能使之有效。

（二）无效的民事法律行为的分类

1、全部无效的民事法律行为和部分无效的民事法律行为

（1）全部无效的民事法律行为

（2）部分无效的民事法律行为，是指民事法律行为的一部分内容不具备民事法律行为的有效要件时，该部分民事法律行为不具有效力，不影响其他部分效力的，其他部分仍具有效力。

2、绝对无效的民事法律行为和相对无效的民事法律行为

（1）绝对无效的民事法律行为，是指违反了法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为。

（2）相对无效的民事法律行为，是指行为内容侵害特定第三人利益，应由该特定第三人主张无效的民事法律行为。

二、无效民事法律行为的分类

（一）无民事行为能力人实施的民事法律行为

（二）行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为

（三）违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为（但是该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。）

（四）违背公序良俗的民事法律行为

（五）恶意串通损害他人合法权益的民事法律行为

三、民事法律行为被确认无效的法律后果

（一）返还财产

民事法律行为被确认无效，当事人因民事法律行为取得的财产，应当返还给对方。如果一方取得，取得方应返还给对方；如果双方取得，则双方返还。（返还财产的范围，以全部返还为原则。）

（二）赔偿损失

民事法律行为被确认无效后，有过错的当事人应当赔偿对方的损失；双方有过错的，则应各自承担相应的责任。

相关法条：《民法典》第一百四十四条 无民事行为能力人实施的民事法律行为无效。

相关法条：《民法典》第一百四十六条 行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。

以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力，依照有关法律规定处理。

相关法条：《民法典》第一百五十三条 违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效，但是该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。违背公序良俗的民事法律行为无效。

相关法条：《民法典》第一百五十四条 行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无

效。

相关法条：《民法典》第一百五十五条 无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力。

相关法条：《民法典》第一百五十六条 民事法律行为部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。

相关法条：《民法典》第一百五十七条 民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；各方都有过错的，应当各自承担相应的责任。法律另有规定的，依照其规定。

第六节 可撤销的民事法律行为

一、可撤销的民事法律行为的概念

（一）可撤销的民事法律行为，是指已经成立且已生效，因为意思表示不真实或者其他法定原因，行为人有撤销权的民事法律行为。

（二）有撤销权人如行使撤销权，则经撤销其效力溯及民事法律行为成立时无效；如果撤销权人在法定期限内未行使撤销权，该民事法律行为原来的效力不变，民事法律行为效力继续。

二、可撤销的民事法律行为的种类

（一）因重大误解的民事法律行为

（二）显失公平的民事法律行为

（三）受欺诈而实施的民事法律行为

（四）受胁迫而实施的民事法律行为

★显失公平：

一、显失公平的概念

显失公平，是指一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使民事法律行为成立时，民事权利义务明显不对称的情形。

二、显失公平的要件

（一）客观要件

给付与对待给付明显不相称。

1、在各个具体的民事法律行为中，应全面考虑风险负担、市场情况等。

2、显失公平仅适用于财产行为，不适用于身份行为。（在财产行为中，公开竞价的财产行为，不适用显示公平；合法的和符合交易习惯的投机性财产行为不适用显失公平。）

（二）主观要件

一方当事人利用对方处于急迫情势，没有经验，缺乏判断能力或者意志薄弱等情事。

1、利用对方处于急迫情势，是指为获取暴力利用对方的窘境，至于交易的提议是否由暴利获得者提出，并不重要。（利用对方处于急迫情势，不仅要求获得暴利者明知所约定的给付明显不合理，而且要求暴利获得者明知对方处于窘境。）

2、利用对方没有经验，是指利用对方没有经验或者缺少生活及交易经验，利用对方没有经验，要求获得暴利者明知对方没有经验或者缺少生活及交易经验。

3、利用对方缺乏判断能力，应根据民事法律行为所涉及的专业复杂程度、市场风险程度及表意人的经历等方面予以认定。（不包含无民事行为能力人或者限制民事行为能力人缺乏判断能力的情形。）

4、利用对方意志薄弱或者控制力薄弱，是指暴利获得者明知对方意志薄弱或者控制力薄弱而获取暴利的行为。

三、撤销权的享有和行使

（一）撤销权，是指权利人以其单方的意思表示撤销已经成立的民事法律行为的权利。（形成权）

（二）可撤销民事法律行为的撤销权由行为成立时的受害人享有。在欺诈、胁迫的情况下，由被欺诈人、被胁迫人享有。在暴利行为的情况下，由行为成立时的受害人享有。在重大误解的情况下，由行为人享有。

（三）撤权权人行使撤销权应采用诉讼或仲裁方式。

（四）有下列情形之一的，撤销权消灭：

1、当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内、重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起三个月内没有行使撤销权；

2、当事人受胁迫，自胁迫行为终止之日起一年内没有行使撤销权；

3、当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为表明放弃撤销权。

当事人自民事法律行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。

（五）撤销权人行使撤销权后当事人之间的民事法律行为溯及于行为成立之日起无效，发生无效民事法律行为的后果，但不得对抗善意第三人。

相关法条：《民法典》第一百四十七条 基于重大误解实施的民事法律行为，行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

相关法条：《民法典》第一百四十八条 一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

相关法条：《民法典》第一百四十九条 第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，对方知道或者应当知道该欺诈行为的，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

相关法条：《民法典》第一百五十条 一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

相关法条：《民法典》第一百五十一条 一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使民事法律行为成立时显失公平的，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

相关法条：《民法典》第一百五十二条 有下列情形之一的，撤销权消灭：

（一）当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内、重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起三个月内没有行使撤销权；

（二）当事人受胁迫，自胁迫行为终止之日起一年内没有行使撤销权；

（三）当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为表明放弃撤销权。

当事人自民事法律行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。

相关法条：《民总解释》第十九条 行为人对行为的性质、对方当事人或者标的物的品种、质量、规格、价格、数量等产生错误认识，按照通常理解如果不发生该错误认识行为人就不会作出相应意思表示的，人民法院可以认定为民法典第一百四十七条规定的重大误解。

行为人能够证明自己实施民事法律行为时存在重大误解，并请求撤销该民事法律行为的，人民法院依法予以支持；但是，根据交易习惯等认定行为人无权请求撤销的除外。

相关法条：《民总解释》第二十条 行为人以其意思表示存在第三人转达错误为由请求撤销民事法律行为的，适用本解释第十九条的规定。

相关法条：《民总解释》第二十一条 故意告知虚假情况，或者负有告知义务的人故意隐瞒真实情况，致使当事人基于错误认识作出意思表示的，人民法院可以认定为民法典第一百四十八条、第一百四十九条规定的欺诈。

相关法条：《民总解释》第二十二条 以给自然人及其近亲属等的人身权利、财产权利以及其他合法权益造成损害或者以给法人、非法人组织的名誉、荣誉、财产权益等造成损害为要挟，迫使其基于恐惧心理作出意思表示的，人民法院可以认定为民法典第一百五十条规定的胁迫。

第七节 效力未定的民事法律行为

一、效力未定的民事法律行为的概念与特征

（一）效力未定的民事法律行为的概念

效力未定的民事法律行为，是指已经成立但效力处于不确定状态的民事法律行为。

（二）效力未定的民事法律行为的特征

1、效力未定的民事法律行为的效力处于未决的不确定状态之中，既非有效，亦非无效。

2、效力未定的民事法律行为的效力确定，取决于享有形成权的第三人是否追认或者是否形成了其他法定条件，其结果可能变为有效的民事法律行为，也可能变为无效的民事法律行为。

3、效力未定的民事法律行为确定为有效的，其效力溯及于行为成立时；确定为无效的，自始无效。

（三）效力未定的民事法律行为的类型

1、欠缺民事行为能力的行为

2、无权代理的行为

二、欠缺民事行为能力的行为

（一）法定代理人的追认权

1、追认权的性质

（1）追认权是形成权。

（2）追认行为是有相对人的单方行为。

（3）追认是辅助性行为。

（一）法定代理人的追认权

1、追认权的性质

（1）追认权是形成权。

（2）追认行为是有相对人的单方行为。

（3）追认是辅助性行为。

3、追认的方式

在相对人催告以前，法定代理人追认的意思可以向限制行为能力人或者相对人表示，追认的意思表示自到达相对人时发生追认的效力。对限制民事行为能力人所订合同的追认，法定代理人应采用明示方式。法定代理人已实际履行该合同或者为该合同的履行做了准备工作，应推定法定代理人予以追认。

4、追认的效力

效力未定民事法律行为经追认后，自始有效；追认权人拒绝追认，该行为自始无效。

（二）相对人的催告权与撤销权

1、相对人的催告权

（1）相对人有权催告法定代理人在30日内予以追认。

（2）法定代理人于催告期满未作表示的，视为拒绝追认。

2、相对人的撤销权

（1）相对人的撤销权，是指相对人撤销其意思表示的权利。

（2）相对人撤销其意思表示，应向法定代理人表示。

（3）相对人撤销其意思表示后，效力未定民事法律行为自始无效。

（4）相对人撤销权行使的条件

A、应在法定代理人追认之前行使。

B、相对人须为善意。

C、应采用明示的方式。

相关法条：《民法典》第一百四十五条 限制民事行为能力人实施的纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应的民事法律行为有效；实施的其他民事法律行为经法定代理人同意或者追认后有效。

相对人可以催告法定代理人自收到通知之日起一个月内予以追认。法定代理人未作表示的，视为拒绝追认。民事法律行为被追认前，善意相对人有撤销的权利。撤销应当以通知的方式作出。

第九章 代理

第一节 代理的概念与特征

一、代理的概念

代理，是指代理人依据代理权，以被代理人的名义与第三人实施民事法律行为，直接对被代理人发生效力。

注意： 在代理关系中，依据代理权代替他人实施民事法律行为的人称为代理人；被他人代替实施民事法律行为，承受民事法律行为后果的人称为被代理人（又称本人）；同代理人为民事法律行为的人称为第三人（又称相对人）。

1、代理是一种法律关系

（1）代理人与被代理之间基于委托授权或者法律直接规定而形成的代理权关系。

（2）代理人依据代理权与第三人之间的代理行为关系。

（3）被代理人与第三人之间因代理行为而形成的具体民事法律关系。

2、代理是民事法律行为

（一）狭义的代理，又称为显名代理，是指直接代理，即以被代理人的名义进行的民事法律行为，后果直接归属于被代理人。

（二）广义的代理包括直接代理和间接代理。间接代理是指代理人以自己的名义进行民事法律行为，而使其后果归属于被代理人。

注意：民法法系国家和地区大多对代理采取狭义的立法主张，普通法系（又称英美法系）国家财采取广义的立法主张。《民法典》采取的是狭义代理的概念。

二、代理与相关概念

（一）代理与传达

1、传达，是指传达人传送表意人已确定的意思表示，传达人不为自己的意思表示。

2、区别代理与传达的意义

（1）传达人不必有行为能力，而代理人必有行为能力。

（2）传达人传达不实，本人可以撤销，但由此造成的损失由本人承担。代理人因自己的过错给被代理人造成损失的，通常由代理人承担责任。

（二）代理与代表

1、代表人与法人是民事主体内部的法律关系，是一个民事主体；代理人与被代理人是两个民事主体间的关系，是两个独立的民事主体。

2、代表人为法人实施民事法律行为即为法人的民事法律行为，不发生另外的效力归属问题；代理人的行为不是被代理人的行为，仅其效力归属于被代理人。

3、代表人为法人所为的行为，包括民事法律行为和事实行为；代理人为代理行为不包括事实行为。

（三）代理与行纪

1、行纪，是指行纪人以自己的名义为委托人从事交易活动。

2、区别代理与行纪的意义

（1）行纪人是以自己的名义为民事法律行为；代理人是以被代理人的名义为民事法律行为。

（2）行纪的后果直接归属于行纪人，然后由行纪人转移于委托人；代理的后果直接归属于被代理人。

（3）行纪必为有偿民事法律行为；代理不以有偿为要件。

（4）代理是独立的民事法律制度；行纪是一种具体的合同关系，属于债的组成部分。

（四）代理与居间

1、居间是指居间人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，委托人支付报酬。

2、区别代理与居间的意义

居间是指居间人与委托人之间的权利义务关系，而代理则发生被代理人与相对人之间的权利义务关系。

三、代理的特征

（一）代理人在代理权限之内实施代理行为

（二）代理人以被代理人的名义实施代理行为

（三）代理行为是具有法律意义的行为

（四）代理行为直接对被代理人发生效力

四、代理的适用范围与意义

（一）代理的适用范围

1、代理的范围

（1）代理各种民事法律行为。

（2）代理实施某些财政、行政行为。

（3）代理民事诉讼行为。

2、代理的限制

（1）具有人身性质的民事法律行为不得代理。

（2）被代理人无权进行的行为不得代理。

（3）双方当事人约定应由本人亲自实施的民事法律行为不适用代理。

（二）代理的意义

1、扩大民事主体的活动范围。

2、补充某些民事主体的行为能力的不足。

相关法条：《民法典》第一百六十一条 民事主体可以通过代理人实施民事法律行为。

依照法律规定、当事人约定或者民事法律行为的性质，应当由本人亲自实施的民事法律行为，不得代理。

相关法条：《民法典》第一百六十二条 代理人在代理权限内，以被代理人名义实施的民事法律行为，对被代理人发生效力。

第二节 代理的分类

一、委托代理与法定代理

根据代理权产生的根据不同，可以将代理分为委托代理和法定代理。

（一）委托代理

1、委托代理，又称为授权代理或者意定代理，是指代理人根据被代理人的委托而进行的代理。

2、委托代理一般产生于代理人与被代理人之间存在的基础法律关系之上，这种法律关系可以是委托合同关系，也可以是劳动合同关系（职务关系），还可以是合伙合同关系。

（二）法定代理

1、法定代理，是指根据法律直接规定而发生的代理关系。

2、法定代理主要是为无民事行为能力人和限制民事行为能力人设立代理人的方式。

3、法定代理产生的根据是代理人与被代理人之间存在的监护关系。

二、一般代理与特别代理

根据代理权限的范围大小，可以将代理分为一般代理与特别代理。

（一）一般代理

一般代理，又称为概括代理、全权代理，是指代理权范围及于代理事项的全部的代理。

（二）特别代理

特别代理，又称为部分代理、特定代理或者限定代理，是指代理权被限定在一定范围或者一定事项的某些方面的代理。

注意：在实践中，如未指明为特别代理时则为概括代理。

三、单独代理与共同代理

根据代理权属于一人还是多人，可以将代理分为单独代理与共同代理。

（一）单独代理

单独代理，又称为独立代理，是指代理权属于一人的代理。

（二）共同代理

1、共同代理，是指代理权属于两人以上的代理。

2、在通常情况下，共同代理人应共同行使代理权，如其中一人或者数人未与其他代理人协商，其实施的行为侵害被代理人权益的，由实施行为的代理人承担民事责任；在当事人有约定的情况下，代理权的行使及其民事责任承担依照当事人的约定。

四、本代理与复代理

根据代理权是由被代理人授予，还是由代理人转托，可以将代理分为本代理与复代理。

（一）本代理

本代理，又称为原代理，是指基于被代理人选任代理人或者依法律规定而产生的代理。

（二）复代理

1、复代理的概念

复代理，又称为再代理、转代理，是指代理人为被代理人的利益将其所享有的代理权转托他人而产生的代理。

①复代理人，是指因代理人的转托而享有代理权的人。

②复任权，是指代理人选择他人作为复代理人的权利。

2、复代理的特征

（1）复代理人是由代理人以自己的名义选任的，不是由被代理人选任的。

（2）复代理人不是原代理人的代理人，而仍然是被代理人的代理人，复代理人行使代理权时仍应以被代理人的名义进行，法律后果直接归属于被代理人，而不归属原代理人，也不是先归属于原代理人，再转移于被代理人。

（3）复代理权不是由被代理人直接授予的，而是由代理人转托的，但以原代理人的代理权限为限，不能超过原代理人的代理权。

3、复代理适用

委托代理人原则上没有复任权（法定代理人无条件地享有复任权），但是在尊重被代理人意思和有利于保护被代理人利益的前提下，委托代理人在下列情况下可享有复任权：

（1）被代理人事先授权可以转委托的。

（2）转委托前征得被代理人同意的。

（3）转委托后得到被代理人追认的。

（4）在紧急情况下，如由于突然疾病、通讯联络中断等特殊原因，委托代理人不能办理代理事项，又不能与被代理人及时取得联系，如不及时转委托他人代理，会给被代理人的利益造成损失或者扩大损失的。

注意：

1、对于经被代理人事先授权或者经代理人同意及追认的复代理，被代理人可以就代理事务直接指示复代理人。代理人仅就复代理人的选任及对复代理人的指示承担责任。（代理人的选任责任，是指代理人所选择的复代理人应具备完成代理事项的品行和能力。代理人的指示责任，是指代理人对复代理人的指示应在被代理人的授权范围内。）

2、在复代理关系中因代理人的错误指示造成被代理人损失的，应由代理人对被代理人承担责任；因代理人的选任错误和复代理人的过错行为造成被代理人的损失的，由代理人和复代理人对被代理人共同承担责任；；在复代理人的过错行为造成被代理人损失的，由复代理人对被代理人承担责任；因代理人和复代理人恶意串通造成被代理人损失的，由代理人和复代理人对被代理人负连带责任。

五、直接代理与间接代理

（一）直接代理

直接代理，是指代理人在代理权限范围内，以被代理人的名义为民事法律行为，直接对被代理人发生法律效力的代理。

（二）间接代理

间接代理，是指代理人以自己的名义为民事法律行为，其效果转移于被代理人的代理。

六、积极代理与消极代理

根据代理人是否处于主动地位，可以将代理分为积极代理与消极代理。

（一）积极代理

积极代理，又称主动代理，是指以代理人为意思表示的代理。

（二）消极代理

消极代理，又称被动代理，是指代理人受领意思表示的代理。

相关法条：《民法典》第一百六十三条 代理包括委托代理和法定代理。

委托代理人按照被代理人的委托行使代理权。法定代理人依照法律的规定行使代理权。

相关法条：《民法典》 第一百六十九 代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追认。

转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。

代理人应当对转委托的第三人的行为承担责任，但是在紧急情况下代理人为了维护被代理人的利益需要转委托第三人代理的除外。

相关法条：《民总解释》第二十六条 由于急病、通讯联络中断、疫情防控等特殊原因，委托代理人自己不能办理代理事项，又不能与被代理人及时取得联系，如不及时转委托第三人代理，会给被代理人的利益造成损失或者扩大损失的，人民法院应当认定为民法典第一百六十九条规定的紧急情况。

第三节 代理权

一、代理权的概念与性质

（一）代理权的概念

代理权，是指代理人基于被代理人的意思表示或者法律的直接规定，能够以被代理人的名义为意思表示或者受领意思表示，其法律效果直接归于被代理人的资格。

（二）代理权的性质

1、否定说

代理不过是特定法律关系，如委任关系的外部效力，并非独立的制度，也无所谓代理权。

2、权力说

代理权是一种法律上之力。代理人的权力不是被代理人授予的，而是由法律授予的，只是由于被代理人和代理人的行为使法律规则发生作用，其结果是代理人得到了这种权力。

3、权利说

代理权是一种民事权利。

4、资格说（通说）

代理权并非权利，而是一种资格和地位。代理权从本质上说只是一种资格，代理人取得代理权只是意味着他得以被代理人的名义与第三人进行民事活动，其行为后果直接归属于被代理人。

二、代理权的发生

（一）基于法律规定而发生

（二）基于被代理人的授权行为而发生

三、授权行为

（一）授权行为的性质

授权行为是以发生代理权为目的的单方行为。

（二）授权行为与基础关系的关系

1、无因说

授权行为与其基础法律关系是被代理人与代理人之间的内部关系，第三人无从得知，授权行为与其基础关系应相互独立，因此，基础关系无效或者被撤销时，代理行为仍然有效。

2、有因说

授权行为基于其基础法律关系而生，授权行为从属于其基础法律关系，故基础法律关系无效或者被撤销时，授权行为应消灭，如为代理行为，属无权代理。

注意：《民法典》对授权行为与基础关系未作规定。

（三）授权行为的相对人

1、授权行为是委托人的单方民事法律行为，授权的意思表示可向受托人或者第三人为之，受托人或者第三人为授权行为的相对人。

2、授权的意思表示向受托人为之与向第三人为之具有相同的法律效力。

3、代理人应具有相应的民事行为能力（代理人应具有意思能力），不要求具有完全的民事行为能力，但代理人不能是无民事行为能力人。

（四）授权行为的形式与内容

1、授权行为的形式

（1）口头形式

（2）书面形式

（3）默示形式

2、授权行为的内容

（1）授权行为的内容由本人决定或者依行为的性质决定，通常包括代理事项、代理权限和代理期限。

（2）如果委托人采用授权书的形式，其内容由授权书规定；如果委托人采用默示方式授权的，其内容由该行为的性质决定。

四、代理权的行使

（一）代理权行使的概念

代理权的行使，是指代理人在代理权限范围内，以被代理人的名义独立、依法有效地实施民事法律行为，以达到被代理人所希望的或者客观上符合被代理人利益的法律效果。

（二）代理权行使的原则

1、代理人应在代理权限范围内行使代理权，不得无

权代理。

（1）代理权限，又称为代理权的范围，是指代理人在何种范围内为意思表示和受领意思表示，其效力及于被代理人。

（2）基于被代理人的意思表示的，代理权的范围应依其意思表示范围确定；基于法律规定的，代理权的范围应依法律规定确定。

（3）代理人有权为保存行为、利用行为和改良行为。代理行为仅以民事法律行为为限，以保存为目的的事实行为，不适用代理的规定；对于利用行为及改良行为，代理人以不变更物或者权利性质为限。

（4）代理人非经被代理人的同意，不得擅自扩大、变更代理权限。

2、代理人应亲自行使代理权，不得任意转托他人代理。

3、代理人应积极行使代理权，尽勤勉和谨慎的义务。

（1）代理人应认真工作，尽相当的注意义务。在法定代理和委托代理的无偿代理中，代理人实施代理行为，必须尽与处理自己事务相同的注意义务；在有偿代理中，代理人应尽善良管理人的注意义务。

（2）在委托代理中，代理人应根据被代理人的指示进行代理活动。

（3）代理人应尽报告与保密的义务。

（4）判断代理人行使代理权是否维护了被代理人利益的标准，对于委托代理，其标准为是否符合被代理人的主观利益；对于法定代理，其标准为是否符合被代理人的客观利益。

五、滥用代理权的禁止

（一）滥用代理权的概念

1、滥用代理权的概念

滥用代理权，是指代理人行使代理权时，违背代理权的设定宗旨和代理行为的基本准则，有损被代理人利益的行为。

2、滥用代理权的构成要件

（1）代理人有代理权。

（2）代理人行使代理权的行为违背了诚实信用原则，违背了代理权的设定宗旨和基本准则。

（3）代理人的代理行为有损被代理人的利益。

（二）滥用代理权的主要类型

1、自己代理

（1）自己代理，是指代理人以被代理人名义与自己进行民事法律行为。

（2）自己代理应予禁止，原则上是无效行为。但经被代理人同意或者追认的自己代理的后果由被代理人承受。

2、双方代理

（1）双方代理，又称为同时代理，是指一人同时担任双方的代理人为民事法律行为。

（2）双方代理应予禁止，原则上是无效行为。但经被代理人同意或者追认的双方代理的后果由被代理人承受。

3、代理人和第三人恶意串通，进行损害被代理人利益的行为

（1)恶意串通，是指代理人和相对人之间存在通谋；损害被代理人的利益，是指实际造成了被代理人财产利益的损失。是否造成了被代理人的损失，应依客观标准确定。

（2）代理人和第三人恶意串通，损害被代理人利益的行为是无效民事法律行为，其代理行为的后果被代理人不予承认。

（3）代理人和第三人串通，损害被代理人利益的，由代理人和第三人负连带责任。

六、代理权的消灭

代理权的消灭，又称为代理权的终止，是指代理人与被代理人之间的代理关系消灭，代理人不再具有以被代理人名义进行民事活动的资格。

（一）委托代理权消灭的原因

1、代理期间届满或者代理事务完成

2、被代理人取消委托或者代理人辞去委托

3、代理人丧失民事行为能力

4、代理人或者被代理人死亡

5、作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止

（二）法定代理权的消灭原因

1、被代理人取得或者恢复完全民事行为能力

2、代理人丧失民事行为能力

3、代理人或者被代理人死亡

4、法律规定的其他情形

相关法条：《民法典》第一百六十四条 代理人不履行或者不完全履行职责，造成被代理人损害的，应当承担民事责任。

代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担连带责任。

相关法条：《民法典》第一百六十五条 委托代理授权采用书面形式的，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由被代理人签名或者盖章。

相关法条：《民法典》第一百六十六条 数人为同一代理事项的代理人的，应当共同行使代理权，但是当事人另有约定的除外。

相关法条：《民法典》第一百六十七条 代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为，或者被代理人知道或者应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，被代理人和代理人应当承担连带责任。

相关法条：《民法典》第一百六十八条 代理人不得以被代理人的名义与自己实施民事法律行为，但是被代理人同意或者追认的除外。

代理人不得以被代理人的名义与自己同时代理的其他人实施民事法律行为，但是被代理的双方同意或者追认的除外。

相关法条：《民法典》第一百七十三条 有下列情形之一的，委托代理终止：

（一）代理期间届满或者代理事务完成；

（二）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；

（三）代理人丧失民事行为能力；

（四）代理人或者被代理人死亡；

（五）作为代理人或者被代理人的法人、非法人组织终止。

相关法条：《民法典》第一百七十四条 被代理人死亡后，有下列情形之一的，委托代理人实施的代理行为有效：

（一）代理人不知道并且不应当知道被代理人死亡；

（二）被代理人的继承人予以承认；

（三）授权中明确代理权在代理事务完成时终止；

（四）被代理人死亡前已经实施，为了被代理人的继承人的利益继续代理。

作为被代理人的法人、非法人组织终止的，参照适用前款规定。

相关法条：《民法典》第一百七十五条 有下列情形之一的，法定代理终止：

（一）被代理人取得或者恢复完全民事行为能力；

（二）代理人丧失民事行为能力；

（三）代理人或者被代理人死亡；

（四）法律规定的其他情形。

相关法条：《民总解释》第二十五条 数个委托代理人共同行使代理权，其中一人或者数人未与其他委托代理人协商，擅自行使代理权的，依据民法典第一百七十一条、第一百七十二条等规定处理。

第四节 无权代理与表见代理

一、无权代理

（一）无权代理的概念

无权代理，是指行为人既没有代理权，也没有令相对人相信其有代理权的事实或理由，而以被代理人的名义所为的代理。

（二）无权代理的特征

1、行为人所实施的民事法律行为，符合代理行为的表面特征，即以被代理人的名义独立对相对人为意思表示，并将其行为的法律后果直接归属于他人。

2、行为人实施代理行为不具有代理权。

3、无权代理行为并非绝对不能产生代理的法律效果。

（三）无权代理的类型

1、行为人自始没有代理权

2、行为人超越代理权

3、代理权终止后的代理

（四）无权代理的效力

无权代理，被代理人不予追认的，对于被代理人不发生法律效力，而是由行为人承担责任。

1、被代理人的追认权

（1）无权代理经被代理人追认，变为有权代理。

（2）被代理人追认的意思向相对人表示的，自追认的意思表示到达相对人时发生追认效力，即该民事法律行为自始生效；向无权代理人表示的，发生补充授权效力，即无权代理人向相对人通知该补充授权表示，该无权代理变为有权代理，该民事法律行为自始有效。

（3）追认可以明示，也可以默示，但沉默不成立追认的意思表示。

（4）无权代理人实施了多项民无权代理行为，被代理人可以追认其中一项或者多项，但是对某一项无权代理行为的追认，应当是概括的，不能只追认利益的方面而不追认不利益的方面。

（5）追认应在相对人撤销通知作出前行使。

2、相对人的催告权与撤销权

（1）相对人的催告权

A、相对人行使催告权应当向被代理人表示。

B、行使催告权应当在被代理人追认之前。

C、相对人可以催告被代理人在三十日内追认，在追认期内被代理人未作表示的，视为拒绝追认。

（2）相对人的撤销权

A、善意的相对人，即不知道或者不应当知道代理人无权代理的人有撤销权。

B、行使撤销权的意思向被代理人或者无权代理人表示。

C、行使撤销权应当在被代理人追认之前。相对人催告后，被代理人未追认前，相对人仍可撤回。

（五）无权代理人的责任

1、无权代理人对相对人的责任

行为人实施的行为未被追认的，善意相对人有权请求行为人履行债务或者就其受到的损害请求行为人赔偿，但是赔偿的范围不得超过被代理人追认时相对人所能获得的利益。

2、无权代理人对被代理人的责任

（1）无权代理人对于被代理人的责任为侵权责任。

（2）相对人知道或者应当知道行为人无权代理的，相对人和行为人按照各自的过错承担责任。

二、表见代理

（一）表现代理的概念与价值

1、表现代理的概念

表现代理，是指行为人没有代理权，但使相对人有理由相信其有代理权，法律规定被代理人应负授权责任的无权代理。

2、表现代理的价值

表见代理的制度价值在于维护交易安全，使个人静的安全与社会动的安全得到协调。

（二）表见代理的构成要件

1、须行为人无代理权。
2、须有使相对人相信行为人具有代理权的事实或者理由。
3、须相对人善意。
4、须行为人与相对人之间的民事法律行为具备民事法律行为的有效要件。

（三）表见代理的类型

1、表见授权的表见行为
（1）表见授权，是指由自己的行为表示授予代理权，实际上并未授予代理权。
（2）表见授权可以是口头形式，也可以是书面形式，包括代理证书、单位印章、单位介绍信、空白合同书、其他证明材料。
2、容忍的表见行为
无权代理人与相对人实施无权代理行为，被代理人知道而不表示反对，或者为履行合同进行准备的，应认定表见代理成立。
3、特定关系中的表见代理
因特殊关系的存在，使他人相信无权代理人享有代理权的，构成表见代理。

（四）表见代理的效力

1、表见代理对被代理人产生有权代理的效力，即在相对人与被代理人之间产生民事关系，被代理人应受表见代理人与相对人之间实施的民事法律行为的约束，享有该行为设定的权利和履行该行为约定的义务。
2、表见代理中的相对人既可以主张狭义无权代理，也可以主张成立表见代理。在相对人不主张表见代理的情况下，被代理人或者无权代理人不得主张表见代理。
3、表见代理成立后，被代理人因承受表见代理的后果而遭受损害的，有权向表见代理人主张损害赔偿。

相关法条：《民法典》第一百七十条 执行法人或者非法人组织工作任务的人员，就其职权范围内的事项，以法人或者非法人组织的名义实施民事法律行为，对法人或者非法人组织发生效力。
法人或者非法人组织对执行其工作任务的人员职权范围的限制，不得对抗善意相对人。

相关法条：《民法典》第一百七十一条 行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力。
相对人可以催告被代理人自收到通知之日起三十日内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。行为人实施的行为被追认前，善意相对人有撤销的权利。撤销应当以通知的方式作出。
行为人实施的行为未被追认的，善意相对人有权请求行为人履行债务或者就其受到的损害请求行为人赔偿，但是赔偿的范围不得超过被代理人追认时相对人所能获得的利益。
相对人知道或者应当知道行为人无权代理的，相对人和行为人按照各自的过错承担责任。

相关法条：《民法典》第一百七十二条 行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，相对人有理由相信行为人有代理权的，代理行为有效。

相关法条：《民总解释》第二十七条 无权代理行为未被追认，相对人请求行为人履行债务或者赔偿损失的，由行为人就相对人知道或者应当知道行为人无权代理承担举证责任。行为人不能证明的，人民法院依法支持相对人的相应诉讼请求；行为人能够证明的，人民法院应当按照各自的过错认定行为人与相对人的责任。

相关法条：第二十八条 同时符合下列条件的，人民法院可以认定为民法典第一百七十二条规定的相对人有理由相信行为人有代理权：
（一）存在代理权的外观；
（二）相对人不知道行为人行为时没有代理权，且无过失。
因是否构成表见代理发生争议的，相对人应当就无权代理符合前款第一项规定的条件承担举证责任；被代理人应当就相对人不符合前款第二项规定的条件承担举证责任。

相关法条：第二十九条 法定代理人、被代理人依据民法典第一百四十五条、第一百七十一条的规定向相对人作出追认的意思表示的，人民法院应当依据民法典第一百三十七条的规定确认其追认意思表示的生效时间。

第十章 诉讼时效、除斥期间与期限

第一节 时效制度概述

一、时效制度的概念与作用

（一）时效制度的概念

1、时效制度的概念
时效制度，是指一定事实状态在法定期间持续存在，从而产生与该事实状态相适应的法律效力的法律制度。
2、时效制度的条件
（1）要有法律规定的一定事实状态存在。
（2）一定的事实状态必须持续一定的时间，即不间断地经过法律规定的期间。、
3、时效制度的特征
（1）时效是法律事实
（2）时效是状态
（3）时效具有强制性

注意：时效制度起源于罗马法的十二铜表法。经过两千多年，现代各国接受并发展了时效制度。民法设立时效制度的目的，在于维护社会公共利益，维护经济秩序。因时效期间届满发生与原权利人利益相反的法

律效果，因此时效制度的实质，在于对民事权利的限制。

（二）时效制度的作用

1、稳定法律秩序

2、促使权利人行使权利

3、避免诉讼上举证困难

二、时效的种类

（一）取得时效

取得时效，又称占有时效，是指占有他人财产，持续达到法定期限，即可依法取得该项财产权的时效。

（二）诉讼时效

诉讼时效，是指因不行使权利的事实状态持续经过法定期间，即依法发生权利不受法律保护的时效。

（三）关于时效种类的立法体例

1、统一立法主义（法、日）

2、各别立法主义（德）

注意：我国仅规定了诉讼时效，而未规定取得时效。

第二节 诉讼时效

一、诉讼时效的含义

诉讼时效，是指权利人在法定期间内不行使权利，义务人便享有抗辩权，从而导致权利人无法胜诉的法律制度。

二、诉讼时效的效力

（一）诉讼时效效力的概念

诉讼时效的效力，是指权利人丧失何种权利的问题。

（二）诉讼时效效力的立法例

1、实体权消灭主义：日本

2、诉权消灭主义：法国

3、抗辩权发生主义：德国

（三）我国诉讼时效的效力

《民法典》采抗辩权发生主义。

三、诉讼时效的适用范围

诉讼时效的适用范围，又称诉讼时效的客体。

债权请求权。（下列请求权不适用诉讼时效的规定：（一）请求停止侵害、排除妨碍、消除危险；（二）不动产物权和登记的动产物权的权利人请求返还财产；（三）请求支付抚养费、赡养费或者扶养费；（四）依法不适用诉讼时效的其他请求权。）

四、诉讼时效期间与诉讼时效的分类

（一）诉讼时效期间的概念与特征

1、诉讼时效期间的概念

诉讼时效期间，是指权利人向人民法院请求保护其民事权利的法定期间。

2、诉讼时效期间的特征

（1）诉讼时效期间是法定期间。

（2）诉讼时效期间是可变期间。

（3）诉讼时效期间是权利人向人民法院请求保护其民事权利的法定期间，超过该期间，当事人的权利不受人民法院保护。

（二）诉讼时效的分类

诉讼时效期间按其适用范围和时效期间的长短的不同，可以将诉讼时效分为一般诉讼时效和特别诉讼时效。

1、一般诉讼时效

（1）一般诉讼时效，又称为普通诉讼时效，是指在一般情况下普遍适用的诉讼时效。

（2）向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。

2、特别诉讼时效

特别诉讼时效，是指法律规定的仅适用于某些特殊民事法律关系的诉讼时效。

（1）短期诉讼时效

短期诉讼时效，是指时效期间不足三年的诉讼时效。

（2）长期诉讼时效

长期诉讼时效，是指时效期间在 3 年至 20 年（不包括 3 年和 20 年）之间的诉讼时效。

（3）最长诉讼时效

A、最长诉讼时效，是指诉讼时效期间为 20 年的诉讼时效。

B、最长诉讼时效与其他诉讼时效的区别

a、最长诉讼时效的期间是从权利被侵害时开始计算的，而其他诉讼时效的期间是从权利人知道或者应当知道权利被侵害时开始计算的。

b、最长诉讼时效不适用诉讼时效的中断、中止等规定，而其他诉讼时效适用有关时效中断、中止的规定。

c、最长诉讼时效的目的主要在于稳定社会经济秩序，而其他诉讼时效的目的更强调保护权利人的权利。

五、诉讼时效期间的起算、中止、中断与延长

（一）诉讼时效期间的起算

诉讼时效期间的起算，又称为诉讼时效期间的开始，是指从什么时候开始计算诉讼时效。

1、诉讼时效期间从权利人知道或者应当知道自己权利受到损害以及义务人之日起计算。

（1）有约定履行期限的债权请求权，从期限届满之日的第二天开始起算。没有履行期限的债权请求权，可以确定履行期限的，诉讼时效期间从履行期限届满之日起计算；不能确定履行期限的，诉讼时效期间从债权人要求债务人履行义务的宽限期届满之日起计算但债务人在债权人第一次向其主张权利时明确表示不履行义务的，诉讼时效期间从债务人明确表示不履行义务时起算。

（2）当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算。

（3）无民事行为能力人或者限制民事行为能力人对其法定代理人的请求权的诉讼时效期间，自该法定代理终止之日起计算。

（4）未成年人遭受性侵害的损害赔偿请求权的诉讼时效期间，自受害人年满十八周岁之日起计算。

（5）请求他人不作为的债权请求权，应当自知道或者应当知道义务人违反不作为义务时起算。

（6）因侵权行为而发生的赔偿请求权，从受害人知道或者应当知道其权利被侵害或者损害发生时起算。损害事实发生时，受害人知道的，从损害时起算；损害事实发生后，受害人才知道的，从知道时起算。在人身损害赔偿中，侵害当时即发现受伤的，从侵害当日起算；侵害当时未曾发现的，事后经检查确诊并证明是由该侵害引起的，从伤势确诊之日起算。

（7）返还不当得利请求权的诉讼时效期间，从当事人知道或者应当知道不当得利事实及对方当事人之日起计算。

（8）管理人因无因管理行为产生的给付必要管理费用、赔偿损失请求权的诉讼时效期间，从无因管理行为结束并且管理人知道或者应当知道本人之日起计算；本人因不当无因管理行为产生的赔偿损失请求权的诉讼时效期间，从其知道或者应当知道管理人及损害事实之日起计算。

（9）合同被撤销产生的返还财产、赔偿损失请求权的诉讼时效期间，从合同被撤销之日起计算。

2、诉讼时效期间的起算，法律有特别规定的，应依法律的特别规定。

（二）诉讼时效的中止

诉讼时效的中止，是指在诉讼时效进行中，因一定的法定事由的发生而使权利人无法行使请求权，暂时停止计算诉讼时效期间。

1、诉讼时效中止的事由

（1）不可抗力；

（2）无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有法定代理人，或者法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代理权；

（3）继承开始后未确定继承人或者遗产管理人；

（4）权利人被义务人或者其他人控制；

（5）其他导致权利人不能行使请求权的障碍。

2、发生时效中止的时间

（1）发生时效中止时间的立法例

A、在时效进行中的任何时间都可发生时效中止。

B、只有法定事由出现在时效期间的最后一定期限内才发生时效的中止。

（2）我国关于发生时效中止时间的规定

在诉讼时效期间的最后6个月内才发生诉讼时效的中止。

3、诉讼时效中止的效力

（1）诉讼时效中止效力的立法例

A、中止事由消除后再经过法定的特别期限。

B、中止事由消除后，时效期间继续计算。

（2）我国关于诉讼时效中止效力的规定

自中止时效的原因消除之日起满六个月，诉讼时效期间届满。

（三）诉讼时效的中断

诉讼时效的中断，是指在诉讼时效进行中，因法定事由的发生致使已经进行的诉讼时效期间全部归于无效，诉讼时效期间重新计算。

1、诉讼时效中断的法定事由

（1）权利人向义务人提出履行请求。

当事人一方提出请求，是指权利人向义务人明确提出要求其履行义务的主张，客观上改变了权利不行使的事实状态，以使诉讼时效中断。（专指诉讼外的请求，不包括诉讼上的请求。）

（2）义务人同意履行义务

A、义务人同意履行义务，又称为承认，是指义务人通过一定的方式向权利人作出愿意履行义务的意思表示。

B、同意履行义务的表示方法除了书面或者能够证明的口头方式之外，债务人向债权人要求延期给付、对债务履行提供担保、支付利息或者租金、作出部分履行或者分期履行等承诺或者行为的，都属于义务人同意履行义务的表现方式。

（3）权利人提起诉讼或者申请仲裁

（4）其他

A、下列事项之一，人民法院应当认定与提起诉讼具有同等诉讼时效中断的效力：申请支付令；申请破产、申请破产债权；为主张权利而申请宣告义务人失踪或死亡；申请诉前财产保全、诉前临时禁令等诉前措施等；申请强制执行；申请追加当事人或者被通知参加诉讼；在诉讼中主张抵销等。

B、权利人向人民调解委员会以及其他依法有权解决相关民事纠纷的国家机关、事业单位、社会团体等组织提出相应民事权利的请求的，导致诉讼时效的中断。

C、权利人向公安机关、人民检察院、人民法院报案或者控告，请求保护其民事权利的，导致诉讼时效中断。

2、诉讼时效中断的效力

（1）对人的效力

诉讼时效中断原则上仅具有相对的效力，即只对使诉讼时效中断的当事人有效力。

（2）期间计算的效力

诉讼时效中断使中断事由发生前已经进行的诉讼时效全部归于无效，诉讼时效重新计算。

（四）诉讼时效的延长

1、诉讼时效的延长，是指在诉讼时效期间届满以后，权利人基于某种正当理由，向人民法院提起诉讼时，经人民法院调查确有正当理由而将法定时效期间予以处延长。

2、诉讼时效的延长发生在诉讼时效期间届满以后。在诉讼时效期间完成以后，如果权利人未能行使权利是由于某种特殊情况造成的，人民法院可根据具体情

况酌情延长诉讼时效。

3、司法实践中，人民法院应以是否涉及重大利益或者是否有重大影响为判断的基本依据。当然，为使审判人员在具体操作规程中能够宽严适度，有必要从立法上对重大利益的幅度和重大影响的范围作相应规定。

相关法条：《民法典》第一百八十八条 向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。

诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

相关法条：《民法典》第一百八十九条 当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间自最后一期履行期限届满之日起计算。

相关法条：《民法典》第一百九十条 无民事行为能力人或者限制民事行为能力人对其法定代理人的请求权的诉讼时效期间，自该法定代理终止之日起计算。

相关法条：《民法典》第一百九十一条 未成年人遭受性侵害的损害赔偿请求权的诉讼时效期间，自受害人年满十八周岁之日起计算。

相关法条：《民法典》第一百九十二条 诉讼时效期间届满的，义务人可以提出不履行义务的抗辩。

诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩；义务人已自愿履行的，不得请求返还。

相关法条：《民法典》第一百九十三条 人民法院不得主动适用诉讼时效的规定。

相关法条：《民法典》第一百九十四条 在诉讼时效期间的最后六个月内，因下列障碍，不能行使请求权的，诉讼时效中止：

（一）不可抗力；

（二）无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有法定代理人，或者法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代理权；

（三）继承开始后未确定继承人或者遗产管理人；

（四）权利人被义务人或者其他人控制；

（五）其他导致权利人不能行使请求权的障碍。

自中止时效的原因消除之日起满六个月，诉讼时效期间届满。

相关法条：《民法典》第一百九十五条 有下列情形之一的，诉讼时效中断，从中断、有关程序终结时起，诉讼时效期间重新计算：

（一）权利人向义务人提出履行请求；

（二）义务人同意履行义务；

（三）权利人提起诉讼或者申请仲裁；

（四）与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。

相关法条：《民法典》第一百九十六条 下列请求权不适用诉讼时效的规定：

（一）请求停止侵害、排除妨碍、消除危险；

（二）不动产物权和登记的动产物权的权利人请求返还财产；

（三）请求支付抚养费、赡养费或者扶养费；

（四）依法不适用诉讼时效的其他请求权。

相关法条：《民法典》第一百九十七条 诉讼时效的期间、计算方法以及中止、中断的事由由法律规定，当事人约定无效。

当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效。

相关法条：《民法典》第一百九十八条 法律对仲裁时效有规定的，依照其规定；没有规定的，适用诉讼时效的规定。

相关法条：《民总解释》第三十五条 民法典第一百八十八条第一款规定的三年诉讼时效期间，可以适用民法典有关诉讼时效中止、中断的规定，不适用延长的规定。该条第二款规定的二十年期间不适用中止、中断的规定。

相关法条：《民总解释》第三十六条 无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的权利受到损害的，诉讼时效期间自其法定代理人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算，但是法律另有规定的除外。

相关法条：《民总解释》第三十七条 无民事行为能力人、限制民事行为能力人的权利受到原法定代理人损害，且在取得、恢复完全民事行为能力或者在原法定代理终止并确定新的法定代理人后，相应民事主体才知道或者应当知道权利受到损害的，有关请求权诉讼时效期间的计算适用民法典第一百八十八条第二款、本解释第三十六条的规定。

相关法条：《民总解释》第三十八条 诉讼时效依据民法典第一百九十五条的规定中断后，在新的诉讼时效期间内，再次出现第一百九十五条规定的中断事由，可以认定为诉讼时效再次中断。

权利人向义务人的代理人、财产代管人或者遗产管理人等提出履行请求的，可以认定为民法典第一百九十五条规定的诉讼时效中断。

第三节 除斥期间

一、除斥期间的概念与特征

（一）除斥期间的概念

除斥期间，又称为预定期间，是指法律规定或者当事人依法确定的对于某种权利所预定的存续期间。

（二）除斥期间的特征

1、除斥期间一般是法律规定的。

2、除斥期间是某种权利存续的期间。

二、除斥期间的性质与作用

（一）除斥期间的性质

除斥期间是一种民事法律事实。

（二）除斥期间的作用

除斥期间的作用：稳定法律秩序；促使权利人行使权利；避免诉讼上举证困难。除斥期间更突出强调促使权利人尽快行使权利，以利于稳定社会秩序。

三、除斥期间的适用范围

除斥期间适用于形成权。适用除斥期间的主要有：撤销因重大误解订立的合同或者显失公平的合同的期间；撤销因欺诈或者胁迫订立的合同的期间；债权人行使撤销权的期间；赠与人行使撤销权的期间；行使合同解除权的期间等。

注意：法律并非对所有的形成权都设有除斥期间的规定，例如，相对人行使催告权的期间、选择权人行使选择权的期间等。

四、除斥期间的计算

（一）法律对除斥期间的起算时间有规定的，适用其规定。

（二）法律对除斥期间的起算时间没有规定的，自权利发生时起算。

五、除斥期间的效力与法律援用

（一）除斥期间的效力

1、除斥期间届满，权利即消灭。

2、除斥期间届满后，其利益不得抛弃。

（二）除斥期间的法律援用

在诉讼过程中，即使当事人不援用除斥期间，法院也应当依职权援用。

六、诉讼时效与除斥期间的区别

（一）立法精神不同

诉讼时效与除斥期间的重要作用都在于维护社会秩序，但是二者维护的社会秩序却相反。诉讼时效维护的是新秩序。除斥期间维护的是原秩序。

（二）适用范围不同

诉讼时效适用于请求权，除斥期间适用于形成权。

（三）起算时间不同

诉讼时效从知道或者应当知道权利被侵害时起计算，除斥期间根据法律规定的时间或者权利发生的时间起算。

（四）期间的可变性不同

法律对诉讼时效有中止、中断、延长的规定；对除斥期间没有中止、中断、延长的规定。

（五）法律效力与法律援用不同

诉讼时效期满后，权利并不当然消灭；除斥期间期满后，权利当然消灭。诉讼时效期间届满后，当事人可以放弃时效利益；除斥期间届满后，其利益不得抛弃。

诉讼时效是当事人主张时法院才援用，除斥期间是法院依职权援用。

相关法条：《民法典》第一百九十九条 法律规定或者当事人约定的撤销权、解除权等权利的存续期间，除法律另有规定外，自权利人知道或者应当知道权利产生之日起计算，不适用有关诉讼时效中止、中断和延长的规定。存续期间届满，撤销权、解除权等权利消灭。

第四节 期限

一、期限的概念与意义

（一）期限的概念

期限，是指民事法律关系发生、变更和消灭的时间。

（二）期限的分类

期限分为期间和期日。

1、期间

（1）期间，是指从时间的某一特定的点到另一特定的点所经过的时间。

（2）期间是某一特定的时间段。

2、期日

（1）期日，是指不可分割的一定时间。

（2）期间是时间的某一特定的点。

（三）期限的确定

1、期限可以由法律规定，也可以由人民法院裁判确定，还可以由双方当事人约定，在有些情况下还可以由当事人一方依法指定。

2、无论采用什么方式，期限一旦确定之后，对双方当事人都具有法律约束力，任何一方不得擅自变更。

（四）期限的意义

1、决定民事主体的民事权利能力和民事行为能力享有和消灭的时间。

2、决定某些事实的推定时间。

3、决定权利的取得和丧失时间。

4、权利的行使和义务履行的期限。

5、决定法律关系的效力的期限。

二、期限的确定和计算方法

（一）期限的确定方式

1、规定一定的期日

2、规定一定的期间

3、规定未来某一特定的时刻

4、规定以当事人提出请求的时间为准

（二）期间的计算

1、按照年、月、日计算期间的，开始的当日不计入，自下一日开始计算。按照小时计算期间的，自法律规定或者当事人约定的时间开始计算。

2、按照年、月计算期间的，到期月的对应日为期间的最后一日；没有对应日的，月末日为期间的最后一日。

3、期间的最后一日是法定休假日的，以法定休假日结束的次日为期间的最后一日。期间的最后一日的截止时间为二十四时；有业务时间的，停止业务活动的时间为截止时间。

4、期间的计算方法依照本法的规定，但是法律另有

规定或者当事人另有约定的除外。

5、民法所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

（三）期日的计算

期日的计算 ，一般以法定期日、指定期日和约定期日为准。

相关法条：《民法典》第二百条 民法所称的期间按照公历年、月、日、小时计算。

相关法条：《民法典》第二百零一条 按照年、月、日计算期间的，开始的当日不计入，自下一日开始计算。

按照小时计算期间的，自法律规定或者当事人约定的时间开始计算。

相关法条：《民法典》第二百零二条 按照年、月计算期间的，到期月的对应日为期间的最后一日；没有对应日的，月末日为期间的最后一日。

相关法条：《民法典》第二百零三条 期间的最后一日是法定休假日的，以法定休假日结束的次日为期间的最后一日。

期间的最后一日的截止时间为二十四时；有业务时间的，停止业务活动的时间为截止时间。

相关法条：《民法典》第二百零四条 期间的计算方法依照本法的规定，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

相关法条：《民法典》第二百零五条 民法所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。